

La negoziazione assistita da uno o più avvocati e la procédure participative

Carlo Alberto Calcagno

**Atti del convegno di Vicenza tenuto il 4 febbraio 2015 e
organizzato da**



Con il riconoscimento di 4 crediti da parte del COA Vicenza

15

1.Introduzione

Il 12 settembre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132¹.

In questo provvedimento è stata dettata, tra le altre², la disciplina della “*Procedura di negoziazione assistita da un avvocato*”.

In seguito la norma è approdata al Senato per la conversione in legge (Atto n. 1612³) e sono stati presentati e discussi diversi emendamenti⁴.

Il 23 ottobre 2014 l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo⁵ ed ha approvato un maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1612 di conversione⁶, in cui è presente peraltro l'emenda con riferimento a diversi articoli del decreto-legge originario⁷.

Il provvedimento è quindi approdato alla Camera (C. 2681⁸) e qui il 3 novembre 2014 è stata posta la questione di fiducia⁹ sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiunti, di un articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione Giustizia della Camera, identico a quello del Senato.

La Camera, con 353 voti favorevoli e 192 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione in data 4 novembre 2014. E dunque la conversione in legge è avvenuta sul testo già approvato dal Senato¹⁰.

In data 10 novembre 2014¹¹ è stata pertanto pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge di conversione che è in vigore dal giorno 11 novembre 2014.

¹ Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Il decreto è entrato in vigore oggi 13-9-2014.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=GvFgrUuTKrmJ415FSOzDLQ__ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.codiceRedazionale=14G00147&elenco30giorni=false
Per la relazione tecnica che è dell'11 settembre 2014 v. <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00801694.pdf>

² Il decreto si compone di sette capi: il capo I reca disposizioni per l'eliminazione dell'arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti; il capo II disciplina la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; il capo III prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio; il capo IV è dedicato alle disposizioni volte a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione; il capo V riguarda la tutela dei crediti e l'accelerazione e semplificazione del procedimento di esecuzione forzata; il capo VI è dedicato all'organizzazione giudiziaria; infine, il capo VII concerne le disposizioni finali e reca la disciplina relativa alla copertura finanziaria.

³ <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44818.htm>

⁴ Cfr. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44818_testi.htm

⁵ Con 161 voti favorevoli 51 contrari.

⁶ <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/806267/index.html>

⁷ In particolare agli articoli 2,3,4,6,7,9, 10 e 11.

⁸ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/aula/44906_aula.htm

⁹ Precisamente per la 24a volta.

¹⁰ Cfr. per il testo integrato <http://mediaresenzaconfini.org/2014/10/24/arbitrato-e-negoziazione-assistita-al-231014-approvazione-del-senato/>

¹¹ GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84

Si tratta della Legge 10 novembre 2014, n. 162. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175)¹².

La disciplina della negoziazione assistita obbligatoria acquista però efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione¹³ e dunque il 9 febbraio 2015.

L'adozione della norma era stata peraltro preannunciata in seno al Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014 ove furono presentati i 12 punti sulla Giustizia per i quali venne avviata una pubblica consultazione conclusasi il 31 agosto 2014¹⁴.

Anche il Ministero della Giustizia ha richiamato l'attenzione pubblica sull'istituto in varie occasioni: il 2 luglio del 2014 con la precisazione che la negoziazione assistita si sarebbe occupata di 60.000 controversie¹⁵ ed il 3 luglio 2014¹⁶ con una corposa nota.

È seguito infine il 5 settembre 2014, sempre in chiave di presentazione dello stesso ministro Orlando, l'Atto di indirizzo politico – istituzionale per l'anno 2015¹⁷, ove si specifica che *“Si vanno quindi definendo forme alternative di risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all'istituto della negoziazione assistita, configurata come complementare e non alternativa alla già*

¹²

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-10&atto.codiceRedazionale=14G00175&elenco30giorni=false

¹³ Art. 3 comma 8 L. 162/14

¹⁴ 1) Giustizia civile: riduzione dei tempi. Un anno in primo grado

2) Giustizia civile: dimezzamento dell'arretrato.

3) Corsia preferenziale per le imprese e le famiglie

4) Csm: più carriera per merito e non grazie alla “appartenenza”

5) Csm: chi giudica non nomina, chi nomina non giudica;

6) Responsabilità civile dei magistrati sul modello europeo

7) Riforma del disciplinare delle magistrature speciali (amministrativa e contabile);

8) Norme contro la criminalità economica (falso in bilancio, autoriciclaggio);

9) Accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione;

10) Intercettazioni (diritto all'informazione e tutela della privacy);

11) Informatizzazione integrale del sistema giudiziario;

12) Riqualificazione del personale amministrativo.

Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7.wp

¹⁵ Il dato era probabilmente un poco sovrastimato.

L'11 settembre 2014 la reazione tecnica (v. p. 20) al decreto legge (<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00801694.pdf>) assumeva che in negoziazione assistita ordinaria andassero 35.000 procedure, in quella familiare 10.000 (<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/801884/index.html>): si sono perse dunque 15.000 pratiche rispetto al primo annuncio. La nota del Bilancio peraltro assume che i 35.000 procedimenti sono una mera ipotesi.

E dunque di certe per la nota del bilancio avremmo solo 10.000 controversie (a fronte di un arretrato di 5.257.693); visto che la relazione tecnica stima poi che 7.000 controversie andranno davanti all'ufficiale di stato civile (oggi Sindaco), la portata teorica di questa riforma sarebbe di 18.000 controversie a fronte delle ventilate 60.000. I posteri ci daranno il dato effettivo.

¹⁶ Misure di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo. Conciliazione con l'assistenza degli avvocati (negoziiazione assistita) civile. https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp;sessionId=8F13BCFA504626A766F3A9B5ABB3906E.ajpAL03?previsio usPage=mg_2_7_1&contentId=ART1040203

¹⁷ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_6_2.wp

avviata mediazione, istituto che, nuovamente reso obbligatorio dal decreto del fare del giugno 2013, sta gradualmente producendo effetti deflattivi significativi”.

Bisogna ricordare però che il cammino dell’istituto nel nostro paese inizia con un testo elaborato del 10 maggio 2011¹⁸ a cui hanno partecipato l’AIAF, l’AIGA, l’UNCC e l’unione Triveneta dei Consigli dell’ordine degli avvocati.

A seguito di tale proposta dell’Avvocatura il 25 maggio 2011 viene presentato un disegno di legge di 25 articoli alla Camera dai deputati Contento (PDL) e Paniz (PDL)¹⁹ e il 13 giugno 2011 al Senato dal senatore Divina (LN-Aut)²⁰.

Tali provvedimenti sicuramente ispirati²¹ dalla disciplina francese della *procédure participative*²² decadde con la fine della legislatura.

Alla vigilia del Congresso degli Avvocati di Bari del 22-24 novembre 2012 il prof. Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense, indicò nel suo contributo congressuale la negoziazione assistita quale strumento privilegiato.

Addirittura un partito politico²³ sempre nel 2012 ebbe a parlare nel suo programma elettorale di *“negoziiazione diretta con valore di titolo esecutivo in presenza degli avvocati”*²⁴.

Sulla scia evidentemente di tale popolarità il 15 marzo 2013 il disegno di legge decaduto con la fine della precedente legislatura venne quasi identicamente ripresentato al Senato dal senatore Divina²⁵.

Il 1° agosto 2013 l’on Venittelli (PD) ed altri²⁶ presentano alla Camera un nuovo provvedimento in materia²⁷ che ricalca però, salvo qualche variazione²⁸, i precedenti quanto alla negoziazione assistita.

Una prima considerazione circa questi provvedimenti che a dire il vero non furono mai esaminati e/o discussi dal Parlamento, riguarda il fatto che negli anni l’istituto è stato coltivato dalle più diverse forze politiche.

¹⁸ Cfr. <http://www.avvocatitriveneto.it/wp-content/uploads/2011/07/12.-Procedura-partecipativa-AIAF-UNCC-Triveneto.pdf>; <http://www.avvocatitriveneto.it/wp-content/uploads/2014/03/NEGOZIAZIONE-ASSISTITA-e-CAMERE-ARBITRALI.pdf>

¹⁹ "Disciplina della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" - Atto Camera 4376. Cfr. http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0049450

²⁰ "Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" – Atto Senato n. 2774 <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=619604>

²¹ "L'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità della convenzione e prevede l'obbligo deontologico di avvisare i clienti sulla possibilità di ricorrervi. È anche prevista la possibilità di ricorrere all'ausilio di un mediatore designato da un organismo di mediazione, di un mediatore familiare o, per gli aspetti tecnici della questione, di esperti e di consulenti".

²² Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010.

²³ Fare per fermare il declino.

²⁴ Cfr. <http://www.fermareildeclino.it/far-funzionare-la-giustizia-ecco-come>

²⁵ "Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" -Atto Senato n. 148. <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/698858/index.html>

²⁶ Biffoni, Leva, Tartaglione, Zanin.

²⁷ Disposizioni concernenti l'istituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura presso gli ordini forensi, la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato e misure di liberalizzazione e semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili - Atto Camera n. 1474; al 14 gennaio 2015 non è ancora iniziato l'esame.

²⁸ V. gli art. 23, 28, 30, 32, 35 e 39.

Possiamo poi dire che tutti i testi presentati, in ossequio alla disciplina francese, ci presentavano uno strumento alternativo da utilizzarsi soltanto nella ipotesi in cui le parti non avessero ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro.

Sempre in aderenza alla disciplina transalpina l'adozione dell'istituto era volontario.

Il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita poteva essere pattuito anche come clausola contrattuale.

Gli avvocati designati, se autorizzati dalle parti, potevano ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un organismo di conciliazione ovvero, nei casi relativi a n.a. e famiglia, all'ausilio di mediatore familiare abilitato.

L'accordo che le parti avessero eventualmente raggiunto diveniva titolo esecutivo soltanto a seguito di omologazione giudiziaria.

Le parti ponevano in essere una transazione (o una rinuncia) che poteva essere impugnata con i rimedi civilistici relativi.

In caso di mancato accordo si prevedeva la dispensa dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se previsto dalla legge²⁹.

In sede di invito alla stipula della convenzione andava inserito l'avvertimento che in alternativa poteva scegliersi la mediazione. Con ciò si richiamava il principio posto dal Nuovo codice di procedura civile francese³⁰ per cui gli strumenti di risoluzione amichevole debbono essere sullo stesso piano e a servizio delle parti di un litigio.

La negoziazione poteva investire oltretutto la separazione ed il divorzio anche la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Ma un ricorso congiunto per valersi dell'accordo in sede di modifica delle condizioni di separazione doveva essere sottoposto al Tribunale per l'omologazione, sentito il pubblico ministero; ed il Tribunale in caso di contrasto con l'interesse dei figli poteva convocare le parti per proporre modifiche o negare l'omologazione.

Nel caso di separazione consensuale si prevedeva che il presidente del tribunale, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, aggiunto il parere del pubblico ministero, riferisse al tribunale in camera di consiglio che provvedeva con decreto all'omologazione dell'accordo. Anche in tal caso il Tribunale poteva convocare le parti per proporre modifiche o negare l'omologazione. La stessa soluzione era prevista per la separazione dei coniugi non coniugati.

²⁹ In Francia tale formulazione considerava essenzialmente la pattuizione contrattuale della mediazione.

³⁰ Si stabilisce, infatti, nel libro V che *“Le parti di una controversia possono, di propria iniziativa e alle condizioni stabilite nel presente libro, cercare di risolvere amichevolmente con l'assistenza di un mediatore, di un conciliatore di giustizia o come parte di un processo partecipativo, dei loro avvocati”*.

Soluzioni analoghe valevano per il caso di divorzio per cui doveva darsi atto dell'infruttuoso tentativo di conciliazione³¹, e di modifica delle condizioni dello stesso.

Interessante era ancora la possibilità di negoziare anche nel corso di un procedimento arbitrale, che oggi ci siamo guardati bene da inserire nell'ambito dell'arbitrato endoprocessuale.

Vi era poi la possibilità di fruire del gratuito patrocinio nel caso però di accordo omologato. E anche i benefici fiscali erano equiparati a quelli della mediazione, sempre nel caso di accordo omologato.

Sussisteva un obbligo dei consigli dell'ordine di formazione in merito alle procedure di negoziazione e di mediazione e alle relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice.

A ben leggere il decreto-legge 132/14 e la legge di conversione, possiamo affermare che il dettato normativo non è stato particolarmente ispirato dai progetti citati.

Un solo intero articolo, quello sull'antiriciclaggio che peraltro non esiste nella disciplina transalpina è presentato nell'identico testo.

Ma prima di intrattenerci sulla disciplina del decreto-legge 132/14 e su quella derivante dalla conversione del decreto³² è opportuno gettare un ampio sguardo comparatistico sulla disciplina.

mediare senza confini.org

³¹ Come nella disciplina francese.

³² Legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. La procédure participative

2.1 I provvedimenti normativi e la genesi

Vi sono in Francia rimedi alternativi al giudizio diversi dalla *conciliation* e dalla *médiation*.

Tra il 2010 ed il 2012 è stato introdotto uno strumento di risoluzione amichevole delle controversie, la *procédure participative* che può essere utilizzata dalle parti assistite obbligatoriamente da avvocato.

Mancano ancora i decreti attuativi che dovevano essere emanati entro il settembre 2011 dall'Esecutivo e così non è stato: la disciplina che sia chiara e precisa è considerabile in vigore dal 23 gennaio 2012³³.

L'art. 4 c. 4 della legge di riforma di alcune professioni tra cui quella di avvocato (v. titolo I, capitolo I³⁴) stabilisce poi che "*Nessuno può, se non è avvocato, assistere una parte nella procedura partecipativa prevista dal codice civile*"³⁵.

La *procédure participative* è stata inserita nel 2010 nel Codice civile³⁶ e poi disciplinata nel 2012 dal Codice di rito³⁷ che fa riferimento alla disciplina del Codice Civile.

Il suo cammino inizia nel 2008 con il rapporto "*L'ambition raisonnée d'une justice apaisée*" di Serge Guinchard, presidente della Commissione per la ripartizione del contenzioso³⁸.

In questo corposo documento si specifica che la *procédure participative* è stata ispirata ai membri della Commissione dal diritto collaborativo nordamericano.

Ma l'articolazione dell'istituto che comprende una fase extragiudiziarica nella quale può essere eventualmente investito un perito della soluzione di una controversia ha, come vedremo, radici molto antiche³⁹.

La Commissione Guinchard⁴⁰ nel suo rapporto indicava peraltro nel diritto collaborativo evidenti limiti sia in termini di costi, sia con riferimento all'assistenza dell'avvocato che è compresa alla fase stragiudiziale.

³³ "Son entrée en vigueur était subordonnée à l'intervention de décrets d'application qui devaient intervenir au plus tard le 1er septembre 2011 (L. 22 déc. 2010, art. 43). À ce jour, ses décrets n'ayant toujours pas été publiés par le pouvoir exécutif, la loi n'en demeure pas moins applicable, dès lors que ses dispositions sont suffisamment claires et précises (Crim., 9 juill. 2003 : Bull. n° 138)". Jérôme Bonnaud. *Les nouveaux privilèges des avocats: fiducie, convention de procédure participative, acte privé contresigné*. 2011. <halshs-00654252>

³⁴ Titre Ier: Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat Chapitre Ier: Dispositions générales.

³⁵ Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. In <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508793&idArticle=LEGIARTI000006902784&dateTexte=&categorieLien=cid>

³⁶ Art. 37 legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 che ha introdotto gli articoli che vanno da 2062 a 2067 del Codice civile.

³⁷ Art. 2 del Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 - art. 2 Titolo II del libro V: Il processo partecipativo (articoli 1542- 1564).

³⁸ Si può trovare in <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000392/0000.pdf>

³⁹ Bisogna dire che i Francesi hanno con la consulenza tecnica un rapporto secolare e che i loro provvedimenti tramite l'opera di Napoleone hanno influenzato la legislazione di mezza Europa e significativamente quella del nostro paese.

⁴⁰ Cfr. in particolare da pag. 168 in poi.

Si può trovare in <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000392/0000.pdf>

Appare qui di qualche interesse riportare il passo pertinente del rapporto.

"La Commissione ha voluto ispirarsi alla prassi del Nord America conosciuta come "diritto collaborativo" per suggerire la nascita in Francia di una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, la "procedura partecipativa" di negoziazione assistita tramite avvocato.

Il diritto collaborativo

Il diritto collaborativo ha registrato una forte crescita negli ultimi quindici anni negli Stati Uniti, dove è nato, e dove è ampiamente praticato in oltre 40 stati. Si è anche sviluppato rapidamente in Canada, Australia e Nuova Zelanda e ha fatto un notevole passo avanti in Europa. Data la portata del fenomeno, gli avvocati francesi hanno preso l'iniziativa in questi ultimi anni, di utilizzare i processi collaborativi come parte delle controversie familiari. Ampiamente usato nel campo, questo modo singolare di risoluzione delle controversie consensuale può comunque riguardare contestazioni di qualsiasi genere. Nei paesi dove è largamente praticato, il diritto collaborativo è usato nel diritto civile, nel diritto del lavoro, nel diritto delle assicurazioni, o per le successioni, ed in particolare il contenzioso commerciale⁴¹. Come per tutti i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, è vietato temporaneamente alle parti di ricorrere ai tribunali. Si va ben oltre, però.

La sua particolarità risiede nel fatto che si basa su una "carta di collaborazione" che obbliga le parti di un litigio ed i loro avvocati a compiere ogni sforzo per giungere a una soluzione consensuale. Più in particolare le obbligazioni dei firmatari importano che essi non possano considerare il ricorso giudiziario come un'alternativa preferibile.

A tal fine gli avvocati sono tenuti a ritirarsi dal procedimento quando una parte viola il patto ed adisce il giudice, ma pure se nutrono dubbi circa la reale intenzione del cliente o dell'altra parte di condurre efficacemente i negoziati.

Meglio ancora la sottoscrizione della carta vieta, in caso di fallimento della procedura, di rappresentare poi nel contenzioso una delle parti. Infine, è convenuto che i pezzi di informazioni scambiati durante il processo di collaborazione non possano essere utilizzati in qualsivoglia contenzioso successivo⁴².

⁴¹ Section 3 – La procédure participative de négociation assistée par avocat

La commission a souhaité s'inspirer de la pratique nord-américaine dite du « droit collaboratif », pour proposer l'émergence en France d'un nouveau mode de règlement des conflits, la « procédure participative » de négociation assistée par avocat.

Le droit collaboratif nord-américain

Le droit collaboratif a connu un fort développement depuis une quinzaine d'années aux États-Unis, où il est né, et où il est largement pratiqué dans plus de 40 États. Il s'est également rapidement développé au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et a fait une percée remarquable en Europe. Face à l'ampleur du phénomène, des avocats français ont pris l'initiative, depuis quelques années, de recourir à des processus collaboratifs dans le cadre de contentieux familiaux. Très utilisé dans ce domaine, ce mode singulier de règlement consensuel des différends peut néanmoins appréhender des litiges de toute nature. Dans les pays qui le pratiquent déjà à grande échelle, le droit collaboratif est utilisé en droit de la responsabilité, droit du travail, droit des assurances ou encore pour le règlement des successions, des litiges commerciaux notamment.

⁴² Comme tout mode alternatif de règlement des conflits, il interdit provisoirement aux parties de recourir au juge. Il va néanmoins beaucoup plus loin. Sa particularité tient à ce qu'il repose sur une « charte collaborative » qui oblige non seulement les parties au litige, mais également leurs avocats, à tout mettre en œuvre pour aboutir à une solution consensuelle. Plus précisément, les obligations découlant de cette charte s'articulent de manière à ce qu'aucun des signataires ne puisse envisager

Queste caratteristiche fondano la forza del diritto collaborativo, ma ne mostrano anche i limiti. Avendo tutto da perdere dal fallimento della procedura collaborativa, le parti sono incitate a partecipare attivamente e utilmente nella ricerca di una soluzione negoziata. In Canada il Ministero della Giustizia ha effettuato uno studio sulla qualità del diritto collaborativo, i risultati, pubblicati nel 2005, hanno evidenziato l'impatto molto positivo dello sviluppo di queste procedure e l'alto livello di soddisfazione delle parti, soprattutto in materia familiare.

Tuttavia, non si può ignorare che ciò che promuove il successo del processo collaborativo è anche ciò che ne rende particolarmente drammatico il fallimento.

Coloro che non sono in grado di raggiungere una soluzione negoziata non avranno le risorse, finanziarie e probatorie, per avviare quelle azioni legali che poi rimangono ancora l'unica via d'uscita.

Quando l'accesso alla giustizia è in gioco, sembra difficile accettare di ragionare in termini di "tutto o niente" e di porre in una posizione di schiacciante sconfitta tutti coloro che non sono riusciti a raggiungere un pieno accordo⁴³.

L'introduzione in Francia di un processo partecipativo

Il diritto collaborativo è una sorta di ricerca di una transazione contrattualizzata, che coinvolge, oltre alle parti, i loro avvocati. A questo riguardo, è particolarmente interessante per ispirare, incoraggiare le parti a una soluzione negoziata della controversia, pur mantenendo un accesso più efficace alla giustizia.

Questo è l'oggetto della proposta della commissione, volta a creare in Francia un processo partecipativo di negoziazione assistita tramite avvocato.

Il piano adottato dalla Commissione si basa sul ruolo centrale della leadership e dell'assistenza di un avvocato. Esso funziona come segue.

Le parti del processo partecipativo, assistite dai loro avvocati si impegnano in esso volontariamente prima di qualsiasi contenzioso.

le recours au juge comme une alternative préférable. À cette fin, les avocats sont tenus de se désengager de la procédure dès lors que l'une des parties rompt le pacte en saisissant le juge, mais également s'ils ont le moindre doute quant à la volonté réelle de leur client ou de l'autre partie d'avancer efficacement dans la négociation. Mieux encore, la signature de la charte leur interdit, en cas d'échec de la procédure, de représenter ultérieurement l'une quelconque des parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Enfin, il est convenu que les éléments d'information échangés au cours de la procédure collaborative ne peuvent être utilisés dans une éventuelle procédure contentieuse ultérieure.

⁴³ Ces traits caractéristiques font la force du droit collaboratif, mais ils en montrent également les limites. Ayant tout à perdre dans l'échec de la procédure collaborative, les parties sont effectivement incitées à participer activement et utilement à la recherche d'une solution négociée. Au Canada, le ministère de la Justice a mené une étude qualitative concernant le droit collaboratif, dont les conclusions, rendues publiques en 2005, ont mis en évidence l'impact très positif du développement de ces procédures et le niveau élevé de satisfaction des parties, notamment en matière familiale. Pour autant, on ne peut ignorer que ce qui favorise le succès du processus collaboratif est en même temps ce qui rend son échec particulièrement dramatique. Ceux qui n'auront pu aboutir à une solution négociée n'auront plus les moyens, financiers et probatoires, de se lancer dans une procédure judiciaire qui demeure alors pourtant leur seule issue. Lorsque l'accès à la justice est en jeu, il paraît difficilement acceptable de raisonner en termes de « tout ou rien » et de placer en situation d'échec insurmontable tous ceux qui ne seront pas parvenus à un accord total.

La loro volontà di sostenere la risoluzione della loro controversia prende la forma di una convenzione di partecipazione che li impegna a collaborare in buona fede per la risoluzione negoziata della controversia. La capacità della procedura di soddisfare le esigenze specifiche delle parti è assicurata dal fatto che l'oggetto, i termini e fattori che determinano la soluzione sono contenuti nella convenzione di partecipazione.

Le parti devono determinare le questioni da cui dipende la risoluzione del litigio, gli elementi informativi necessari per l'elaborazione delle soluzioni e le modalità del loro scambio. Esse forniscono inoltre le regole che disciplineranno l'eventuale necessità di un perito e la sua retribuzione.

Il processo partecipativo è quindi in grado di estendere efficacemente la portata delle clausole di conciliazione che sono comunemente utilizzate, ma sono spesso a rischio per la loro evasività, ed indirettamente alimentano il contenzioso giudiziario che circonda la loro attuazione⁴⁴.

Si è naturalmente previsto che le parti si impegnino reciprocamente a non adire il giudice durante il corso del contratto partecipativo. Perché ciò sia proficuo, l'impegno a non adire il giudice deve produrre le stesse conseguenze procedurali che la Corte Suprema riconnette alle clausole preventive di conciliazione. E dunque una pronuncia di irricevibilità.

Il contratto partecipativo potrà prevedere, in conformità con la legge del 17 giugno 2008, una riforma della prescrizione civile, la sospensione del termine di prescrizione durante il corso del processo partecipativo, tranne nelle materie in cui tali accordi sono esclusi dalla legge.

Per renderlo più attraente e sicuro alla fine, la Commissione propone di coordinare pienamente il processo partecipativo con il sistema giudiziario.

In primo luogo prevedendo che l'accordo contenente la regolazione pattizia del litigio possa essere omologato dal giudice competente tramite una procedura di giurisdizione graziosa alla fine della quale sarà dotato di forza esecutiva nel caso in cui essa si rivelasse come necessaria.

⁴⁴ L'introduction en France d'une procédure participative

Le droit collaboratif constitue une forme de recherche transactionnelle contractualisée, faisant intervenir, en sus des parties, leurs avocats. À cet égard, il apparaît particulièrement intéressant de s'en inspirer, pour inciter les parties à la résolution négociée de leur différend, tout en préservant davantage leur accès effectif à la justice. Tel est l'objet de la proposition de la commission, tendant à créer en France une procédure participative de négociation assistée par avocat.

Le schéma retenu par la commission est fondé sur le rôle central d'impulsion et d'assistance des avocats. Il se décline de la façon suivante.

Les parties à la procédure participative, assistées de leurs avocats, s'y engagent volontairement avant toute procédure contentieuse. Leur volonté de prendre en charge la résolution de leur différend prend la forme d'une convention de participation qui les engage à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution négociée du différend. La capacité de la procédure à répondre aux besoins particuliers des parties est assurée par le fait que l'objet, les modalités et les éléments déterminant la solution sont inscrits dans la convention de participation. Les parties y déterminent nécessairement les questions qu'impliquent la résolution du litige, les éléments d'information nécessaires à l'élaboration des solutions et les modalités de leur échange. Elles prévoient également les règles qui encadreront l'éventuelle intervention d'un technicien et sa rémunération. La procédure participative est ainsi apte à prolonger utilement les clauses de conciliation qui sont d'usage courant mais qui risquent souvent, par leur imprécision, de nourrir indirectement le contentieux judiciaire autour de leur mise en œuvre.

Poi, perché in caso di disaccordo o di accordo parziale, le parti non siano costrette a rimettere tutto in causa dopo aver condotto una lunga procedura, è previsto un verbale per constatare l'accordo parziale e i punti su cui la controversia continua: il beneficio per le parti allora consiste nel poter adire al giudice con la sola rimessione al cancelliere del documento, accompagnato dalle produzioni pertinenti, perché da una parte siano omologati i punti di accordo e dall'altra si statuisca sui punti in disaccordo senza che la causa scada ad un livello precedente, dato l'avanzamento delle trattative tra le parti durante il processo partecipativo.

I tempi destinati alla negoziazione a monte della lite giudiziaria permettono anzi di accelerare gli ulteriori tempi processuali, in caso di fallimento totale o parziale della negoziazione⁴⁵.

La necessità di assistere e consigliare le parti durante i negoziati, e l'esito giudiziario del processo partecipativo, giustificano che ciascuna parte sia assistita dal suo legale nella conduzione del processo partecipativo.

L'assistenza di un avvocato pone le parti in grado di difendere i loro interessi nel modo più pertinente. Ecco perché si prevede che tutte le formalità siano espletate dalle parti con l'assistenza dei loro avvocati: la convenzione partecipativa è firmata e, se del caso, può essere variata dalle parti, sempre assistite dai loro avvocati; il riconoscimento della soluzione negoziata, dei punti restanti del litigio, della volontà delle parti di adire al giudice e gli accordi che posero fine alla procedura sono egualmente sottoscritti in presenza degli avvocati.

La commissione si è particolarmente preoccupata che il diritto di accesso al giudice sia preservato.

Da un lato, l'obbligo per l'avvocato, previsto dal diritto collaborativo, di ritirarsi se la trattativa fallisce, non è stabilito. D'altra parte, in caso di emergenza, è ancora possibile andare in tribunale per ottenere un ordine di misure provvisorie o conservative. Infine, in caso di violazione del contratto di una parte, il disposto lascia l'altra parte libera dal suo obbligo di non adire il tribunale⁴⁶.

⁴⁵ Il est naturellement prévu que les parties s'engagent mutuellement à ne pas saisir le juge pendant le cours du contrat participatif. Pour qu'il soit complet, l'engagement de ne pas saisir le juge doit produire les mêmes conséquences procédurales que celles qui sont attachées par la Cour de cassation aux clauses de conciliation préalable. Il s'agira donc d'une fin de non-recevoir. Le contrat participatif pourra prévoir, conformément à la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, la suspension du délai de prescription pendant le cours de la procédure participative, sauf dans les matières où de tels accords sont exclus par ladite loi. Pour la rendre attractive et en sécuriser l'issue, la commission propose d'articuler de manière complète la procédure participative avec le système judiciaire. D'abord, en prévoyant que l'accord constatant le règlement consensuel du litige peut être homologué par le juge compétent dans le cadre d'une procédure gracieuse de sorte qu'il sera doté de la force exécutoire lorsque cela sera nécessaire. Ensuite, parce qu'en cas de désaccord ou d'accord partiel, les parties ne sont pas contraintes de tout remettre en cause dans le cadre d'une longue procédure contentieuse : un procès-verbal est prévu pour constater l'accord partiel ainsi que les points sur lesquels le litige persiste ; l'avantage pour les parties consiste alors à pouvoir saisir la juridiction compétente par la seule remise au greffe de ce document, accompagné des pièces utiles, pour, d'une part, homologuer les points d'accord et, d'autre part, statuer sur les points de désaccord sans que l'affaire soit renvoyée à la mise en l'état, compte tenu de l'avancement des échanges entre les parties pendant le cours de la procédure participative. Le temps consacré à la négociation en amont de la procédure judiciaire permet ainsi d'accélérer le déroulement d'une procédure judiciaire ultérieure, en cas d'échec total ou partiel de la négociation.

⁴⁶ La nécessité d'assister et de conseiller les parties tout au long de la négociation, ainsi que le dénouement judiciaire de la procédure participative, justifient que les parties soient chacune assistées de leur avocat pour conduire la procédure

Inoltre, per le materie prevedenti diritti indisponibili, la Commissione ha programmato un regime speciale, che garantisce il rispetto dei diritti in questione e che è costruito attorno ai seguenti principi.

In primo luogo le parti in queste materie, secondo le precisazioni che seguono, assistite dai loro avvocati adiscono il giudice, che statuisce con ordinanza sulla richiesta, se autorizzare la conduzione di una procedura partecipativa.

Per la procedura di divorzio e di separazione, comprese le liquidazioni successive, non è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice per avviare un processo partecipativo; tuttavia, il riferimento al giudice e il procedimento dinanzi a lui restano soggetti alle disposizioni speciali in vigore.

D'altra parte, un accordo non può produrre effetti che dopo l'omologazione da parte del giudice competente a conoscere della questione, vale a dire, il giudice naturale, il cui coinvolgimento garantisce che l'accordo rispetti l'ordine pubblico e tuteli i diritti e gli interessi di alcuno.

Infine, su domanda del rappresentante del Consiglio Superiore del notariato, si precisa che la procedura partecipativa non pregiudica alcuna regola della pubblicità fondiaria, di modo che il ruolo del notaio è conservato, nel rispetto delle esigenze del decreto n. 55-22 del 4 gennaio 1955 e del decreto n. 55-1350 del 14 ottobre 1955.

La commissione ritiene che il processo partecipativo sia ben progettato, a seguito dell'accordo formalizzato e della sua relazione con il sistema giudiziario, un quadro giuridico prevedibile e sicuro per le parti, incoraggiate a risolvere la loro controversia amichevolmente con l'assistenza dei loro avvocati⁴⁷.

participative. L'assistance par un avocat place les parties en mesure de défendre leurs intérêts de la manière la plus pertinente. C'est pourquoi il est prévu que l'ensemble des formalités doit être accompli par les parties avec l'assistance de leurs avocats : la convention de participation est signée et, le cas échéant, modifiée par les parties, toujours assistées de leurs avocats ; la constatation de la solution négociée, des points restant litigieux ou de la volonté des parties de se tourner désormais vers le juge et les accords qui mettent un terme à la procédure sont également signés en présence des avocats.

La commission s'est particulièrement attachée à ce que le droit d'accès à un juge soit préservé. D'une part, l'obligation qui est faite à l'avocat, en droit collaboratif, de se déporter en cas d'échec de la négociation, n'est pas reprise. D'autre part, en cas d'urgence, il demeure possible de saisir le juge aux fins d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Enfin, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, le dispositif délègue l'autre partie de son obligation de ne pas saisir la justice.

⁴⁷ En outre, pour les matières dans lesquelles les droits sont indisponibles, la commission a prévu un régime spécifique, garantissant le respect des droits en cause et s'articulant autour des grands principes suivants.

D'une part, dans ces matières, et sous réserve des précisions qui suivent, les parties assistées de leurs avocats sollicitent du juge, qui statue par ordonnance sur requête, l'autorisation d'engager une procédure participative. Pour les procédures de divorce et de séparation de corps, en ce compris les liquidations subséquentes, l'autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour engager une procédure participative; en revanche, la saisine du juge et la procédure suivie devant lui demeurent soumises aux dispositions spéciales en vigueur.

D'autre part, un accord ne pourra produire d'effet qu'après son homologation par le juge compétent pour connaître de la matière, c'est-à-dire le juge naturel, dont l'intervention permet de s'assurer que l'accord respecte l'ordre public et préserve les droits et intérêts de chacun.

Enfin, à la demande du représentant du Conseil supérieur du notariat, il est précisé que la procédure participative ne préjudicie pas aux règles de la publicité foncière, de façon à ce que le rôle du notaire soit préservé, dans le respect des exigences du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955.

La commission considère que la procédure participative ainsi conçue constitue, en raison de la convention formalisée et de son articulation avec le système judiciaire, un cadre juridique prévisible et sécurisant pour les parties, incitant celles-ci à résoudre leur litige à l'amiable, avec l'assistance de leurs avocats.

La nuova esperienza giuridica della *procédure participative*, emendata dai difetti del diritto collaborativo, almeno a dire della predetta Commissione⁴⁸, è stata approvata⁴⁹ in prima lettura dal Senato nel febbraio del 2009 tramite le cure del proponente senatore Laurent Bételle, Governo favorevole, con lo scopo in realtà di limitare l'ambito della mediazione⁵⁰.

All'epoca era Guardasigilli Rachida Dati che sollecitò in un primo tempo il rapporto Guinchard e appoggiò poi l'operazione della *procédure participative* nel tentativo di farsi perdonare: nel 2008 il Ministro ebbe, infatti, a subire una massiccia mobilitazione di magistrati, avvocati e amministratori locali, tutti uniti contro la sua riforma che sopprimeva più di trecento giurisdizioni in Francia⁵¹.

Il Guardasigilli sotto cui vennero invece approvati i provvedimenti di legge⁵² che introdussero l'istituto (in vigore dal 23 gennaio 2012) fu Michel Mercier.

L'attuale Ministro della Giustizia, Christiane Taubira, è invece assolutamente favorevole alla mediazione⁵³, tanto che vuole introdurre la mediazione familiare obbligatoria per tutti i rapporti familiari⁵⁴.

Il *Conseil national des barreaux* (CNB) tramite Jean-Marie Burguburu il suo presidente, al contrario vorrebbe⁵⁵ che si estendesse la negoziazione assistita come condizione di procedibilità a tutte le materie compresa quella familiare⁵⁶.

Gli esiti della *procédure participative* peraltro non confortano le pretese vantate dal CNB⁵⁷: nel 2013 secondo un rapporto del Senato francese del 2014, sono state richieste solo 7 omologazioni di *procédure*

⁴⁸ Non per gli organismi di mediazione.

Cfr. http://fr.wikimeditation.org/images/9/95/CPMN_Communique_23mars2009.pdf

⁴⁹ Proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées

⁵⁰ http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_B%C3%A9teille

⁵¹ http://fr.wikimeditation.org/images/9/95/CPMN_Communique_23mars2009.pdf;

http://it.wikipedia.org/wiki/Rachida_Dati

⁵² Art. 37 della legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 che ha introdotto gli articoli che vanno da 2062 a 2067 del Codice civile; art. 2 del Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 - art. 2 Titolo II del libro V: Il processo partecipativo (articoli 1542-1564).

⁵³ Nel paese transalpino esiste peraltro già la mediazione obbligatoria in sede sperimentale e sino al dicembre 2014 qualora si invochi la revisione delle modalità per l'esercizio della potestà dei genitori o del contributo al mantenimento e all'educazione del bambino. Evidentemente il Ministro vuole estendere la mediazione familiare obbligatoria avendo dato la stessa buoni frutti.

⁵⁴ Cfr. <http://mediaresenzaconfini.org/2014/09/10/che-cosa-pensa-il-ministro-della-giustizia-francese-della-mediazione/>

⁵⁵ <http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-avocats-doivent-proposer-des-forfaits-11-02-2014-3578877.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F>

La stima degli avvocati in Francia non è stata mai così bassa.

Il 4 aprile 2014 un deputato, Mr. Damien Abad, si è posto il problema di capire ed ha fatto una interrogazione parlamentare sul punto, se non sia possibile che una persona depositi un ricorso al Tribunale di Grande istanza (il nostro tribunale) senza assistenza legale visto che né la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, né la convenzione europea dei diritti dell'uomo richiamano la necessità dell'assistenza legale. Cfr. sul punto <http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53052QE.htm>

⁵⁶ In Francia la negoziazione assistita è assolutamente volontaria.

⁵⁷ Dobbiamo dire però che da ultimo il CNB si è dimostrato "imparziale". "L'avocat, acteur des modes amiables de résolution des différends" è un brochure che il CNF francese (CNB) ha preparato nell'ottobre del 2014 per divulgare la cultura dei MARC (così chiamano gli ADR in Francia). Si spiega ad esempio che ci sono ben dieci buone ragioni per andare in mediazione e farsi accompagnare da un avvocato. Che circa l'84% delle imprese che hanno partecipato ad una mediazione (Rapporto Magendie)

participative; ma anche le transazioni tra avvocati che sono possibili in Francia dagli anni '90 hanno avuto soltanto 115 richieste di omologazione⁵⁸.

Mi sono intrattenuto sulle vicende storiche transalpine più recenti in buona sostanza per far comprendere che la stagione della negoziazione assistita in Francia si è sostanzialmente conclusa dopo soli due anni di vigenza contrariamente ad illustri e trionfalistiche opinioni (FRICERO) che avevano affermato “*Cet objectif conduira à une déjudiciarisation de certains contentieux de masse, et la matière familiale en est une illustration topique !*”.

Il 4 giugno 2014 il Ministero della Giustizia della Francese ha pubblicato una sintesi di contributi degli avvocati, cancellieri dei tribunali di commercio, degli ufficiali giudiziari e dei notai sulla giustizia nel 21° secolo.

In tale documento i rappresentanti degli avvocati, dei notai e degli ufficiali giudiziari evidenziano la necessità di una sorta di assicurazione per i cittadini che ricomprenda una consulenza legale più una mediazione o conciliazione preventiva obbligatoria e gratuita. Nessuno parla più di negoziazione assistita⁵⁹.

La scuola di mediazione del *Bar Paris* del resto gli dedica la miseria di tre ore nell'ambito del suo corso di 25 ore rivolto agli assistenti avvocati⁶⁰ e questo è un eloquente quanto negativo sintomo.

La responsabilità del fallimento viene imputata secondo alcuno al fatto che la legge non prevede in Francia una disciplina della riservatezza, ma i suoi limiti vanno pattuiti in convenzione⁶¹, secondo altri al fatto che i clienti degli avvocati francesi preferiscono che sia il giudice a fissare l'importo delle parcelle dei

si sono dichiarate soddisfatte. Che il 99% degli accordi in mediazione hanno avuto esecuzione spontanea. Che la presenza dell'avvocato favorisce gli accordi per il 50%. Che in Francia ci sono ben 64 centri di mediazione gestiti dall'avvocatura. Questa apertura alla mediazione è forse dovuta al fatto che a prescindere dalla parificazione di legge e dalle direttive del Governo, il CNB ha dovuto tener conto dei dati disastrosi sulla n.a. e di uno Studio. L'Istituto IPSOS su richiesta del Consiglio Nazionale Forense di Francia (CNB), ha realizzato uno studio (cfr. <http://blogcdcl.wordpress.com/>) per conoscere gli usi delle società in materia di ADR e le loro esigenze e aspettative.

I risultati sono stati i seguenti:

- I conflitti sono legati a una violazione del contratto e coprono il 96% delle PMI
- Un terzo delle PMI ha incontrato nel corso degli ultimi tre anni un conflitto relativo a una violazione del contratto
- La disponibilità ad una risoluzione amichevole è indiscutibile, ma le aziende non rinunciano al processo
- Una risoluzione deve essere veloce e contribuire a mantenere le relazioni
- Solo una società su 10 ha utilizzato l'ADR
- Le aziende, una volta informati sono interessate a verificare i benefici: velocità, efficienza, mantenimento delle buone relazioni e basso costo
- Alla fine dell'intervista il 72% delle imprese ha previsto di inserire una clausola nel loro contratto per obbligarsi all'uso di un ADR

[http://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/199905791718/\[CNB\]_Justice_21eme_siecle_-_Modes_amiabiles_de_resolution_des_differends_\[oct._2014\].pdf](http://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/199905791718/[CNB]_Justice_21eme_siecle_-_Modes_amiabiles_de_resolution_des_differends_[oct._2014].pdf)

⁵⁸ <http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4045.html>

⁵⁹

Synthesis des contributions des professions d'avocats, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice et notaires sur la Justice du XXIème siècle. In

<http://www.justice.gouv.fr/publication/justice21-synthese-contributions-professions.pdf>

⁶⁰ http://dl.avocatparis.org/Ecole_Mediation/pdf/170913_EdlM-Programme-A4-septembre-PRINT.pdf

⁶¹ Jerome Bônard. *Les nouveaux privileges des avocats: fiducie, convention de procédure participative, acte privé contresigné* op cit.

loro avvocati e non vedono dunque di buon occhio la pattuizione delle competenze che va effettuata in convenzione.

Gli stessi COA nostrani peraltro non si sono sino ad ora impegnati particolarmente nella diffusione dello strumento italiano, ossia della negoziazione assistita, prediligendo invece la formazione in materia arbitrale.

mediaresenzaconfini.org

2.2 Uno sguardo comparato

Del resto se allarghiamo lo sguardo comparatistico osserviamo che le procedure gestite autonomamente da avvocati non hanno dato, perlomeno negli ultimi cinquanta anni, risultati positivi: è a tutti noto ad esempio come la *discovery* statunitense sia stata sottratta agli avvocati negli anni '80 e posta sotto il controllo del giudice anche a motivo degli alti costi che generava⁶².

Tanto meno ci sono stati in Europa risultati degni di nota quando si è trattato di procedure costruite come condizioni di procedibilità e con omologazione del giudice, come nel caso della negoziazione assistita italiana odierna: si è fatta la prova in Grecia già nel 1995 (*Απόπειρα εξώδικης επίλυσης*⁶³) ed in Romania nel 2000 (*Conciliere directă*)⁶⁴, ma i risultati sono stati fallimentari⁶⁵ e perlomeno in Romania, nel tentativo di rilanciare un istituto che appunto coinvolgeva gli avvocati, si è pensato alla fine di inviarli in alternativa, in mediazione⁶⁶. In Grecia si è introdotto in particolare un tentativo obbligatorio preventivo⁶⁷ per i procedimenti di diritto privato che rientrano in funzione della loro materia nella giurisdizione del tribunale collegiale di primo grado e per i quali il diritto sostanziale consente la conciliazione⁶⁸.

Quando registra l'atto iniziale del procedimento e fissa la data dell'udienza, il cancelliere appone, sull'originale e sulle copie, un timbro leggibile recante l'indicazione che l'udienza avrà luogo soltanto previo tentativo di "soluzione extragiudiziale della controversia"⁶⁹.

La convocazione in udienza deve comprendere anche l'invito al convenuto a presentarsi presso l'ufficio dell'avvocato o del collegio di avvocati del ricorrente in un determinato giorno e ora, per cercar di giungere alla risoluzione extragiudiziale della controversia.

La parte così convocata deve presentarsi accompagnata dal proprio avvocato o deve essere rappresentata da un avvocato munito di procura.

⁶² In oggi peraltro i costi sono rimasti e dunque si è introdotta quella telematica.

⁶³ 214 A C.p.c. (Tentativo di transazione giudiziaria).

⁶⁴ Art. 720 C.p.c.

⁶⁵ Cfr. per la Grecia http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gre_it.htm

Per la Romania v. ad es. *Concilierea directă*, procedura obligatorie dacă vrei să-ți obții banii de la debitori în instanță in <http://jurefani.wordpress.com/2012/03/05/concilierea-directa-procedura-obligatorie-daca-vrei-sa-ti-obtii-banii-de-la-debitori-in-stanta/>

⁶⁶ Art. 42 Legea 202/2010.

⁶⁷ Art. 214 A che è entrato in vigore nel 2000 e che è stata modificato nel 2002.

⁶⁸ "1. Αγωγές, που έχουν ως αντικείμενό τους διαφορές ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία, για τις οποίες επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός, δεν μπορεί να συζητηθούν, αν δεν προηγηθεί απόπειρα "εξώδικης* επίλυσης"*, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων".

⁶⁹ "2. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης της αγωγής και τον ορισμό δικασίμου ο γραμματέας θέτει στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σφραγίδα ότι συζήτηση δεν επιτρέπεται αν δεν προηγηθεί απόπειρα "εξώδικης* επίλυσης της διαφοράς".

Gli avvocati possono stabilire di comune accordo un'altra data per tale incontro o rimandarlo a un altro giorno ed ora, stabilendo il luogo.

Gli incontri per la risoluzione extragiudiziale delle controversie si tengono nell'arco di tempo fra il quinto giorno dopo la notificazione del procedimento e il trentacinquesimo giorno prima della data stabilita per l'udienza⁷⁰.

Durante l'incontro le parti, accompagnate dai loro avvocati o rappresentate dagli avvocati ai quali hanno dato procura, e assistite se lo desiderano da una terza persona scelta di comune accordo⁷¹, esaminano l'intera controversia e l'eventuale replica del convenuto, senza esser vincolate dalle disposizioni del diritto sostanziale.

Nel caso si avvalgano di un terzo se il tentativo non riesce, in tutto o in parte, esso non può essere sentito in un successivo giudizio in qualità di testimone o di esperto o come consulente tecnico o non può essere autorizzato a partecipare causa a qualsiasi titolo⁷².

Le parti si servono di tutti i mezzi opportuni per accertare i fatti principali ed i punti sui quali vi è accordo o disaccordo, nonché le conseguenze accettate o contestate, nell'intento di giungere a una risoluzione reciprocamente accettabile della controversia, nella sua interezza o in parte.

Se giungono a una risoluzione integrale o parziale della controversia, si redige il verbale, che è esente da tributi, indicandovi i termini dell'accordo e, in particolare, la natura del diritto riconosciuto, l'importo della prestazione dovuta e l'eventuale termine di adempimento.

L'accordo si limita alla controversia in oggetto.

Inoltre, si determinano i costi previsti all'articolo 176 e seguenti del CPC.

Il verbale viene datato e firmato dalle parti o dai loro avvocati, nel numero di originali equivalente al numero delle parti o gruppi di parti⁷³.

⁷⁰ "3. Στην κλήση για συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνεται και πρόσκληση προς τον εναγόμενο να προσέλθει στο γραφείο του δικηγόρου του ενάγοντος ή στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου του τελευταίου ορισμένη ημέρα και ώρα, με αντικείμενο την απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. Αν η επίσκεψη γίνεται από τον εναγόμενο ή από άλλο διάδικο, αυτός προσκαλεί τον αντίδικο στο γραφείο του δικηγόρου του ή στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου του τελευταίου. Ο προσκαλούμενος οφείλει να παραστεί με δικηγόρο ή να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο εφοδιασμένο με την κατά το άρθρο 98 ειδική πληρεξουσιότητα. Στη συνάντηση μπορεί να κληθεί και ο τυχόν προσεπικαλούμενος. Οι δικηγόροι μπορούν από κοινού να ορίσουν άλλη ημερομηνία συνάντησης ή να αναβάλλουν τη συνάντηση για άλλη ημέρα και ώρα σε ορισμένο τόπο. Οι συναντήσεις για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς πραγματοποιούνται μέσα στο χρονικό διάστημα από την πέμπτη ημέρα μετά την επίδοση της αγωγής έως την τριακοστή πέμπτη ημέρα πριν από τη δικάσιμο."

⁷¹ Si tratta dunque di un tentativo di conciliazione anche senza la presenza di un terzo, o addirittura di una negoziazione tra avvocati.

⁷² "4. Κατά τη συνάντηση οι διάδικοι με τους δικηγόρους τους ή εκπροσωπούμενοι από τους πληρεξουσικούς δικηγόρους τους, επικουρούμενοι, εφόσον το επιθυμούν, και από τρίτο πρόσωπο κοινής επιλογής, εξετάζουν ολόκληρη τη διαφορά καθώς και την τυχόν ανταγωγή του εναγομένου, χωρίς να δεσμεύονται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Χρησιμοποιούν όλα τα πρόσφορα μέσα για να εξακριβώσουν τα κρίσιμα περιστατικά και τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας τους, καθώς και τις συνέπειες που δέχονται ή αμφισβητούν, ώστε να επιτύχουν αμοιβαίως αποδεκτή λύση της διαφοράς, εν όλω ή εν μέρει. Το τρίτο πρόσωπο κοινής επιλογής που μετέσχε τυχόν στη συνάντηση, έστω και σε μέρος της, αν η απόπειρα αποτύχει εν όλω ή εν μέρει και ακολουθήσει συζήτηση της διαφοράς, δεν εξετάζεται ως μάρτυρας ούτε μπορεί να οριστεί ως πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος ούτε επιτρέπεται να μετάσχει στην εκδίκαση με οποιαδήποτε ιδιότητα."

Ogni parte può presentare il proprio originale del verbale al presidente del tribunale collegiale di primo grado presso il quale è pendente il caso, e chiederne la omologa.

Il presidente omologa il verbale dopo aver accertato che: a) la controversia può essere risolta in via "extragiudiziale" ai sensi del paragrafo 1; b) il verbale è stato firmato a norma di legge; c) nel verbale sono indicati con chiarezza il diritto riconosciuto e l'eventuale importo della prestazione dovuta.

Se la controversia comprende anche la richiesta di rigetto della domanda della parte avversa, la ratifica del verbale costituisce titolo esecutivo e il presidente emana contemporaneamente l'ordine di esecuzione.

Se l'obiettivo era esclusivamente una pronuncia pregiudiziale, nel verbale viene indicato il diritto riconosciuto. In ogni caso la ratifica del verbale comporta l'estinzione del processo⁷⁴.

Se non si raggiunge un accordo, viene redatto e firmato il verbale dell'insuccesso del tentativo di "soluzione alternativa alla controversia", nel quale si possono indicare anche i motivi.

Se non viene firmato un verbale comune, l'avvocato del ricorrente o di un'altra parte diligente redige una dichiarazione, nella quale si possono indicare anche i motivi dell'insuccesso.

Una dichiarazione analoga può essere redatta anche dall'avvocato della parte avversa.

Il verbale o le dichiarazioni riguardanti l'insuccesso vengono depositati durante l'udienza assieme alle conclusioni.

In caso di accordo parziale non è richiesta la stesura di un verbale specifico o di dichiarazioni⁷⁵.

Purtroppo questo tipo di ΕΤΕΔ non ha dato grandi risultati, ovvero non ha dato luogo a molti accordi extragiudiziali.

Altra esperienza che richiama la soluzione approntata dall'Italia è appunto quella rumena.

Ma anche qui le cose non sono andate come preventivato.

La legislazione rumena⁷⁶ prevede l'istituto della "conciliazione diretta" tra le parti nelle controversie commerciali.

⁷³ "5. Αν οι διάδικοι καταλήξουν σε ολική ή μερική λύση της διαφοράς, συντάσσεται ατελώς πρακτικό στο οποίο αναγράφεται το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και οι τυχόν όροι υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί. Η συμφωνία περιορίζεται στα όρια της ένδικης διαφοράς. Καθορίζονται επίσης και επιβάλλονται τα έξοδα κατά τις διατάξεις των άρθρων 176 επ.. Το πρακτικό χρονολογείται και υπογράφεται από τους διαδίκους ή από τους δικηγόρους τους, αν έχουν την κατά το άρθρο 98 ειδική πληρεξουσιότητα, σε τόσα αντίτυπα όσοι οι αντιδικούντες διάδικοι ή ομάδες διαδίκων".

⁷⁴ "6. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή, την επικύρωσή του. Ο πρόεδρος αφού διαπιστώσει: α) ότι η διαφορά είναι δεκτική "εξώδικης" επίλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, β) ότι το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και γ) ότι από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το τυχόν ποσόν της οφειλόμενης παροχής, επικυρώνει το πρακτικό. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό από την επικύρωση του αποτελεί τίτλο εκτελεστό και ο πρόεδρος το περιάπτει ταυτόχρονα με τον εκτελεστήριο τύπο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης. Αν η επικυρούμενη συμφωνία καλύπτει μέρος της διαφοράς, η κατάργηση της δίκης επέρχεται μόνο κατά τούτο."

⁷⁵ Art. 214 A commi 7-11.

L'art. 109 del Codice di procedura civile della Romania stabilisce che chi rivendica un diritto contro un'altra persona deve fare una richiesta davanti al giudice competente. Nei casi specificatamente previsti dalla legge però la citazione al giudice competente può essere operata solo dopo il compimento di una procedura preliminare, alle condizioni stabilite da tale legge.

La prova della procedura preliminare deve essere allegata alla citazione.

Un caso specifico che necessita la procedura preliminare è stato inserito con il decreto n. 138/2000, che ha appunto introdotto l'art. 720¹⁷⁷ C.p.c., a tenore del quale rapporti commerciali in contestazione, quando sono suscettibili di valutazione pecuniaria, devono essere preventivamente risolti attraverso la conciliazione diretta (*conciliere directa*) con l'altra parte.

La *conciliere directa* in sostanza di una specie di *discovery* obbligatoria: il richiedente s'incontra con la parte avversa che lo informa per iscritto delle domande giudiziali che svolgerà e della loro base giuridica, e di tutti i documenti che li supportano.

L'incontro vero e proprio di conciliazione avviene decorsi 15 giorni da tale scambio.

La conciliazione intervenuta si formalizza un documento scritto che mostra i crediti reciproci in materia e punto di vista di ciascuna parte.

Va ribadito che la legge 202/10 da ultimo introduce sempre nel caso dei rapporti commerciali l'alternatività con la mediazione che a questo punto diviene, in quanto eletto nel caso, uno strumento obbligatorio⁷⁸.

E dunque il legislatore rumeno ha deciso di potenziare l'incontro delle parti inserendo la presenza di un terzo neutrale.

⁷⁶ Che per quanto riguarda la gestione delle controversie è mutata ultimamente con un importante provvedimento: Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor. Legea 202/2010 Mica reforma a Justiției. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010 (Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I nr. 714 del 26 ottobre 2010. Piccola riforma della giustizia).

⁷⁷ A *modifica ed integrazione del Codice di Procedura Civile (Codul de procedura civila)*.

⁷⁸ Art. 42 Legea 202/2010.

2.3 La procédure participative, la negoziazione e le tecniche di comunicazione

Per i motivi sostanziali e procedurali che emergono dal testo normativo francese peraltro il processo partecipativo è istituito altamente specialistico e necessita in altre parole di adeguata preparazione su più versanti.

Va valutato e affrontato attentamente il processo negoziale, ma pure le conseguenze nel caso di accordo parziale, di mancato accordo e di inesecuzione della convenzione partecipativa.

La procedura partecipativa non coincide, in altre parole, con la semplice omologazione di una transazione tra avvocati che è presente peraltro in Francia da parecchi anni e pure in altri paesi europei come ad esempio la Germania.

È qualcosa di profondamente diverso ed in Francia non sembra in particolare uno strumento alla portata dei novelli avvocati: la negoziazione partecipativa presuppone eccellenti nozioni di diritto, ma pure una spiccata esperienza processuale. E ciò perché nel caso di insuccesso, parziale o totale, delle trattative la procedura potrebbe facilmente costituire un primo grado di giudizio⁷⁹.

La negoziazione francese, in altre parole, prevede due fasi: 1) negoziazione tra le parti in base alla convenzione stipulata liberamente e accordo o mancato accordo o accordo parziale 2) omologazione per accordo e giudizio per mancato accordo o per accordo parziale partendo non dagli atti introduttivi delle parti, ma dalla stipulata convenzione a cui sono allegati i documenti che le parti ritengono pertinenti. Questo percorso destinato dunque a legali esperti richiede altresì in loro un cambiamento di mentalità.

Unitamente alla mediazione civile e commerciale la procedura partecipativa prende, infatti, a piene mani “le sue regole non scritte” dalla negoziazione e dunque l’assistente nella procedura partecipativa non si possono permettere di ignorarle.

Ciò è detto a chiare lettere in una intervista da Natalie Fricero⁸⁰, docente ordinario dell’Università di Nizza, che è stata membro anziano della Commissione Guinchard.

In sostanza l’accademica spiega che per fruire della negoziazione assistita l’avvocato deve formarsi in tecniche di comunicazione e negoziazione e deve essere addestrato ad andare in mediazione.

A commento di questa intervista Dominique Lopez, uno dei più importanti avvocati negoziatori di Francia⁸¹ scrive quanto segue: *“Fort bien, qu’ils le soient est toujours un plus pour négocier, c’est vrai mais si en face l’autre avocat n’est pas formé car il n’en a nulle obligation, il sera très dur d’arriver à un accord qui ne soit pas une concession réciproque au sens juridique du terme? C’est donc perdre une chance d’avoir votre solution optimale et encore faut-il que l’avocat non formé à ces techniques ne*

⁷⁹ Cfr. art. 1561 e 1562 C.p.c.

⁸⁰ http://www.youtube.com/watch?v=_OOEFY-9ZNs

⁸¹ Cfr. <http://www.cyber-avocat.com/CaFamille/Equipe.asp>

s'arcaboute pas naturellement sur une défense légitime mais axée uniquement sur les positions de base de son client. Ce ne sera que temps perdu et personne n'en sortira gagnant".

Nello stesso senso si è espresso Laurence Junod-Fanget, avvocato in Lione e Présidente de la commission des Modes amiables de résolution des différends: *"L'avocat formé à la négociation - Initialement formé au droit, à la rédaction d'actes juridiques et/ou judiciaires ainsi qu'à la plaidoirie, l'avocat apprend aussi les techniques d'entretien et de négociation. Cela est particulièrement utile dans les conflits familiaux. Une séparation est une période délicate, faite de doutes, de désarroi, de fragilité psychologique et, pourtant, des décisions doivent être prises sur les plans extrapatrimonial et patrimonial".*

Insomma o gli avvocati sono preparati in tecniche di negoziazione e comunicazione oppure se si parla solo di posizioni giuridiche la negoziazione assistita si traduce in una mera perdita di tempo.

mediarensenzaconfini.org

2.4 La disciplina in generale

La disciplina civilistica della *procédure participative* doveva entrare in vigore al più tardi attraverso la normativa di dettaglio il 1° settembre 2011⁸²; in realtà le norme regolamentari non sono mai state varate e sono andate a regime le sole norme processuali a fine gennaio 2012⁸³; l'art. 2068 C.c. dispone, infatti, espressamente che la procedura partecipativa è disciplinata dal Codice di procedura civile.

Si ritiene in oggi che siano entrate in vigore dal 23 gennaio 2014 soltanto le norme di chiara e precisa interpretazione.

Il legislatore a fine 2010 ha inserito dunque il titolo XVIII al libro terzo del Codice Civile: "Della convenzione di procedura partecipativa".

La convenzione di procedura partecipativa è un accordo mediante il quale le parti di una controversia che non ha ancora visto l'intervento di giudice o di un arbitro si impegnano ad operare congiuntamente ed in buona fede per risolvere amichevolmente la loro controversia⁸⁴. L'accordo è a tempo determinato⁸⁵.

La norma stabilisce dunque espressamente che la controversia non deve aver visto l'intervento del giudice o dell'arbitro.

La dottrina (FRICERO) fa notare che l'avvocato è tenuto a controllare che non vi sia depositato in tribunale un atto introduttivo con riferimento a quella data controversia, ma che sarebbe possibile ottenere in via di arbitrato una misura provvisoria o un *expertise*.

Le parti devono essere dunque disposte a raggiungere un accordo insieme.

Quando le parti sottoscrivono un impegno CPP, di fatto, fanno tutto il possibile per cercare di risolvere la loro controversia in via amichevole, da qui l'esigenza in primo luogo per loro di cercare lealmente una strada per il raggiungimento di un accordo (JUNOD-FANGET').

Il codice di procedura civile aggiunge che la p.p. "*Si traduce in una procedura convenzionale per raggiungere un accordo e, se del caso, per proseguire in sede giudiziaria*"⁸⁶.

Come abbiamo accennato nella procedura convenzionale al fine di raggiungere un accordo può trovare spazio anche l'intervento di un tecnico (articoli 1544-1555 del Codice di rito).

⁸² V. art. 43 legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010.

⁸³ La *procédure participative* est régie par le code de procédure civile.

⁸⁴ La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Art. 2062 c. 1 C.c.

⁸⁵ Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Art. 2062 c. 2 C.c.

⁸⁶ Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Art. 1543 C.p.c.

Quanto allo sbocco giudiziario in Francia esiste già una “procedura ai fini del processo” (*procédure aux fins de jugement*) in difetto di conciliazione davanti al *Tribunal d’instance* e alla *juridiction de proximité*.

⁸⁷.

In sostanza in caso di fallimento totale o parziale del tentativo preventivo di conciliazione, il richiedente può adire il giudice in sede contenziosa in base a tutte o a parte delle domande originarie⁸⁸. Il ricorso al giudice è fatto secondo le modalità previste dall'articolo 829⁸⁹.

Per intendere la procedura partecipata *aux fins de jugement* – la cui disciplina è contenuta negli articoli del Codice di rito che vanno dal 1556 al 1564 – si deve comprendere che in buona sostanza le parti definiscono già con la convenzione partecipativa e/o con l’accordo, totale o parziale, l’oggetto del giudizio davanti al giudice competente per la misura.

Il mondo processuale rimane cioè cristallizzato in base alle vicende extraprocessuali: solo alcuni fatti qualificati (pagamento, compensazione, aggiornamenti di contratti ad esecuzione differita) successivi alla stipula della convenzione o dell’accordo possono mutare il quadro processuale.

La dottrina francese (JUNOD-FANGET⁹⁰) parla a questo proposito di un processo ibrido nel quale la libertà contrattuale si coniuga con la difesa dei diritti, del contraddittorio, della parità delle forze, del diritto ad una difesa di qualità⁹¹.

Il giudizio è assicurato dal legislatore francese per la omologazione dell’accordo totale o parziale, in caso di mancato accordo, totale o parziale e infine nella ipotesi di inesecuzione della convenzione che appunto legittima l’azione giudiziaria.

Ma torniamo alla disciplina sostanziale. Gli estremi della convenzione di procedura partecipativa sono contenuti, a pena di nullità, in un atto scritto che deve precisare:

- 1) il termine
- 2) l’oggetto della controversia
- 3) L’indicazione dei documenti e delle informazioni necessarie per risolvere la disputa e le condizioni del loro scambio⁹².

⁸⁷ L’art. 829 C.p.c. recita appunto « à fin de conciliation et, à défaut, de jugement ».

⁸⁸ Art. 836 c. 1 C.p.c. novellato.

⁸⁹ Art. 836 c. 2 C.p.c. novellato. La domanda giudiziale viene formata ai fini della conciliazione o in difetto del giudizio, fermo restando che si può sempre chiedere la promozione del tentativo di conciliazione.

La domanda può anche essere formata attraverso una dichiarazione da depositarsi congiuntamente nella segreteria del Giudice oppure a seguito di presentazione volontaria davanti al giudice.

⁹⁰ Président de la commission des Modes amiables de résolution des différends.

⁹¹ Ainsi, la CPP engage les parties dans un processus hybride alliant la souplesse contractuelle tout en respectant les droits fondamentaux du justiciable (accès au juge préservé, droit à l’égalité des forces, droit à une justice de qualité, protection des droits de la défense, respect du principe du contradictoire...). Cfr. in materia il dossier FAMILLE ET PROCÉDURE PARTICIPATIVE in http://cnb.avocat.fr/docs/egdf/egdf10/docs/dalloz/12-procedure-participative/AJfam_2013-535.pdf

⁹² La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise:

1° Son terme ;

2° L’objet du différend ;

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. Art. 2063 C.c.

La dottrina (JUNOD-FANGET') sottolinea che il primo elemento da affrontare è l'oggetto che deve essere costruito dagli elementi di accordo e di disaccordo su cui gli avvocati devono essere molto rigorosi: lo scambio di argomenti giuridici consente di valutare tutti i punti di vista e di trovare dei criteri oggettivi per risolvere equitativamente la controversia (ossia quanto richiesto dal punto 3 dell'art. 2063 c.c.); in seconda battuta ed in relazione appunto agli elementi di disaccordo si stabilisce il termine che può essere anche prorogato in relazione al fatto che pure l'oggetto può subire modifiche durante la procedura.

Sarebbe opportuno (FRICERO) stabilire anche un calendario delle varie fasi della trattativa.

L'oggetto merita grande attenzione intanto perché deve riguardare la totalità degli aspetti (ad esempio in materia di autorità parentale deve concernere sia gli aspetti patrimoniali, sia quelli extrapatrimoniali), ma soprattutto perché può riguardare soltanto diritti disponibili (art. 2064⁹³) e non è sempre facile distinguerli dagli indisponibili; ad esempio non è disponibile la delega della genitorialità, ma sono disponibili le condizioni di esercizio della autorità parentale oppure può essere disponibile l'utilizzo del nome patronimico.

In Italia si potrebbe pensare, tra gli altri, che siano indisponibili i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), i diritti personalissimi (diritto al nome, all'identità, diritti politici), l'impugnazione di delibera di approvazione del bilancio, il riconoscimento di paternità naturale, le controversie con la P.A. in materia di scelta del contraente⁹⁴.

Altro motivo e non certo l'ultimo per cui la precisione dell'oggetto è fondamentale risiede nel fatto che se le parti a seguito del fallimento delle trattative decidono di adire il *tribunal de grand instance* (il nostro tribunale) gli sono precluse modifiche (art. 1561⁹⁵).

Circa l'oggetto si può aggiungere che è necessaria una certa trasparenza nella trasmissione dei documenti fondamentali per il buon esito della procedura. L'avvocato però deve essere garantito del fatto che venga rispettata la riservatezza e allora la dottrina (FRICERO) suggerisce di utilizzare per lo scambio delle *Data room*, ossia dei sistemi che non consentono di stampare, né di riprodurre quanto a video.

La riservatezza peraltro è un'altra delle cose di cui bisogna decidere il carattere: può essere parziale o totale, e riguardare cioè convenzione, documenti scambiati e anche l'accordo. Dal punto di vista

⁹³ Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

⁹⁴ D. PISELLI, *La negoziazione assistita da avvocato*, Impresa e Società, in <http://www.ilcaso.it/>

⁹⁵ Article 1561 C.p.c.

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.

Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieure ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

deontologico è possibile scambiare anche le missive che sono rivolte al proprio cliente o quelle che sono rivolte a colleghi, ma non è possibile scambiare documenti coperti dal segreto professionale⁹⁶.

L'avvocato deve pure stare attento che nei verbali interlocutori non vengano immesse informazioni che ledano il principio di riservatezza.

In convenzione va previsto poi anche l'onorario dell'avvocato, perché in questo caso non è fissato dal giudice. È ammesso nella procedura anche il gratuito patrocinio⁹⁷.

Il termine stabilito dalle parti produce poi degli effetti importanti.

La prescrizione estintiva del diritto è sospesa dalla firma della convenzione fino al fallimento constatato e datato⁹⁸; nel qual caso il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal termine della convenzione, per un tempo che non potrà essere inferiore ai sei mesi⁹⁹. Il che significa che il termine eventualmente trascorso prima della firma non viene cancellato come in caso di interruzione.

Il Codice di rito aggiunge alcuni elementi in relazione alla procedura partecipativa convenzionale: *“Oltre a quanto menzionato dall'art. 2063 C.c., la convenzione di procedura partecipativa menziona i nomi, i cognomi, e gli indirizzi delle parti e dei loro avvocati.”*¹⁰⁰

La dottrina (FRICERO) rileva che sarebbe opportuno allegare anche la fotocopia della carta di identità delle parti e l'estratto K bis¹⁰¹ per le persone giuridiche.

Sempre la legge precisa che la comunicazione delle memorie e dei documenti tra le parti avviene tramite i loro avvocati secondo le modalità previste dalla convenzione, che li porta a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo. Una ricevuta viene apprestata quando un documento sarà comunicato¹⁰².

Qualsiasi persona, assistita dal suo avvocato, può concludere una convenzione di procedura partecipativa a condizione che i diritti siano disponibili, fatte salve le disposizioni della sezione 2067¹⁰³, ossia quelle che

⁹⁶ Cfr. art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971.

⁹⁷ Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. Art. 10 c. 2 Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Prévoir les modalités de paiement des honoraires de l'avocat - En l'absence de juge taxateur, les parties doivent organiser la répartition des frais de la procédure dès la convention. L'aide juridictionnelle est prévue par l'art. 10 de la loi n° 91-647 du 10 juill. 1991. L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un accord dans le cadre d'une procédure participative est régie par les art. 118-2 à 118-8 du décret du 19 déc. 1991. Le règlement type pris pour l'application de l'art. 29 de la loi du 10 juill. 1991, annexé au décret n° 96-887 du 10 oct. 1996 et modifié par le décret n° 2012-350 du 12 mars 2012, précise les modalités pratiques permettant la rétribution finale de l'avocat (FRICERO).

⁹⁸ La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. Art. 2238 c. 1 ultima parte C.c.

⁹⁹ En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Art. 2238 c. 2 ultima parte C.c. Si tratta di una norma decisamente incentivante.

¹⁰⁰ Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. Art. 1545 c. 1 C.p.c.

¹⁰¹ Rappresenta la carta di identità delle società (sarebbe il nostro certificato camerale). Cfr. <https://www.infogreffe.fr/societes/documents-officiels/demande-kbis.html>

¹⁰² La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée. Art. 1545 c. 2 C.p.c.

attengono alla separazione ed al divorzio, materie nelle quali comunque è possibile utilizzare la procedura, ma non vi sono le conseguenze che poi vedremo in caso di mancato raggiungimento di un accordo.

In sostanza per quanto riguarda le convenzioni in materia di separazione e divorzio esse sono incardinate nel processo di famiglia e richiedono la celebrazione del tentativo di conciliazione.

Si tratta dunque di una procedura con assistenza legale obbligatoria.

Ciò è ribadito anche dall'art. 1544 del Codice di rito nella Sezione I, e dunque in relazione alla procedura partecipativa convenzionale: «*Le parti, assistite dai loro avvocati, ricercano congiuntamente, alle condizioni fissate dalla convenzione, un accordo che metta fine alle differenze che li oppongono*»¹⁰⁴.

Ciò comporta una particolare responsabilità per l'avvocato come evidenzia FRICERO¹⁰⁵, che è sancita in Francia dalla legge: "l'avvocato redattore di un atto giuridico assicura la validità e la piena efficacia dell'atto secondo le previsioni delle parti. Egli deve rifiutare di partecipare alla redazione di un atto o di un accordo manifestamente illecito o fraudolento".

La dottrina francese (JUNOD-FANGET) precisa che nella procedura partecipativa l'avvocato che sia abituato a negoziare rafforza il proprio ruolo e il giudice mantiene il proprio di terzo imparziale che risolve le controversie e provvede alla omologazione degli accordi.

Tale procedura non può però essere utilizzata nella materia del lavoro¹⁰⁶. Tuttavia al momento si sta discutendo un progetto di legge detto Macron¹⁰⁷ che modifica l'art. 83 del Codice del lavoro prevedendo l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2064 C.c. e dunque se verrà approvato si potrà procedere con la procedura assistita anche in materia di lavoro (contro l'adozione di questo progetto di legge il Tribunale del lavoro di Lione ha scioperato il 15 di gennaio¹⁰⁸).

¹⁰³ Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067. Art. 2064 c. 1 C.c.

¹⁰⁴ Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

¹⁰⁵ L'art. 7.2 du RIN (art. 9 du décret n° 2005-790 du 12 juill. 2005) permet de préciser les contours de leur responsabilité : «l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux ». N. FRICERO, *La convention de procédure participative: un cadre juridique adapté aux différends familiaux*, in Dossier Famille et procédure participative, ottobre 2013. http://www.dalloz-revues.fr/AJ_famille-cover-29993.htm

¹⁰⁶ Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Art. 2064 u.c. C.c.

¹⁰⁷ PROJET DE LOI pour la croissance et l'activité NOR : E1N1426821L/Bleue1
<https://www.contexte.com/documents/5745/le-projet-de-loi-macron.html#pages/p2>

¹⁰⁸ <http://www.lextimes.fr/6.aspx?sr=901>

Finché è in corso la procedura partecipativa, il giudice non può ricevere la domanda che richieda una pronuncia sulla controversia. Tuttavia l'inesecuzione della controversia legittima l'altra parte a ricorrere al giudice perché si pronunci¹⁰⁹.

Nei casi d'urgenza la convenzione non impedisce che le parti possano richiedere misure provvisorie¹¹⁰.

La procedura partecipativa convenzionale può essere modificata con le stesse forme con cui è stata costituita¹¹¹.

Le parti, a conclusione della procedura partecipativa, possono raggiungere un accordo su tutte o su alcune delle controversie e l'intesa può essere sottoposta all'omologazione del giudice¹¹².

Quando, non riuscendo a raggiungere un accordo con la procedura partecipativa, le parti presentano la loro controversia in tribunale, sono esentati dal preventivo tentativo di conciliazione o di mediazione, se previsto¹¹³.

Tale norma appare criticabile dal momento che la mediazione non agisce solo sul piano dei diritti, ma soprattutto su quello degli interessi e quindi la procedura di mediazione non può considerarsi equiparabile ad un contratto stipulato con l'assistenza dei legali e tantomeno ad un non accordo. Inoltre potrebbe aggiungersi che la mediazione o la conciliazione sono di ausilio proprio quando la negoziazione diretta od indiretta si sia rivelata inefficace.

Acutamente poi si fa notare che questa previsione pone nel nulla la clausola di mediazione che si fosse inserita nei contratti¹¹⁴.

¹⁰⁹ Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. Art. 2065 c. 1 C.c.

¹¹⁰ En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. Art. 2065 c. 2 C.c.

¹¹¹ La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Art. 1546 C.p.c.

¹¹² Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. (Art. 2066 c. 1 C.c.) Non si fa qui che riprendere la prassi vigente in materia di transazioni tra avvocati.

¹¹³ Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Art. 2066 c. 2 C.c.

¹¹⁴ http://fr.wikimeditation.org/images/9/95/CPMN_Communique_23mars2009.pdf

2.5 La procédure participative in materia di famiglia

Una convenzione di procedura partecipativa può essere raggiunta dai coniugi che siano in cerca di una soluzione consensuale di divorzio o di separazione¹¹⁵.

Ma non è applicabile l'art. 2066¹¹⁶ e dunque non si può pensare di andare esenti dal tentativo di conciliazione in caso di mancato accordo, ove esso sia previsto.

Esattamente la disciplina prevede quanto di seguito con riferimento alle procedure divorzili che non vengono richieste per mutuo consenso.

Un tentativo di conciliazione è obbligatorio davanti al giudice. Può essere rinnovato nel corso del procedimento (art. 252 c. 1).

Il giudice cerca di conciliare gli sposi tanto sul principio del divorzio quanto sulle sue conseguenze (art. 252 c. 2).

Quando il giudice cerca di conciliare gli sposi, deve intrattenersi personalmente con ciascuno separatamente prima della riunione in sua presenza (art. 252-1 c. 1).

Gli avvocati sono quindi invitati ad assistere e partecipare al colloquio (art. 252-1 c. 2).

Nel caso in cui il coniuge che non ha presentato la domanda non compare in udienza o non è in grado di esprimere la sua volontà, il giudice si intrattiene con l'altro coniuge e lo invita alla riflessione (art. 252-1 c. 3).

Il tentativo di conciliazione può essere sospeso e ripreso senza formalità, così da dare agli sposi un tempo di riflessione al massimo di 8 giorni (art. 252-2 c. 1).

Se un termine più lungo può essere utile, il giudice può decidere di sospendere il processo e di ricorrere ad un nuovo tentativo di conciliazione nel termine massimo di 6 mesi. Egli ordina, se è necessario, le misure provvisorie necessarie (art. 252-2 c. 2).

In Francia la domanda di divorzio o separazione legale presentata a seguito di una convenzione di procedura partecipativa è formata e giudicata secondo le norme inerenti al divorzio contenute nel titolo VI del libro I del Codice civile¹¹⁷.

In Francia il matrimonio può essere sciolto per morte di uno dei coniugi, per il divorzio legalmente pronunciato (art. 227).

Il divorzio può essere pronunciato in quattro ipotesi: nel caso di mutuo consenso, di accettazione del principio di rottura del matrimonio, nel caso di alterazione permanente della relazione coniugale, per colpa (art. 229).

¹¹⁵ Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. Art. 2067 c. 1 C.c.

¹¹⁶ L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. Art. 2067 c. 2 C.c.

¹¹⁷ La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce. Art. 2067 C.c. c. 2 ultima parte.

L'assistenza dei legali è necessaria quando si tratti di divorzio per accettazione del principio della rottura del matrimonio (art. 253).

L'alterazione permanente della relazione coniugale risulta dalla cessazione della comunione di vita tra gli sposi, che vivono separati nei due anni anteriori alla richiesta di divorzio (art. 238 c. 1).

Qualora uno degli sposi si trovi sotto un regime di protezione previsto dal capitolo II del titolo XI del codice civile, non può essere presentata domanda alcuna di divorzio per mutuo consenso o per accettazione del principio di rottura del matrimonio (art. 249-4).

La separazione può essere pronunciata nei medesimi casi e alle stesse condizioni del divorzio (art. 296); ma pone semplicemente fine al dovere di coabitazione (art. 299) e non a quello di soccorso (art. 303 c. 1), cosa che invece succede col divorzio (art. 270 c. 1).

La separazione porta sempre alla separazione dei beni (art. 302 c. 1), ma non allo scioglimento del matrimonio (art. 299).

Tutti i casi di separazione, potranno convertirsi in divorzio per mutuo consenso (art. 307 c. 1).

Quando la separazione è pronunciata per mutuo consenso, non potrà convertirsi in divorzio se non su domanda congiunta (art. 307 c. 2).

Trascrivo qui di seguito l'intera disciplina sostanziale del divorzio e della separazione in Francia¹¹⁸, così che si possa capire la portata della *procédure participative*

Libro primo: Delle persone¹¹⁹

Titolo VI: Del divorzio¹²⁰

Capitolo primo: Sui casi di divorzio¹²¹

Il divorzio può essere pronunciato in quattro ipotesi: nel caso di mutuo consenso, di accettazione del principio di rottura del matrimonio, nel caso di alterazione permanente della relazione coniugale, per colpa (art. 229)¹²².

¹¹⁸ Nella traduzione italiana operata dal sottoscritto

¹¹⁹ Livre Ier: Des personnes

¹²⁰ Titre VI: Du divorce

¹²¹ Chapitre Ier: Des cas de divorce

¹²² Article 229

Le divorce peut être prononcé en cas :

- soit de consentement mutuel ;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.

Sezione 1 : Del divorzio per mutuo consenso¹²³

Il divorzio per mutuo consenso può essere chiesto dai coniugi congiuntamente quando gli sposi sono d'accordo sulla rottura del matrimonio e sui suoi effetti e sottopongono all'approvazione del giudice una convenzione regolante le conseguenze del divorzio (art. 230)¹²⁴.

Il giudice omologa la convenzione e pronuncia il divorzio se acquisisce la convinzione della realtà della volontà dei coniugi e che il loro consenso è libero e chiaro (art. 232 c. 1)¹²⁵.

Il (giudice) può rifiutare l'omologazione e non pronunciarsi sul divorzio se verifica che la convenzione non protegge a sufficienza gli interessi dei minori o di uno degli sposi (art. 232 c. 2)¹²⁶.

Sezione 2 : Sul divorzio per accettazione (della rottura del matrimonio)¹²⁷

Il divorzio può essere domandato da uno o dall'altro degli sposi o da entrambi quando accettano la rottura del matrimonio indipendentemente dai fatti che l'hanno causata (art. 233 c. 1)¹²⁸.

Questa accettazione non è suscettibile di ritrattazione, nemmeno in caso di appello (art. 233 c. 2)¹²⁹.

Se acquisisce la convinzione che ciascuno dei coniugi hanno prestato liberamente il consenso, il giudice pronuncia il divorzio e statuisce sulle conseguenze (art. 234)¹³⁰.

Sezione 3 : Sul divorzio per alterazione permanente della relazione coniugale¹³¹

Il divorzio può essere domandato da uno degli sposi quando la relazione coniugale è alterata permanentemente (art. 237)¹³².

¹²³ Section 1: Du divorce par consentement mutuel

¹²⁴ Article 230

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

¹²⁵ Article 232

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

¹²⁶ Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

¹²⁷ Section 2: Du divorce accepté

¹²⁸ Article 233

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

¹²⁹ Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

¹³⁰ Article 234

S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

¹³¹ Section 3: Du divorce pour altération définitive du lien conjugal

L'alterazione permanente della relazione coniugale risulta dalla cessazione della comunione di vita tra gli sposi, che vivono separati nei due anni anteriori alla richiesta di divorzio (art. 238 c. 1)¹³³.

Nonostante le presenti disposizioni, il divorzio per alterazione permanente della relazione coniugale è pronunciato nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 246, in quanto la domanda su questa base si sia formata a titolo riconvenzionale (art. 238 c. 2)¹³⁴.

Sezione 4 : Sul divorzio per colpa¹³⁵

Il divorzio può essere domandato da uno degli sposi quando i fatti costitutivi di una grave violazione o rinnovata di diritti e obblighi del matrimonio sono imputabili ad un congiunto e rendono intollerabile il mantenimento della vita comune (art. 242)¹³⁶.

A partire dalla riconciliazione degli sposi è impedita l'invocazione dei fatti allegati come causa di divorzio (art. 244 c. 1)¹³⁷.

Il giudice dunque dichiara la domanda irricevibile. Tuttavia, un'altra domanda può essere formata in conseguenza di fatti sopravvenuti o scoperti dopo la riconciliazione, e i fatti più vecchi possono essere ripresi all'interno di questa nuova domanda (art. 244 c. 2)¹³⁸.

Il mantenimento o la ripresa temporanea della vita comune non possono essere considerati come una riconciliazione se questi sono risultanti dalla necessità o dagli effetti di una conciliazione o dai bisogni dell'educazione dei minori (art. 244 c. 3)¹³⁹.

Le colpe del coniuge che ha preso l'iniziativa del divorzio non impedisce l'esame della sua domanda; ma possono, tuttavia eliminare dalle colpe imputate all'altro coniuge quel carattere di gravità che le farebbero considerare cause di divorzio (art. 245 c. 1)¹⁴⁰

¹³² Article 237

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

¹³³ Article 238

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

¹³⁴ Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

¹³⁵ Section 4 : Du divorce pour faute

¹³⁶ Article 242

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

¹³⁷ Article 244

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

¹³⁸ Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

¹³⁹ Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

¹⁴⁰ Article 245

Queste colpe possono essere invocate dall'altro coniuge tramite domanda riconvenzionale di divorzio. Se le domande sono accolte, il divorzio è pronunciato per colpa parziale (art. 245 c. 2)¹⁴¹.

Anche in assenza della domanda riconvenzionale, il divorzio può essere pronunciato per il torto di uno degli sposi se dal dibattimento scaturiscono dei torti a carico di uno o dell'altro (art. 245 c. 3)¹⁴².

A domanda dei coniugi, il giudice può limitarsi a constatare che sussistono i fatti che sono causa di divorzio, senza dover indicare i torti o le rimozioni delle parti (art. 245-1)¹⁴³.

Se sono presentate concorrentemente una domanda per alterazione permanente della relazione coniugale ed una domanda per colpa, il giudice esamina per prima la domanda per colpa (art. 246 c.1)¹⁴⁴.

Se questa ultima viene rigettata, il giudice statuisce sulla domanda di divorzio per alterazione permanente della relazione coniugale (246 c. 2)¹⁴⁵.

Sezione 5: Sulle modificazioni del fondamento della domanda di divorzio¹⁴⁶

Gli sposi possono, in qualsiasi momento della procedura, domandare al giudice di constatare il loro assenso a veder pronunciare il divorzio per mutuo consenso presentandogli una convenzione che lo regoli (art. 247)¹⁴⁷.

Gli sposi possono ugualmente, in qualsiasi momento della procedura, quando hanno domandato il divorzio per alterazione permanente della relazione coniugale o per colpa, domandare al giudice di constatare il loro accordo per veder pronunciare il divorzio per accettazione della rottura del matrimonio (art. 247-1)¹⁴⁸.

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

¹⁴¹ Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

¹⁴² Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

¹⁴³ Article 245-1

A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

¹⁴⁴ Article 246

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

¹⁴⁵ S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

¹⁴⁶ Section 5: Des modifications du fondement d'une demande en divorce

¹⁴⁷ Article 247

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

¹⁴⁸ Article 247-1

Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Se, durante il corso di un procedimento instaurato per alterazione permanente della relazione coniugale, il convenuto dichiara in via riconvenzionale il divorzio per colpa, il ricorrente può invocare i torti del suo congiunto al fine di mutare il titolo della sua domanda (art. 247-2)¹⁴⁹

Capitolo II. Sulla procedura di divorzio¹⁵⁰

Sezione I: Disposizioni generali¹⁵¹

Il dibattimento della causa, le conseguenze del divorzio e le misure provvisorie non sono pubbliche (art. 248)¹⁵².

Se la domanda di divorzio è formata a nome di una maggiore tutelata, viene presentata tramite il tutore, previo l'autorizzazione del consiglio di famiglia se è stato istituito o dal giudice tutelare. La domanda è formata dopo avviso medico e, nella misura del possibile, dopo che è stata sentita la interessata, a seconda del caso, dal consiglio di famiglia o dal giudice (art. 249 c. 1)¹⁵³.

La maggiore in curatela esercita l'azione da se stessa con l'assistenza del curatore (art. 249 c. 2)¹⁵⁴.

Se lo sposo contro cui è stata formata la domanda è sotto tutela, l'azione è esercitata contro il tutore; se sussiste una curatela, è ammessa l'autodifesa, con l'assistenza del curatore (art. 249-1)¹⁵⁵.

Un tutore od un curatore ad hoc è nominato quando la tutela o la curatela è stata affidata al coniuge della persona protetta (art. 249-2)¹⁵⁶.

Se uno dei coniugi è sotto la protezione della corte, la domanda di divorzio non può essere esaminata se non dopo che si è sostituita la tutela o la curatela. Tuttavia, il giudice può adottare i provvedimenti provvisori di cui agli articoli 254 e 255 e le misure urgenti di cui all'articolo 257 (art. 249 c. 3)¹⁵⁷.

¹⁴⁹ Article 247-2

Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

¹⁵⁰ Chapitre II: De la procédure du divorce

¹⁵¹ Section 1 : Dispositions générales

¹⁵² Article 248

Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

¹⁵³ Article 249

Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.

¹⁵⁴ Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

¹⁵⁵ Article 249-1

Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.

¹⁵⁶ Article 249-2

Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.

¹⁵⁷ Art. 249-3

Qualora uno degli sposi si trovi sotto un regime di protezione previsto dal capitolo II del titolo XI del presente libro¹⁵⁸, non può essere presentata domanda alcuna di divorzio per mutuo consenso o per accettazione del principio di rottura del matrimonio (art. 249-4)¹⁵⁹.

Sezione 2: Sulla procedura applicabile al divorzio per mutuo consenso¹⁶⁰

La domanda di divorzio è presentata dai rispettivi avvocati delle parti o da un avvocato scelto di comune accordo (art. 250 c. 1)¹⁶¹.

Il giudice esamina la domanda con ciascuno degli sposi, poi li riunisce. Quindi chiama l'avvocato o gli avvocati (art. 250 c. 2)¹⁶².

Quando le condizioni di cui all'art. 232 sono raggiunte, il giudice omologa la convenzione che regola le conseguenze del divorzio e, con la stessa decisione, lo pronuncia (art. 250-1)¹⁶³.

In caso di rifiuto di omologazione della convenzione, il giudice può tuttavia omologare le misure provvisorie ai sensi degli articoli 254 e 255 che le parti acconsentono di assumere sino alla data in cui la sentenza di divorzio passi in giudicato, a condizione che soddisfino l'interesse del minore o dei minori (art. 250-2 c. 1)¹⁶⁴.

Una nuova convenzione potrà essere presentata dai coniugi entro un periodo massimo di sei mesi (art. 250-2 c. 2)¹⁶⁵.

In difetto della presentazione di una nuova convenzione entro il termine fissato dall'art. 250-2 o se il giudice rifiuta nuovamente la domanda di divorzio è caducata¹⁶⁶.

Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.

¹⁵⁸ Si tratta dei maggiori di età per cui è stata constatata dalla medicina un'alterazione che impedisce che possano provvedere a loro stessi

¹⁵⁹ Article 249-4

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

¹⁶⁰ Section 2: De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel.

¹⁶¹ Article 250

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

¹⁶² Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

¹⁶³ Article 250-1

Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

¹⁶⁴ Article 250-2

En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

¹⁶⁵ Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

¹⁶⁶ Article 250-3

Sezione 3: Sulla procedura applicabile agli altri casi di divorzio¹⁶⁷

Paragrafo 1 Sulla richiesta iniziale¹⁶⁸

Il coniuge che forma una domanda di divorzio presenta, tramite un avvocato, una richiesta al giudice, senza indicare i motivi di divorzio (art. 251)¹⁶⁹.

Paragrafo 2: Sulla conciliazione¹⁷⁰

Un tentativo di conciliazione è obbligatorio davanti al giudice. Può essere rinnovato nel corso del procedimento (art. 252 c. 1)¹⁷¹.

Il giudice cerca di conciliare gli sposi tanto sul principio del divorzio quanto sulle sue conseguenze (art. 252 c. 2)¹⁷².

Quando il giudice cerca di conciliare gli sposi, deve intrattenersi personalmente con ciascuno separatamente prima della riunione in sua presenza (art. 252-1 c. 1)¹⁷³.

Gli avvocati sono quindi invitati ad assistere e partecipare al colloquio (art. 252-1 c. 2)¹⁷⁴.

Nel caso in cui il coniuge che non ha presentato la domanda non compare in udienza o non è in grado di esprimere la sua volontà, il giudice si intrattiene con l'altro coniuge e lo invita alla riflessione (art. 252-1 c. 3)¹⁷⁵.

Il tentativo di conciliazione può essere sospeso e ripreso senza formalità, così da dare agli sposi un tempo di riflessione al massimo di 8 giorni (art. 252-2 c. 1)¹⁷⁶.

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

¹⁶⁷ Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce

¹⁶⁸ Paragraphe 1 : De la requête initiale.

¹⁶⁹ Article 251

L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

¹⁷⁰ Paragraphe 2 : De la conciliation.

¹⁷¹ Article 252

Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

¹⁷² Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

¹⁷³ Article 252-1

Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.

¹⁷⁴ Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.

¹⁷⁵ Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.

¹⁷⁶ Article 252-2

La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.

Se un termine più lungo può essere utile, il giudice può decidere di sospendere il processo e di ricorrere ad un nuovo tentativo di conciliazione ne termine massimo di 6 mesi. Egli ordina, se è necessario, le misure provvisorie necessarie (art. 252-2 c. 2)¹⁷⁷.

Se il giudice constata che il domandante mantiene ferma la sua domanda, raccomanda agli sposi di regolare amichevolmente le conseguenze del divorzio (art. 252-3 c. 1)¹⁷⁸.

Egli chiede loro di presentare all'udienza un progetto di regolamento degli effetti del divorzio. A questo effetto, può assumere le misure provvisorie di cui all'art. 255 (art. 252-3 c. 2)¹⁷⁹.

Ciò che è stato detto o scritto nel corso di una conciliazione, in qualsiasi forma essa si sia svolta, non può essere invocato nel corso della procedura a favore o contro un coniuge od un terzo (art. 252-4)¹⁸⁰.

Gli sposi non possono accettare il principio della rottura del matrimonio e la pronuncia sul divorzio sul fondamento dell'art. 233 se ciascuno di loro non è assistito da un avvocato (art. 253)¹⁸¹.

Paragrafo 3: Sulle misure provvisorie¹⁸²

All'udienza prevista dall'art. 252, il giudice prescrive, in considerazione di eventuali accordi tra i coniugi, le misure necessarie per garantire la loro esistenza e quella dei minori sino alla data nella quale la sentenza passerà in giudicato (art. 254)¹⁸³.

Il giudice può in particolare:

- 1° Proporre agli sposi la misura della mediazione familiare e, dopo aver accolto il loro consenso, nominare un mediatore familiare per procedere;
- 2° Indirizzare gli sposi affinché incontrino un mediatore familiare che li informi sull'oggetto e la regolamentazione della procedura;
- 3° Decidere sulla modalità di residenza separata degli sposi;

¹⁷⁷ Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

¹⁷⁸ Article 252-3

Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.

¹⁷⁹ Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

¹⁸⁰ Article 252-4

Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

¹⁸¹ Article 253

Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

¹⁸² Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.

¹⁸³ Article 254

Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

4° Attribuire ad uno di loro il godimento dell'alloggio e degli arredi domestici o stabilirne il godimento condiviso, precisare la sua gratuità o meno e, se del caso, prendere atto dell'accordo delle parti su una indennità di occupazione;

5° Ordinare la restituzione dell'abbigliamento e degli oggetti personali;

6° Fissare l'assegno alimentare e l'indennità per il pagamento delle spese processuali che uno degli sposi dovrà versare al congiunto, designare colui o coloro tra gli sposi che dovranno assicurare il regolamento di tutto o di parte delle predette misure;

7° Accordare ad uno degli sposi una indennità a valersi sui diritti derivanti dalla liquidazione del regime patrimoniale se la situazione lo rende necessario

8° Statuire sull'attribuzione del godimento o della gestione dei beni comuni o indivisi diversi da quelli di cui al punto quarto, con riserva dei diritti di ciascuno degli sposi in relazione alla liquidazione del regime matrimoniale;

9° Designare qualsiasi professionista qualificato in grado di stendere un inventario estimativo o di fare delle proposte per comporre gli interessi pecuniari degli sposi;

10° Nominare un notaio in grado di elaborare un progetto di liquidazione del regime matrimoniale e per la formazione dei lotti da condividere (art. 255)¹⁸⁴.

Le misure provvisorie relative ai bambini sono disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo IX di questo libro (art. 256)¹⁸⁵.

Sulla base della richiesta iniziale il giudice può prendere delle misure urgenti (art. 257 c. 1)¹⁸⁶.

Può, a questo titolo, autorizzare lo sposo che lo richieda a risiedere separatamente, in un luogo con i figli minori (art. 257 c. 2)¹⁸⁷.

¹⁸⁴ Article 255

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

¹⁸⁵ Article 256

Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

¹⁸⁶ Article 257

Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.

Può anche, a garanzia dei diritti di un coniuge, ordinare tutte le misure di conservazione come l'apposizione dei sigilli sui beni comuni. Le disposizioni dell'art. 220¹⁸⁸ del titolo XIV del presente libro e le altre salvaguardie previste per il regime matrimoniale rimangono tuttavia applicabili (art. 257 c. 3)¹⁸⁹. Il giudice può procedere a tutte le ricerche utili presso i debitori o presso coloro che detengono valori per conto degli sposi, senza che possa essere invocato il segreto bancario (art. 257 c. 4)¹⁹⁰.

Capitolo III: Sulle conseguenze del divorzio¹⁹¹

Sezione 1: Sulla data da cui si producono gli effetti del divorzio¹⁹²

La decisione che pronuncia il divorzio scioglie il matrimonio dalla data in cui essa prende forza di cosa giudicata (art. 260)¹⁹³.

La sentenza di divorzio è opponibile ai terzi, anche con riferimento ai beni degli sposi, a partire dal giorno in cui sono completate le formalità di trascrizione in margine in base alle regole dello stato civile (art. 262)¹⁹⁴.

La sentenza di divorzio ha effetto nel rapporto tra i coniugi in materia di proprietà:

- quando è pronunciata per mutuo consenso, dalla data della omologazione della convenzione regolante tutte le conseguenze del divorzio, a meno che non disponga diversamente;
- quando è pronunciata per accettazione del principio di rottura del matrimonio, per alterazione permanente della relazione coniugale o per colpa, dalla data dell'ordinanza di non conciliazione (art. 262 -1 c. 1);

¹⁸⁷ Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

¹⁸⁸ Article 220

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

¹⁸⁹ Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

¹⁹⁰ Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

¹⁹¹ Chapitre III : Des conséquences du divorce

¹⁹² Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

¹⁹³ Article 260

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

¹⁹⁴

Article 262

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

A domanda di uno dei coniugi, il giudice può fissare gli effetti della sentenza dalla data in cui è cessata la coabitazione e la collaborazione. Questa domanda non potrà che essere formata nell'occasione del procedimento di divorzio. L'attribuzione dell'abitazione coniugale per uno solo dei coniugi conserva il carattere gratuito dall'ordinanza di non conciliazione, salvo decisione contraria del giudice (art. 262-1 c. 2)¹⁹⁵.

Tutte le obbligazioni contratte da uno dei coniugi a carico della comunione, tutte le vendite dei beni comuni effettuate da uno dei coniugi nel limite dei suoi poteri, successivamente alla domanda di divorzio, sono nulle, se si prova che sono state fatte in frode ai diritti dell'altro coniuge (art. 262-2)¹⁹⁶.

Sezione 2: Le conseguenze del divorzio per gli sposi¹⁹⁷

Paragrafo 1: Disposizioni generali¹⁹⁸

Se gli sposi divorziati vogliono contrarre un'altra unione, è necessaria una nuova celebrazione del matrimonio (art. 263)¹⁹⁹.

Dopo il divorzio, ciascuno dei coniugi perde l'uso del nome del suo coniuge (art. 264 c. 1)²⁰⁰.

L'uno degli sposi può nondimeno conservare l'uso del nome dell'altro, con il consenso dello stesso, e con l'autorizzazione del giudice, se ciò sia giustificato da un interesse particolare proprio o dei minori (art. 264 c. 2)²⁰¹.

Il divorzio non ha incidenza sui vantaggi matrimoniali che hanno effetto durante il matrimonio e sulla donazioni di beni qualunque sia la loro forma (art. 265 c. 1)²⁰².

¹⁹⁵ Article 262-1

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens:

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

¹⁹⁶ Article 262-2

Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

¹⁹⁷ Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux

¹⁹⁸ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

¹⁹⁹ Article 263

Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

²⁰⁰ Article 264

A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

²⁰¹ L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

²⁰² Article 265

Il divorzio comporta la revoca di pieno diritto dei vantaggi matrimoniali che hanno effetto dalla dissoluzione del regime matrimoniale o alla morte di uno dei coniugi e delle disposizioni a causa di morte, accordati da uno sposo all'altro per il contratto di matrimonio o pendente l'unione, salva la volontà contraria dello sposo che lo consente. Questa volontà è constatata dal giudice al momento della pronuncia di divorzio e rende irrevocabile il vantaggio o la disposizione mantenuta (art. 265 c. 2)²⁰³.

Tuttavia, se il contratto di matrimonio lo prevede, gli sposi possono riprendersi sempre i beni che hanno apportato alla comunione (art. 265 c. 3)²⁰⁴.

Il divorzio non ha incidenza sui diritti che l'uno o l'altro degli sposi deriva dalla legge o da una convenzione intervenuta con i terzi (art. 265-1)²⁰⁵.

Gli sposi possono, in pendenza dell'istanza di divorzio, stipulare tutte le convenzioni per la liquidazione e la divisione del loro regime matrimoniale (art. 265-2 c. 1)²⁰⁶.

Quando la liquidazione comporta la liquidazione di beni sottoposti a pubblicità fondiaria, la convenzione deve essere stipulata per atto notarile (art. 265-2 c. 2)²⁰⁷.

Paragrafo 2: Le conseguenze proprie dei divorzi diversi da quello per mutuo consenso²⁰⁸

Senza pregiudizio dell'art. 270, il risarcimento dei danni e gli interessi può essere accordato al coniuge per riparare a conseguenze di particolare gravità che ha subito per il fatto dello scioglimento del matrimonio quando era convenuto o per un divorzio pronunciato per alterazione definitiva della relazione coniugale e che non abbia a sua volta formulato alcuna domanda di divorzio, o quando il divorzio è pronunciato per colpa esclusiva del suo coniuge (art. 266 c. 1)²⁰⁹.

La predetta domanda non può essere formulata che nell'occasione della domanda di divorzio (art. 266 c. 2)²¹⁰.

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

²⁰³ Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

²⁰⁴ Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

²⁰⁵ Article 265-1

Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.

²⁰⁶ Article 265-2

Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

²⁰⁷ Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

²⁰⁸ Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel.

²⁰⁹ Article 266

Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

²¹⁰ Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce .

In difetto di una regolamentazione convenzionale intervenuta tra gli sposi, il giudice, nel pronunciare il divorzio, ordina la liquidazione e divisione degli interessi patrimoniali (art. 267 c. 1)²¹¹.

Statuisce sulle domande di mantenimento della cosa indivisa o della assegnazione preferenziale (art. 267 c. 2)²¹².

Può anche accordare ad uno sposo o a tutti e due sulla parte di comunione o di proprietà indivisa (art. 267 c. 3)²¹³.

Se il progetto di liquidazione stabilito dal notaio designato ai sensi dell'art. 255 n. 10 contiene sufficienti informazioni, il giudice, su domanda dell'uno o dell'altro coniuge, decide sul disaccordo tra di loro persistente (art. 267 c. 4)²¹⁴.

Le operazioni di liquidazione e divisione degli interessi patrimoniali dei coniugi trovano regolamento negli articoli del Codice di procedura civile (art. 267-1)²¹⁵.

Gli sposi possono, pendente la domanda, sottoporre all'omologazione del giudice le convenzioni che regolano tutte o parti delle conseguenze di divorzio (art. 268 c. 1)²¹⁶.

Il giudice, dopo aver verificato che l'interesse di ciascuno degli sposi e dei minori sono preservate, omologa la convenzione e pronuncia il divorzio (art. 268 c. 2)²¹⁷.

Paragrafo 3: Delle prestazioni compensative²¹⁸

Il divorzio mette fine al dovere di soccorso tra i coniugi (art. 270 c. 1)²¹⁹.

Uno degli sposi può essere tenuto a versare all'altro una prestazione destinata a compensarlo, per quanto possibile, della disparità che la rottura del matrimonio crea nelle rispettive condizioni di vita. Questa

²¹¹ Article 267

A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

²¹² Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

²¹³ Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

²¹⁴ Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

²¹⁵ Article 267-1

Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.

²¹⁶ Article 268

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

²¹⁷ Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

²¹⁸ Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.

²¹⁹ Article 270

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

prestazione ha carattere forfetario. Essa prende le forme di un capitale il cui ammontare è disposto dal giudice (art. 270 c. 2)²²⁰

Tuttavia, il giudice, può rifiutarsi di accordare tale prestazione se lo comanda l'equità, anche in considerazione dei criteri previsti dall'art. 271, anche quando il divorzio è pronunciato per esclusivo torto del coniuge che domanda il beneficio di tale prestazione, con riguardo alle circostanze particolari della rottura (art. 270 c. 3)²²¹.

La prestazione compensativa è fissata secondo le esigenze dello sposo a cui è versata e in base alle risorse dell'altro e tenendo conto della situazione al momento del divorzio e dell'evoluzione prevedibile negli anni a venire (art. 271 c. 1)²²².

A questo effetto, il giudice prende in considerazione in particolare:

- la durata del matrimonio;
- lo stato di salute dei coniugi;
- la loro qualifica e situazione professionale,
- le conseguenze delle scelte professionali fatte da uno dei coniugi durante la vita comune per l'educazione dei minori e il tempo che ci vorrà ancora per consolidare o favorire la carriera dell'altro coniuge a detrimento della propria;
- il patrimonio stimato o prevedibile degli sposi, tanto nel capitale che nel reddito, successivamente alla liquidazione del regime matrimoniale;
- i diritti esistenti o prevedibili;
- il loro rispettivo stato della pensione di anzianità avendo stimato, per quanto possibile, la riduzione della pensione che potrebbe essere stata causata al coniuge creditore dell'indennità compensativa nelle circostanze di cui alla sesta alinea (art. 271 c. 2)²²³.

²²⁰

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

²²¹ Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

²²² Article 271

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

²²³ A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;

Nell'ambito della fissazione di un'indennità compensativa, operata dal giudice o dalle parti, o in occasione della domanda di revisione, le parti forniscono al giudice una dichiarazione certificata sull'onore dell'accuratezza delle loro risorse, del reddito, del patrimonio e delle condizioni di vita (art. 272)²²⁴.

Il giudice decide le modalità secondo le quali si escuterà la prestazione compensativa in capitale secondo le seguenti forme:

1° versamento di una somma di denaro, la pronuncia di divorzio può essere subordinata alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 277;

2° Attribuzione dei beni in proprietà o di un diritto temporaneo o di un diritto d'uso, di abitazione o d'usufrutto, la sentenza opera una cessione forzata in favore del creditore. Tuttavia, il consenso dello sposo debitore è necessario per l'attribuzione in proprietà di beni che egli ha ricevuto per successione o donazione (art. 274)²²⁵.

Quando il debitore non in condizione di versare il capitale secondo le modalità previste dall'art. 274, il giudice fissa le modalità di pagamento del capitale, entro il periodo di otto anni, sotto forma di versamenti periodici indicizzati secondo le regole applicabili agli alimenti (art. 275 c. 1)²²⁶.

Il debitore può richiedere la revisione delle modalità di pagamento nel caso di un importante mutamento della situazione. A titolo eccezionale, il giudice, con decisione speciale e motivata, autorizza il versamento del capitale per una durata totale superiore agli otto anni (art. 275 c. 2)²²⁷.

Il debitore può liberarsi in ogni momento con il saldo del capitale indicizzato (art. 275 c. 3)²²⁸.

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

²²⁴ Article 272

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

²²⁵ Article 274

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécute à la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

²²⁶ Article 275

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

²²⁷ Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

²²⁸ Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé

Dopo la liquidazione del regime matrimoniale, il creditore della prestazione compensativa può inoltrare al giudice la domanda di pagamento del saldo del capitale indicizzato (art. 275 c. 4)²²⁹.

I termini di pagamento nel primo comma dell'articolo 275 non sono esclusivi del pagamento di una parte del capitale con le modalità previste dall'art. 274 (art. 275-1)²³⁰.

In via eccezionale, il giudice può, con decisione motivata, quando l'età o lo stato di salute del creditore non gli permette di provvedere a suoi bisogni, fissare la prestazione compensativa sotto forma di rendita vitalizia. Prende in considerazione gli elementi previsti dall'art. 271 (art. 276 c. 1)²³¹.

L'importo della rendita può essere minore, quando le circostanze lo impongono, a seguito di attribuzione di una frazione di capitale secondo le forme previste dall'art. 274 (art. 276 c. 2)²³².

La rendita è indicizzata; l'indice è determinato come in materia di alimenti (art. 276-1 c. 1)²³³.

L'importo della rendita prima della indicizzazione è fissata in modo uniforme per tutta la sua durata o può variare in periodi successivi a seguito della probabile sviluppo delle risorse e dei bisogni (art. 276-1 c. 2)²³⁴.

Le prestazioni compensative fissate sotto forma di rendita possono essere rivisitate, sospese o soppresse in caso di importante cambiamento delle risorse e dei bisogni dell'una e dell'altra parte (art. 276-3 c. 1)²³⁵.

La revisione non può avere l'effetto di portare la rendita ad un ammontare superiore a quello fissato inizialmente dal giudice (art. 276-3 c. 2)²³⁶.

Il debitore di una prestazione compensativa sotto forma di rendita può, in qualsiasi momento, chiedere al giudice la sostituzione parziale o totale della rendita con un capitale. La sostituzione si effettua in base alle modalità stabilite da un decreto del Consiglio di Stato (art. 276 -4 c. 1)²³⁷.

²²⁹ Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

²³⁰ Article 275-1

Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.

²³¹ Article 276

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

²³² Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

²³³ Article 276-1

La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

²³⁴ Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

²³⁵ Article 276-3

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

²³⁶ La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

²³⁷ Article 276-4

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il creditore della prestazione compensativa può formare la medesima domanda se ritiene che qualche modifica della situazione del debitore permette questa sostituzione, in particolare modo durante la liquidazione del regime matrimoniale (art. 276-4 c. 2)²³⁸.

Le modalità di esecuzione previste dagli articoli 274, 275 et 275-1 sono applicabili. Il rifiuto del giudice di sostituire parzialmente o totalmente la rendita con un capitale, deve essere particolarmente motivato (art. 276-4 c. 3)²³⁹.

Indipendentemente dall'ipoteca legale o giudiziaria, il giudice può imporre al debitore di costituire un pegno, di fornire cauzione o di sottoscrivere una fideiussione per il pagamento della rendita o del capitale (art. 277)²⁴⁰.

In caso di divorzio per mutuo consenso, gli sposi fissano l'ammontare e le modalità della prestazione compensativa attraverso la convenzione che sottopongono all'omologazione del giudice. Possono prevedere che la prestazione cesserà di decorrere dalla realizzazione di un determinato evento. La prestazione può prendere la forma di una rendita attribuita per una durata determinata (art. 278 c. 1)²⁴¹.

Il giudice, tuttavia, può rifiutarsi di omologare la convenzione se essa fissa i diritti e le obbligazioni dei coniugi in modo non equo (art. 278 c. 2)²⁴².

La convenzione omologata ha la stessa forza esecutiva della decisione del giudice (art. 279 c. 1)²⁴³.

Essa non può essere modificata se non attraverso una nuova convenzione tra gli sposi, egualmente sottoposta ad omologazione (art. 278 c. 3)²⁴⁴.

Tuttavia, i coniugi possono prevedere nel loro accordo che ciascuno di essi può, in caso di variazioni significative delle risorse o delle esigenze di una delle parti chiedere al giudice di rivedere l'indennità compensativa. Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 275 e degli articoli 276-3 e 276-4 sono applicabili, in quanto l'indennità compensativa assuma la forma di un capitale o di una rendita temporanea o vitalizia (art. 278 c. 4)²⁴⁵.

²³⁸ Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

²³⁹ Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

²⁴⁰ Article 277

Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

²⁴¹ Article 278

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

²⁴² Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

²⁴³ Article 279

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

²⁴⁴ Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

²⁴⁵ Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation

Salve le particolari disposizioni della convenzione, sono applicabili gli articoli dal 280 a 280-2 (art. 278 c. 5)²⁴⁶.

Quando in applicazione dell'art. 268, gli sposi sottopongono all'omologazione del giudice una convenzione relativa ad una prestazione compensativa, sono applicabili le disposizioni degli articoli 278 e 279 (art. 279-1)²⁴⁷.

Alla morte dello sposo debitore, il pagamento della prestazione compensativa, qualunque sia la sua forma, viene riscossa tramite la successione. Il pagamento rimane in capo a tutti gli eredi, che non sono responsabili personalmente, nel limite dell'attivo successorio, ed in caso di insufficienza da tutti i legatari particolari, proporzionalmente al loro emolumento con riserva di applicazione dell'art. 927²⁴⁸ (art. 280 c. 1)²⁴⁹.

Quando la prestazione compensativa è stata fissata sotto forma di capitale pagabile secondo le condizioni dell'art. 275, il saldo del capitale indicizzato diventa immediatamente esigibile (art. 280 c. 2)²⁵⁰.

Quando è fissato sotto forma di rendita, essa è sostituita da un capitale immediatamente esigibile. La sostituzione viene operata secondo le modalità prescritte con decreto del Consiglio di Stato (art. 280 c. 3)²⁵¹.

In deroga all'articolo 280 gli eredi possono decidere insieme di mantenere le forme e le modalità di regolamento della prestazione compensativa che incombeva sullo sposo debitore, e che si obblighino personalmente al pagamento di detta prestazione. A pena di nullità, l'accordo prende le forme dell'atto notarile. Esso è opponibile ai terzi a decorrere dalla sua notificazione allo sposo creditore quando non sia intervenuto all'atto (art. 280-1 c. 1)²⁵².

compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

²⁴⁶ Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

²⁴⁷ Article 279-1

Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

²⁴⁸ A meno che cioè il testatore non abbia stabilito un diritto di precedenza.

²⁴⁹ Article 280

A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

²⁵⁰ Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

²⁵¹ Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

²⁵²

Article 280-1

Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

Quando le modalità del regolamento della prestazione compensativa non vengono mantenute, le azioni previste dal secondo comma dell'art. 275 e degli articoli 276-3 e 276-4, a seconda che la prestazione compensativa prenda la forma di un capitale o di una rendita temporanea o vitalizia, sono intentabili dagli eredi del debitore. Questi possono egualmente liberarsi in qualsiasi momento con il saldo del capitale indicizzato quando la prestazione compensativa prende le forme del primo comma dell'art. 275 (art. 280-1 c. 2)²⁵³.

Le pensioni di reversibilità eventualmente versate in relazione a qualsiasi coniuge deceduto sono dedotte dall'ammontare della indennità compensativa, quando quest'ultima, alla data della morte, aveva preso la forma di rendita vitalizia. Se gli eredi si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 280-1, a meno che il giudice non decida diversamente, una deduzione dal medesimo ammontare continua ad operare se il creditore perde il diritto o subisce una modifica del suo diritto alla pensione²⁵⁴.

I trasferimenti ed i prelievi fatti ai sensi del presente paragrafo sono, qualunque sia la loro modalità di versamento, considerati come parte del regime matrimoniale. Non possono essere assimilati alle donazioni (art. 281)²⁵⁵.

Paragrafo 4 : L'alloggio²⁵⁶.

Se il locale che serve da alloggio alla famiglia appartiene o è posseduto da uno degli sposi, il giudice può concederne la locazione al coniuge che esercita da solo o in comune l'autorità parentale su uno o su più minori che sono residenti abitualmente in quel locale e quando lo esige il loro interesse (articolo 285-1 c. 1)²⁵⁷.

Il giudice fissa la durata della locazione e può rinnovarla sino al raggiungimento della maggiore età del più giovane dei minori. Il giudice può risolvere il contratto di locazione se ciò è giustificato da nuove circostanze (articolo 285-1 c. 2)²⁵⁸.

Sezione 3: Le conseguenze del divorzio per i minori²⁵⁹

²⁵³ Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.

²⁵⁴ Article 280-2

Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.

²⁵⁵ Article 281

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

²⁵⁶ Paragraphe 4 : Du logement.

²⁵⁷ Article 285-1

Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

²⁵⁸ Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Le conseguenze del divorzio per i minori sono regolate dalle disposizioni del Capitolo I del titolo IX del presente libro (art. 286)²⁶⁰.

Capitolo IV: La separazione²⁶¹

Sezione I: I casi e la procedura della separazione²⁶²

La separazione può essere pronunciata a domanda di uno degli sposi negli stessi casi e alle medesime condizioni del divorzio (art. 296)²⁶³.

Lo sposo contro cui è presentata una domanda di divorzio può formalizzare una domanda riconvenzionale di separazione. Tuttavia, quando la domanda di divorzio è fondata sull'alterazione permanente della relazione coniugale, la domanda riconvenzionale non può tendere che al divorzio. Lo sposo contro il quale è presentata una domanda di separazione può formalizzare una domanda riconvenzionale di divorzio (art. 297)²⁶⁴

Quando la domanda di divorzio e di separazione sono concorrenti, il giudice esamina in prima battuta la domanda di divorzio. Egli si pronuncia non appena le circostanze lo permettono. In caso contrario, esso delibera sulla richiesta di separazione (art. 297 -1 c. 1)²⁶⁵.

Tuttavia, quando le domande sono fondate sulla colpa, il giudice le esamina contemporaneamente e, se le accoglie, pronuncia il divorzio a torto condiviso (art. 297 -1 c. 2)²⁶⁶.

Inoltre, le regole contenute nell'art. 228

Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 228 e al capitolo II di cui sopra si applicano alla procedura di separazione (art. 298)²⁶⁷.

Sezione 2: Le conseguenze della separazione²⁶⁸

La separazione non scioglie il matrimonio, ma pone fine al dovere di coabitazione (art. 299)²⁶⁹.

²⁵⁹ Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants

²⁶⁰ Article 286

Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

²⁶¹ Chapitre IV : De la séparation de corps

²⁶² Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps

²⁶³ Article 296

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

²⁶⁴ Article 297

L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

²⁶⁵ Article 297-1

Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

²⁶⁶ Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

²⁶⁷ Article 298

En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

²⁶⁸ Section 2 : Des conséquences de la séparation de corps

Ciascuno dei coniugi separati conserva l'uso del nome dell'altro. Tuttavia, la sentenza di separazione o la successiva può, tenuto conto dell'interesse specifico degli sposi, vietarlo (art. 300)²⁷⁰.

In caso di morte di uno degli sposi, l'altro sposo conserva che la legge accorda al coniuge sopravvissuto. Quando la separazione è pronunciata per mutuo consenso, i coniugi possono includere nella loro convenzione una rinuncia ai diritti successori che a loro sono conferiti dagli articoli che vanno da 756 a 757-3 e da 764 a 766 (art. 301)²⁷¹.

La separazione porta sempre alla separazione dei beni (art. 302 c. 1)²⁷².

Per quanto riguarda le merci, la data in cui la separazione ha effetto è determinata conformemente agli articoli da 262 a 262-2 (art. 302 c. 2)²⁷³.

La separazione lascia in piedi il dovere di soccorso: la sentenza che la pronuncia o quella posteriore fissa la pensione alimentare che è dovuto allo sposo secondo lo stato di bisogno (art. 303 c. 1)²⁷⁴.

Questa pensione è attribuita senza considerare i torti. Lo sposo debitore può nondimeno invocare, se del caso, le disposizioni dell'articolo 207, comma 2 (art. 303 c. 2)²⁷⁵.

Questa pensione è sottoposta alle regole delle obbligazioni alimentari (art. 303 c. 3)²⁷⁶.

Tuttavia, quando la consistenza dei beni dello sposo debitore è adeguata, la pensione alimentare può essere sostituita, in tutto o in parte, per la costituzione di un capitale, secondo le regole degli articoli da 274 a 275-1, 277 e 281. Se questo capitale diventa insufficiente per coprire i bisogni del creditore, quello può domandare un complemento sotto forma di pensione alimentare (art. 303 c. 4)²⁷⁷.

Salve le disposizioni di questa sezione, le conseguenze della separazione obbediscono alle medesime regole di cui alle conseguenze del divorzio evidenziate al capitolo III (art. 304)²⁷⁸.

²⁶⁹ Article 299

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

²⁷⁰ Article 300

Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.

²⁷¹ Article 301

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

²⁷² Article 302

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

²⁷³ En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

²⁷⁴ Article 303

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

²⁷⁵ Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

²⁷⁶ Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

²⁷⁷ Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

²⁷⁸ Article 304

Sezione 3: La fine della separazione²⁷⁹

La ripresa volontaria della vita comune mette fine alla separazione (art. 305 c. 1)²⁸⁰.

Per essere opponibile ai terzi, la stesa. Deve essere constatata attraverso atto notarile, o fatta oggetto di una dichiarazione dell'ufficiale di stato civile. Ne viene fatta menzione al margine dell'atto di matrimonio, e anche a margine del loro atto di nascita (art. 305 c. 2)²⁸¹.

La proprietà dei beni rimane separata a meno che gli sposi adottino un nuovo regime matrimoniale secondo le regole dell'articolo 1397 (art. 305 c. 3)²⁸².

A domanda di uno degli sposi, il giudizio di separazione è convertito di pieno diritto in divorzio quando la separazione dura da due anni (art. 306)²⁸³.

In tutti i casi di separazione, essi potranno convertirsi in divorzio per mutuo consenso (art. 307 c. 1)²⁸⁴.

Quando la separazione è pronunciata per mutuo consenso, non potrà convertirsi in divorzio se non su domanda congiunta (art. 307 c. 2)²⁸⁵.

Dal momento della conversione, la causa di separazione diventa la causa di divorzio; non può essere modificata l'attribuzione delle colpe (art. 308 c. 1)²⁸⁶.

Il giudice stabilisce le conseguenze del divorzio. Le prestazioni e le pensioni tra gli sposi sono determinate in base alle regole proprie del divorzio (art. 308 c. 2)²⁸⁷.

Il divorzio e la separazione sono regolati dalla legge francese:

- quando gli sposi sono di nazionalità francese
- quando gli sposi sono domiciliati sul territorio francese
- quando nessuna legge straniera si riconosce competente, e dunque i tribunali francesi sono competenti per pronunciare sul divorzio o sulla separazione²⁸⁸.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

²⁷⁹ Section 3: De la fin de la séparation de corps

²⁸⁰ Article 305

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

²⁸¹ Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

²⁸² La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

²⁸³ Article 306

A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.

²⁸⁴ Article 307

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.

²⁸⁵ Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

²⁸⁶ Article 308

Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

²⁸⁷ Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

²⁸⁸ Article 309

Preso atto della disciplina sostanziale descritta in precedenza pare opportuno soffermarsi un momento con maggiore dettaglio sul ruolo del giudice.

Gli accordi in materia di famiglia trovano una particolare considerazione presso il giudice francese.

Il giudice "in caso di disaccordo, si sforza di conciliare le parti. Al fine di facilitare la ricerca di un accordo da parte dei genitori in materia di esercizio consensuale dell'autorità parentale, il giudice può proporre loro la mediazione, e dopo aver ottenuto il loro consenso, designa un mediatore familiare per procedere"²⁸⁹.

Al momento di decidere sulle condizioni di esercizio della potestà genitoriale, si tiene conto degli accordi che i genitori hanno già concluso²⁹⁰.

All'udienza del conciliazione, prescrive le misure provvisorie "in considerazione degli eventuali accordi intervenuti tra i coniugi"²⁹¹.

Il giudice "Omologa gli accordi e dichiara il divorzio se acquisisce la certezza che la volontà di ciascun coniuge è reale e che il loro consenso è libero e informato. Può rifiutare l'omologazione e non pronunciare sul divorzio se si rende conto che l'accordo non preserva a sufficienza gli interessi dei minori o di uno degli sposi"²⁹².

Omologa la convenzione se constata che preserva sufficientemente l'interesse del minore o quando il consenso dei coniugi è stato espresso liberamente²⁹³.

E dunque una CPP (*convention des procédure participative*) potrà essere omologata solo quando sono stati protetti i diritti del minore o del coniuge convenuto (in particolare di quello più debole

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

²⁸⁹ En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Art 373-2-10 C.c.

²⁹⁰ Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
(*omissis*) Art 373-2-11 C.c.

²⁹¹ Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Art. 254 C.c.

²⁹² Article 232

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

²⁹³ Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. Art. 373-2-7 C.c.

economicamente); il ruolo del giudice è proprio quello di dare alle parti la certezza che l'accordo non trascuri i valori in gioco.

Anche quando il giudice risolve la lite la CPP può essere utile perché già da tempo le parti si sono scambiati i documenti inerenti la controversia.

Detto ciò il divorzio in Francia non costituisce diritto disponibile. Per questo motivo la legge precisa che per la CPP si devono seguire le norme del titolo VI del libro I del Codice civile.

Si può dire che ci sono più momenti e più ipotesi in cui si può raggiungere una CPP e l'accordo è sempre garantito dalla presenza del giudice.

Tra gli altri ricordiamo soprattutto il momento antecedentemente alla presentazione di una domanda di divorzio consensuale; oppure quello tra il deposito della domanda e la notifica dell'udienza di conciliazione.

Ma la disciplina di cui sopra ci aiuta ad aggiungere altre ipotesi in cui l'accordo delle parti potrebbe svolgere un ruolo principe.

Ad esempio nell'ambito del divorzio per colpa la legge stabilisce che "A domanda dei coniugi, il giudice può limitarsi a constatare che sussistono i fatti che sono causa di divorzio, senza dover indicare i torti o le rimozioni delle parti" (art. 245-1). E dunque i coniugi possono ben stipulare un accordo con il quale rinunciano all'indicazione.

Spazio pattizio può trovarsi anche riguardo alle disposizioni inerenti i vantaggi matrimoniali; il principio generale prevede che "Il divorzio comporta la revoca di pieno diritto dei vantaggi matrimoniali che hanno effetto dalla dissoluzione del regime matrimoniale o alla morte di uno dei coniugi e delle disposizioni a causa di morte, accordati da uno sposo all'altro per il contratto di matrimonio o pendente l'unione, salva la volontà contraria dello sposo che lo consente. Questa volontà è constatata dal giudice al momento della pronuncia di divorzio e rende irrevocabile il vantaggio o la disposizione mantenuta (art. 265 c. 2).

Essendoci però la possibilità di una volontà contraria, anche qui è possibile dar luogo a pattuizioni.

All'accordo si fa riferimento espresso nel caso in cui si sia azionata una domanda di divorzio non consensuale e si decida di passare al consensuale; l'art. 247 prevede, infatti, che gli sposi possono, in qualsiasi momento della procedura, domandare al giudice di constatare il loro assenso a veder pronunciare il divorzio per mutuo consenso presentandogli una convenzione che lo regoli.

La legge specifica che "Quando le condizioni di cui all'art. 232 sono raggiunte, il giudice omologa la convenzione che regola le conseguenze del divorzio e, con la stessa decisione, lo pronuncia" (art. 250-1).

Le condizioni di cui all'art. 232 sono le seguenti: i coniugi sono d'accordo sulla rottura del matrimonio, il giudice ha accertato che quella espressa sia la reale volontà dei coniugi e che il consenso sia stato espresso

liberamente e chiaramente ed in ultimo la convenzione protegge gli interessi dei minori o di uno degli sposi.

In caso di rifiuto di omologazione della convenzione, il giudice può tuttavia omologare alcune misure provvisorie che le parti acconsentono di assumere sino alla data in cui la sentenza di divorzio passi in giudicato, a condizione che soddisfino l'interesse del minore o dei minori (art. 250-2 c. 1). Una nuova convenzione potrà essere presentata dai coniugi entro un periodo massimo di sei mesi (art. 250-2 c. 2). In difetto della presentazione di una nuova convenzione entro il termine fissato dall'art. 250-2 o se il giudice rifiuta nuovamente la domanda di divorzio è caducata.

E dunque la procedura partecipativa ha uno spazio di almeno sei mesi per concordare una nuova convenzione.

Per i casi di divorzio non consensuale si precisa che è necessario un tentativo di conciliazione, all'esito negativo del quale "Se un termine più lungo può essere utile, il giudice può decidere di sospendere il processo e di ricorrere ad un nuovo tentativo di conciliazione nel termine massimo di 6 mesi. Egli ordina, se è necessario, le misure provvisorie necessarie" (art. 252-2 c. 2).

In questo tempo di sospensione può avere dunque spazio la p. p., ma anche successivamente.

Se il giudice constata che il domandante mantiene ferma la sua domanda, raccomanda agli sposi di regolare amichevolmente le conseguenze del divorzio (art. 252-3 c. 1). Egli chiede loro di presentare all'udienza un progetto di regolamento degli effetti del divorzio. A questo effetto, può assumere le misure provvisorie di cui all'art. 255 (art. 252-3 c. 2).

E dunque anche qui i coniugi possono ricorrere alla p.p. ed in particolare nominare un tecnico (v. ad. es. il punto 9 dell'art. 255).

La sentenza di divorzio del resto ha effetto nel rapporto tra i coniugi in materia di proprietà:

- quando è pronunciata per mutuo consenso, dalla data della omologazione della convenzione regolante tutte le conseguenze del divorzio, a meno che non disponga diversamente;
- quando è pronunciata per accettazione del principio di rottura del matrimonio, per alterazione permanente della relazione coniugale o per colpa, dalla data dell'ordinanza di non conciliazione (art. 262-1 c. 1).

Ancora "L'uno degli sposi può nondimeno conservare l'uso del nome dell'altro, con il consenso dello stesso, e con l'autorizzazione del giudice, se ciò sia giustificato da un interesse particolare proprio o dei minori" (art. 264 c. 2).

Anche in questo caso gli sposi possono procedere a p.p.

Gli sposi possono, in pendenza dell'istanza di divorzio, stipulare tutte le convenzioni per la liquidazione e la divisione del loro regime matrimoniale (art. 265-2 c. 1)

E dunque la p.p. può prendere vigore anche nella fase di liquidazione e divisione del regime matrimoniale. Salvo che “Quando la liquidazione comporta la liquidazione di beni sottoposti a pubblicità fondiaria, la convenzione deve essere stipulata per atto notarile” (art. 265-2 c. 2). In difetto di appunto di una regolamentazione convenzionale intervenuta tra gli sposi, “il giudice, nel pronunciare il divorzio, ordina la liquidazione e divisione degli interessi patrimoniali” (art. 267 c. 1).

Anche le conseguenze del divorzio possono essere oggetto di p.p.: “Gli sposi possono, pendente la domanda, sottoporre all’omologazione del giudice le convenzioni che regolano tutte o parti delle conseguenze di divorzio”(art. 268 c. 1).

Il giudice, dopo aver verificato che l’interesse di ciascuno degli sposi e dei minori sono preservate, omologa la convenzione e pronuncia il divorzio (art. 268 c. 2).

Un’indennità compensativa (versamento di una somma di denaro, attribuzione in proprietà di un immobile ecc.) può essere oggetto di accordo tra le parti (art. 272). In difetto viene ovviamente disposta dal giudice.

In caso di divorzio per mutuo consenso, gli sposi fissano l’ammontare e le modalità della prestazione compensativa attraverso la convenzione che sottopongono all’omologazione del giudice. Possono prevedere che la prestazione cesserà di decorrere dalla realizzazione di un determinato evento. La prestazione può prendere la forma di una rendita attribuita per una durata determinata (art. 278 c. 1). C’è un limite però perché “Il giudice, tuttavia, può rifiutarsi di omologare la convenzione se essa fissa i diritti e le obbligazioni dei coniugi in modo non equo (art. 278 c. 2)”.

La convenzione omologata ha la stessa forza esecutiva della decisione del giudice (art. 279 c. 1).

Essa non può essere modificata se non attraverso una nuova convenzione tra gli sposi, egualmente sottoposta ad omologazione (art. 278 c. 3).

E dunque la convenzione di p.p. può riguardare anche le modifiche della convenzione originaria.

Una convenzione può riguardare anche *post mortem* del creditore la riscossione, l’esigibilità, la forma dell’indennità compensativa (art. 279 e art. art. 280).

Si tenga ancora conto che tutti i casi di separazione “potranno convertirsi in divorzio per mutuo consenso (art. 307 c. 1)”. E si applicheranno conseguentemente le regole relative (la legge prevede che salve le disposizioni della sezione II, le conseguenze della separazione obbediscono alle medesime regole di cui alle conseguenze del divorzio evidenziate al capitolo III (art. 304))

In ultimo possiamo dire che è possibile omologare davanti al giudice un accordo che attenga all’esercizio dell’autorità parentale²⁹⁴.

In tal caso però per ottenere l’omologazione non basta allegare il contratto e la convenzione.

²⁹⁴ V. art. 1557 c. 3 C.p.c.

Si deve anche dare la prova che il minore capace di discernimento è stato sentito dal giudice o da un terzo delegato in presenza del suo avvocato (art. 1557).

mediare senza confini.org

2.6. La comparsa del tecnico nella procedura partecipativa

La sezione II²⁹⁵ del Capitolo I del titolo II del libro V del Codice di rito, contiene, come accennato, una disciplina legata alla comparsa di un tecnico nella procedura partecipativa convenzionale che ora esaminiamo.

Quando le parti decidono di ricorrere ad un tecnico, esse lo scelgono di comune accordo e determinano il suo mandato. Il tecnico è remunerato dalle parti, secondo le modalità convenute tra di loro²⁹⁶.

È compito del tecnico, prima di accettare la missione, di comunicare tutti i fatti che possono inficiare la propria indipendenza in modo che le parti possano tirare le conseguenze che stimano utili²⁹⁷.

Il tecnico comincia le operazioni nel momento in cui le parti abbiano concordato con lui le modalità del contratto²⁹⁸: non c'è un giudice che stabilisce l'onorario e la contrattazione tra le parti fa sicuramente risparmiare quella parte che tra l'altro, in sede di giudizio, vedrebbe in un primo tempo addossato a lui tutto l'onorario del CTU.

Il tecnico compie la sua missione con coscienza, diligenza ed imparzialità nel rispetto del principio del contraddittorio²⁹⁹.

Non potrà essere revocato se non con il consenso unanime delle parti³⁰⁰.

Su richiesta del tecnico o dopo aver ricevuto le sue osservazioni, le parti possono modificare la missione di lui od affidare una missione aggiuntiva ad un altro tecnico³⁰¹.

Le parti comunicano al tecnico i documenti necessari per lo svolgimento della sua missione³⁰².

Quando l'inerzia di una parte impedisce al tecnico di condurre al meglio la sua missione, questi convoca l'assemblea delle parti e comunica loro quali siano le diligenze necessarie. Se la parte non risponde alla sua richiesta, il tecnico continua la sua missione in base agli elementi che ha a disposizione³⁰³.

Un qualsiasi terzo interessato può, con l'accordo delle parti e del tecnico, intervenire alle operazioni condotte che lo riguardino. Il tecnico lo informa sui punti che sono per lui vincolanti³⁰⁴.

²⁹⁵ Le recours à un technicien.

²⁹⁶ Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Art. 1547 C.p.c.

²⁹⁷ Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles. Art. 1548 C.p.c.

²⁹⁸ Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. Art. 1549 c. 1 C.p.c.

²⁹⁹ Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire. Art. 1549 c. 2 C.p.c.

³⁰⁰ Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Art. 1549 c. 3 C.p.c.

³⁰¹ A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Art. 1550 C.p.c.

³⁰² Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Art. 1551 c. 1 C.p.c.

³⁰³ Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose. Art. 1551 c. 2 C.p.c.

Il tecnico unisce al suo rapporto le osservazioni ed i reclami scritti, se le parti o nel caso i terzi intervenienti lo domandano³⁰⁵.

Egli menziona nel suo rapporto le osservazioni e di reclami³⁰⁶.

Al termine delle operazioni, il tecnico rimette alle parti un rapporto scritto, e, se del caso, ai terzi intervenienti³⁰⁷.

Il rapporto può essere prodotto in causa³⁰⁸.

La consulenza tecnica dunque si presta almeno a due utilizzazioni: 1) costituisce base per la negoziazione tra le parti; 2) può essere prodotta in giudizio all'esito evidentemente del fallimento della negoziazione.

Appare strumento interessante in primo luogo perché è extragiudiziale: normalmente la consulenza tecnica è invece delegata dal giudice.

Inoltre può vertere su qualsiasi oggetto e non soffre dunque le limitazioni di materia che la maggior parte degli strumenti processuali (anche in Italia) possiedono.

Lo strumento sembra avvicinarsi alla *neutral evaluation* di stampo anglo-sassone dal momento che le parti sono padrone della missione del tecnico e dunque potrebbero chiedergli oltre al rapporto anche di fare una conciliazione od una mediazione.

Bisogna dire che i Francesi hanno con la consulenza tecnica un rapporto secolare e che i loro provvedimenti storicamente hanno influenzato la legislazione di mezza Europa e significativamente quella del nostro paese.

Dunque con un Editto del 1563³⁰⁹ si consentì ai tribunali di nominare degli esperti (*arbitres rapporteurs* = arbitri-relatori) che sentivano le parti e ne riferivano al Tribunale.

Con questa legge nasce propriamente in Francia quello che noi consideriamo il consulente tecnico³¹⁰.

L'art. 3 dell'Editto del novembre 1563 stabiliva in questo modo la competenza del Tribunale dei Giudici e Consulenti dei Mercanti, ossia del Tribunale di commercio su cui recentemente sta riflettendo anche il Ministero della Giustizia italiano.

“Conosceranno i Giudici e Consoli dei Mercanti di tutti i processi e le controversie che d'ora in poi interverranno tra i Mercanti, solamente nell'ambito dell'esercizio della mercatura, le loro vedove

³⁰⁴ Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables. Art. 1552 C.p.c.

³⁰⁵ Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandant, leurs observations ou réclamations écrites. Art. 1553 c. 1 C.p.c.

³⁰⁶ Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations. Art. 1553 c. 2 C.p.c.

³⁰⁷ A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. Art. 1554 c. 1 C.p.c.

³⁰⁸ Ce rapport peut être produit en justice. Art. 1554 c. 2 C.p.c.

³⁰⁹ Edit du mois de Novembre 1563, portant établissement des Juges-Consuls en la ville de Paris; <http://partages.univ-rennes1.fr/files/partages/Recherche/Recherche%20Droit/Laboratoires/CHD/Textes/Edit1563.pdf>

³¹⁰ Cfr. Revue de législation et de jurisprudence, Volume 15, Bureau de rédaction, 1842, p. 319 e ss. http://books.google.it/books?id=NKEvAQAAMAAJ&hl=it&source=gbs_navlinks_s <http://www.mediation-ieam.com/Historique.asp>

riconosciute, i fattori, servitori e istitori, riguardanti crediti, quietanze, fatture, lettere di cambio e di credito, ricevute, contratti di assicurazione, compagnie, società o associazioni già in piedi o che si faranno; in queste materie e controversie noi abbiamo il pieno potere e l'autorità regale per commetterle alla cognizione, giudizio e decisione dei giudici sopradetti; e tre di loro, che non svolgano attività contenziosa, eletti tra di loro, possano, se la natura della materia lo consente, se sono richiesti dalle parti, fornire il parere che ritengono, ad eccezione di quelle cause che siano riservate ai giudici e che siano pendenti davanti a loro, ovvero davanti ai Giudici e Consoli dei Mercanti, se le parti consentono e richiedono.

E ora dichiaro nulle tutte quei documenti portanti crediti, quietanze, fatture, e simili che non siano soggette alla giurisdizione dei ai Giudici e Consoli dei Mercanti”³¹¹.

E dunque nello stesso collegio si eleggevano tre soggetti che su richiesta delle parti potevano fare una proposta di composizione, se le parti lo richiedevano.

La figura del consulente-relatore non era storicamente una novità, già i Romani l'avevano.

Dall'avvocato BARINETTI³¹², accademico dell'Ottocento, apprendiamo che gli arbitri ricevevano dal pretore alcune controversie “*per le molte differenze ed i rapporti assai intralciati*” nelle quali assumevano funzione di mediatori e di pacificatori³¹³.

Gli arbitri che a Roma svolgevano questo ruolo di mediatori e pacificatori erano detti *sequestri*. E pure l'imperatore Federico II li norma splendidamente quando si occupa delle attribuzioni del Baiulo: “*Decideranno parimenti le querele che insorgessero tra la gente rustica sopra la variazione de' confini, o altro incommodo che si pretendesse ne' beni, e percezione dei loro frutti, chiamando ed interponendo la mediazione dei più pratici di detti confini e terre, che sieno uomini dabbene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto*”.

Dal 1563 il cammino dei tecnici in Francia è proseguito senza soluzione di continuità: all'inizio del XIX secolo in Francia si conoscevano diverse figure di compositori che avevano a che fare con la delegazione: parliamo degli arbitri d'obbligo e degli arbitri conciliatori eredi della tradizione sopra esposta.

³¹¹ Connaîtront les Juges & Consuls des marchands, de tous procès & différends qui se seront ciaprès mus entre Marchands, pour fait de marchandise seulement, leurs veuves Marchandes publiques, leurs Facteurs, Serviteurs & Commettants, tous Marchands, soit que lesdits différends procèdent d'obligations, cédulés, récépissés, lettres de change ou crédit, réponses, assurances, transports de dettes & novations d'icelles, calculs ou erreur en iceux, compagnies, société ou association ja faites, ou qui se feront ci-après ; desquelles matières & différends, nous avons, de nos pleine puissance & autorité royale, attribué & commis la connaissance, jugement & décision auxdits Juges-Consuls, & aux trois d'eux, privativement à tous nos Juges, appelés avec eux, si la matière y est sujette, & en sont requis par les Parties, tel nombre de personnes de conseil qu'ils aviseront, exceptés toutefois & réservés les procès que la qualité susdite ja intentés & pendants pardevant nos Juges, auxquels néanmoins enjoignons les renvoyer pardevant lesdits Juges & Consuls des marchands, i les Parties le requièrent et consentent. Et avons dès à présent déclarés nuls tous transports de cédulés, obligations & dettes qui seront faits par lesdits Marchands & personnes privilégiées, ou autre quelconque non sujette à la Jurisdiction desdits Juge & Consuls.

³¹² Professore ordinario di diritto somano all'Università di Pavia nel 1864.

³¹³ P. BARINETTI, *Diritto romano*, Parte generale, Vallardi, Milano, 1864 p. 190-191.

Gli arbitri d'obbligo venivano nominati dal tribunale di commercio per occuparsi delle vicende societarie che andavano in arbitrato obbligatorio.

Il giudice del commercio poi rimetteva davanti agli arbitri conciliatori le parti per l'esame dei conti: essi avevano l'obbligo di sentire le parti e conciliarle, qualora fosse stato possibile, e dare in caso diverso il loro parere; questi arbitri peraltro non giudicavano, ma esprimevano solo un parere³¹⁴.

Lo schema era in allora quello di oggi della procedura partecipativa con nomina di tecnico, con l'unica differenza che attualmente sono le parti a nominarlo.

Sulla scorta dell'art 421 del Codice di procedura civile francese del 1806³¹⁵ l'arbitro conciliatore – erede dell'arbitro-relatore - arrivò anche in Italia: il Codice commerciale etneo del 1819 prevedeva che il giudice del commercio rimettesse davanti agli arbitri le parti per l'esame dei conti; essi avevano l'obbligo di sentire le parti e conciliarle, qualora fosse possibile, e dare in caso diverso il loro parere.

Gli arbitri conciliatori erano peraltro utilizzati anche ai sensi dell'art. 156 del Codice di procedura civile italiano del 1859 con riferimento alla controversie societarie.

Di qui l'istituto è passato nell'art. 402 dal Codice del 1865 e, venendo a tempi più recenti, si ritrova negli articoli 198-200 del nostro Codice di procedura civile, anche se in quest'ultimo non si fa riferimento all'incarico di arbitri, ma alla figura del consulente contabile³¹⁶.

Rispetto alle figure del passato l'arbitro-relatore della *procédure participative* viene appunto nominato dalle parti con l'assistenza dei loro avvocati.

In ciò ha giocato la "contaminazione" del diritto nordamericano.

Se si fossero seguiti lo spirito e la lezione dell'Editto del 1563 ciò non sarebbe accaduto.

Il re di Francia Carlo IX che emise l'Editto non aveva, infatti, una grande considerazione degli avvocati.

L'art. 4 prevedeva infatti che *"E per tagliare corto tutte le lungaggini, ed altre occasioni di eccezione o dilazione, voglio ed ordino che tutti i rinvii siano espressi e basati su una richiesta; e le parti saranno tenute a comparire personalmente alla prima udienza per essere ascoltate se non c'è una legittima scusa di malattia od assenza, nel qual caso invieranno una risposta scritta di propria mano, o nel caso di malattia i loro parenti vicini ed amici che siano muniti di procura speciale, il tutto senza ministero di avvocato e procuratore"*³¹⁷.

³¹⁴ Corte Suprema di Giustizia, 5 aprile 1838.

³¹⁵ Cfr. J. MATTEI, *Annotazioni al codice di procedura civile*, Pietro Naratovich, Venezia, 1869, p. 459.

³¹⁶ Circa la diretta derivazione dell'esame contabile nostrano da quello del 1865 si esprime V. ANDRIOLI in *Commento al codice di procedura civile*, E. Jovene, Napoli, 1956, p. 114. L'autore ritiene semplicemente che l'oggetto del nostro esame contabile sia più lato, poiché può pertenerne ad ogni sorta di giudizio.

³¹⁷ Et pour couper court à toute longueur, & ôter l'occasion de fuit & plaider, voulons & ordonnons que tous ajournements soient libellés, & qu'ils contiennent demande certaine ; & seront tenues les Parties comparoir en personne à la première assignation, pour être ouies par leur bouche, s'ils n'ont légitime excuse de maladie ou absence, esquels cas enverront par écrit leur réponse signée de leur man propre, ou au cas de maladie, de l'un de leurs parents, voisins ou amis ayant de ce chargé & procuration spéciale, dont il sera apparoir à ladite assignation, le tout sans aucun ministère d'Avocat ou Procureur.

In altre parole i Giudici e Consoli dei Mercanti giudicavano, dopo aver tentato la conciliazione³¹⁸, con le parti presenti e senza l'assistenza dei difensori.

Ma ci sono altri aspetti della normativa del 1563 su cui riflettere.

Il principio di negoziazione secondo buona fede che si ritrova nel decreto 132/14 e nella procédure participative è qui già presente.

Nel prologo dell'Editto sta appunto scritto: “*Carlo³¹⁹ per grazia di Dio, re di Francia: A tutti i presenti e futuri: Saluto e vi rendo conto della richiesta e del monito per noi reso dal nostro Consiglio dei Mercanti della nostra buona città di Parigi, e per il bene pubblico e l'accorciamento di tutti i processi e delle controversie tra i Mercanti che sembra debbano negoziare in buona fede, senza le sottigliezze e le coercizioni previste dalle leggi e dalle Ordinanze, almeno, secondo l'avviso delle nostre tre volte onorata Madonna e Madre, dei Principi del nostro sangue, dei Signori e delle Genti del nostro Consiglio, stabiliamo ordiniamo e permettiamo ciò che segue*”³²⁰.

Questo editto è importante non solo perché istituisce il tribunale dei Mercanti, ma perché ci fa comprendere che la negoziazione in buona fede nasce nell'ambito delle relazioni tra i commercianti e dunque non è campato per aria che il primo organismo di mediazione di Francia stigmatizzi l'operazione della *procédure participative* come un favore che è stato fatto delle grandi multinazionali europee.

Almeno originariamente l'Editto riguardava appunto i mercanti.

Inoltre in questo prologo la locuzione “*ans être astreins aux subtilités des Lois & Ordonnances*” ci spiega che la ratio dell'istituto era quella di creare una zona franca, fuori cioè dagli obblighi coercitivi, ove i Mercanti potessero negoziare; non è che la “Besa”, la tregua che in Albania si afferma a seguito della guerra con l'impero Ottomano.

Chi fa come il sottoscritto la professione del mediatore la chiama semplicemente *setting* di mediazione.

³¹⁸ Art. 5

Se le versioni contrastano e le parti non si trovano d'accordo, sarà fissato un termine alla prima udienza per indicare i loro testimoni, che verranno sentiti sommariamente e dopo le deposizioni il giudice prenderà una decisione in udienza se è possibile secondo l'onore e la coscienza di detti Giudici e Consoli.

ARTICLE V

Si les Parties sont contraires, & non d'accord de leurs faits, délai compétent leur sera préfix à la première comparution, dans lequel ils produiront leurs témoins, qui seront ouïs sommairement, & sur leur déposition, le différend sera jugé sur la champ, si faire se peut, dont nous chargeons l'honneur & conscience desdits Juges & Consuls.

³¹⁹ Si tratta di Carlo IX che fu re di Francia dal 1560 al 1574.

³²⁰ CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France : A tous présents & à venir : Salut, Savoir faisons, que sur la Requête & remontrance à nous faites en notre Conseil de la part des Marchands de notre bonne ville de Paris, & pour le bien public & abréviation de tout procès & différends, Marchands qui doivent négocier en semble de bonne foi, sans être astreins aux subtilités des Lois & Ordonnances, avons, par l'avis de notre très-honorée Dame & Mère, des Princes de notre sang, Seigneurs & Gens de notredit Conseil, statué, ordonnons & permis ce qui s'ensuit.

2.7. Conclusione della procedura convenzionale e di quella a fine del giudizio

La sezione III del Capitolo I del titolo II del libro V del Codice di rito francese è dedicata alla conclusione della procedura convenzionale³²¹.

La procedura convenzionale si intende conclusa:

- 1) con lo spirare del termine della convenzione partecipativa;
- 2) per la risoluzione anticipata e scritta della convenzione operata dalle parti assistite dai loro avvocati;
- 3) con la stipulazione di un accordo che ponga fine alla totalità delle differenze o la redazione di un documento che attesti la persistenza parziale o totale delle differenze stesse³²².

Quando è stato raggiunto almeno un parziale accordo, lo si constata per iscritto dalle parti, assistite dai loro avvocati. E si enunciano in maniera dettagliata gli elementi che hanno permesso la conclusione di questo accordo³²³.

Il Capitolo II del titolo II del libro V del Codice di Rito si occupa invece dello sbocco processuale (*procédure aux fins de jugement*), ambito che, come detto all'inizio, appare quanto meno delicato.

Al termine della procedura convenzionale e con l'eccezione delle domande di divorzio o di separazione su cui è tenuto a provvedere a norma della sezione II del capo V del titolo I del libro III (ossia delle norme inerenti al divorzio e alla separazione), il giudice può conoscere della causa, a seconda dei casi, per omologare l'accordo delle parti che termina la controversia, un parziale accordo delle parti e decidere in merito alla parte del contenzioso rimasto in sospeso o per pronunciarsi sulla intera questione³²⁴.

La domanda fatta al giudice da una parte in caso di inesecuzione della convenzione dell'altra, perché statuisca sulla causa prima dello spirare del termine della convenzione, è formata, istruita e giudicata conformemente alle regole di procedura applicabile davanti al giudice stesso³²⁵.

³²¹ L'issue de la procédure.

³²² La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

³²³ La procédure conventionnelle s'éteint par :

1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. Art. 1555 C.p.c.

³²⁴ A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige. Art. 1556 c. 1 C.p.c.

³²⁵ La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge. Art. 1556 c. 2 C.p.c.

Il Codice affronta subito il caso più semplice in cui venga domandato di omologare l'accordo che chiude la controversia³²⁶ (art. 1557).

La domanda di omologazione di un accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 1555, ossia nel caso di accordo tombale, viene presentato al giudice su richiesta di una delle parti o di tutte le parti³²⁷.

Per essere ricevibile, la richiesta è accompagnata dalla convenzione del processo partecipativo³²⁸.

Qualora l'accordo richieda la capacità di discernimento di un minore, soprattutto quando si riferisce alle modalità di esercizio della potestà genitoriale, la richiesta deve descrivere le condizioni in base a cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice, o dalla persona da questi designata e ad essere assistito da un avvocato³²⁹.

Il Paragrafo I appartiene invece alla sezione II che riguarda la *procédure de jugement* quando persistono delle differenze³³⁰ ossia il caso opposto al precedente.

Tale paragrafo contiene due norme generali che si attagliano a tali ipotesi.

Quando le norme di procedura applicabili dinanzi al giudice al fine di decidere su tutta o parte della controversia sulla base della sezione II e III (ossia le successive che si occupano della omologazione di accordo parziale e delle differenze parziali residue) prevedono un tentativo preliminare di conciliazione o di mediazione, il caso si riferisce direttamente ad una udienza per essere giudicato³³¹.

Viene ribadita dunque l'esenzione del tentativo già evidenziata nella disciplina sostanziale.

Davanti al *tribunal de grande instance* e a meno che la procedura non debba essere assoggettata alla procedura ordinaria, l'affare è direttamente richiamato all'udienza del giudice assegnatario. L'affare non potrà essere restituito allo *juge de la mise en état*³³² quando le parti vogliono modificare le loro richieste o la base giuridica delle stesse³³³.

Il paragrafo II si occupa invece della omologazione di accordo parziale e delle differenze parziali residue.

Quando le parti non sono pervenute che ad un accordo parziale e a meno che non domandino l'omologazione ai sensi dell'art. 1557, possono rivolgersi al giudice perché statuisca secondo le regole che

³²⁶ La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend.

³²⁷ La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties. Art. 1557c. 1 C.p.c.

³²⁸ A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative. Art. 1557 c. 2 C.p.c.

³²⁹ Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat. Art. 1557 c. 3 C.p.c.

³³⁰ La procédure de jugement du différend persistant.

³³¹ Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée. Articolo 1558 C.p.c.

³³² È un giudice del *tribunal de grande instance* che sovrintende al corretto esercizio processuale e che può essere nominato come giudice unico in certe materie.

³³³ Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article 1561. Articolo 1559 C.p.c.

valgono di fronte a lui, con una richiesta congiunta firmata dai propri avvocati che li hanno assistiti nella procedura partecipativa alle condizioni previste dal presente paragrafo.

La richiesta contiene a pena di irricevibilità, oltre a ciò che è menzionato dall'art. 57 (ossia gli elementi necessari per una domanda congiunta):

- i punti oggetto di un accordo tra le parti, per cui possono chiedere al giudice congiuntamente l'omologazione;
- le rispettive pretese delle parti per quanto riguarda i punti sui quali esse rimangono in lite, accompagnate dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ogni affermazione, indicando per ciascuna pretesa i documenti forniti.

Sotto la stessa sanzione (della irricevibilità), la predetta richiesta è accompagnata dalla convenzione di procedura partecipativa, dei documenti previsti dall'art. 2063 C.c. (i documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione delle differenze), e se del caso, del rapporto del tecnico, e dei documenti che sono stati comunicati durante la procedura convenzionale³³⁴.

L'oggetto della lite è determinato dalle pretese rispettive che sono state formulate come espresso nella domanda ai sensi dell'articolo 1559³³⁵.

Le parti non possono modificare le loro pretese, salvi l'aggiornamento di una domanda relativa ad un contratto ad esecuzione differita, l'intervenuto pagamento e la compensazione, la sottoposizione al giudice di un intervento di terzo o la sopravvenienza o la rivelazione di un fatto successivo alla stipulazione dell'accordo³³⁶.

³³⁴ Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :

— les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

— les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle. Articolo 1560 C.p.c.

³³⁵ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559. Art. 1561 c. 1 C.p.c.

³³⁶ Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieure ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord. Art. 1561 c. 2 C.p.c.

Le parti non possono modificare la base giuridica della loro richiesta o sollevare nuovi motivi quando rispondono all'invito del giudice di fornire spiegazioni di fatto o di diritto che quest'ultimo ritiene necessarie per risolvere la controversia³³⁷.

Il paragrafo III e conclusivo della nostra analisi si occupa invece della situazione in cui le differenze permangono totali.

Quando le differenze dunque persistono totalmente il giudice le può conoscere:

- in base alle regole che vigono davanti a lui;
- oppure in base alle regole del precedente paragrafo;
- o ancora su richiesta unilaterale su cui egli deciderà circa le regole che vigono davanti a lui tenendo conto di quelle previste nel presente paragrafo³³⁸.

La richiesta è depositata in cancelleria dall'avvocato della parte più diligente. A pena di irricevibilità, essa va presentata entro tre mesi che decorrono dallo spirare del termine di conclusione della convenzione di procedura partecipativa³³⁹.

In aggiunta alle informazioni richieste, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 58 (indicazioni anagrafiche ed oggetto della domanda), la domanda contiene una dichiarazione dei motivi di fatto e di diritto ed è accompagnata da un elenco dei documenti di cui al terzo comma dell'articolo 1560 (i documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione delle differenze e i documenti che sono stati forniti al tecnico durante la procedura)³⁴⁰.

L'avvocato che procede al deposito ne informa l'altra parte e il medesimo avvocato che l'ha assistita nella procedura convenzionale, a seconda dei casi, mediante notifica o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno³⁴¹.

Davanti al *tribunal de grande instance*, il deposito deve contenere la nomina di avvocato³⁴².

Quando la domanda è stata depositata presso il *tribunal de grande instance*, la notifica dell'avvocato procedente informa che il convenuto deve nominare un legale entro quindici giorni da tale notifica³⁴³.

³³⁷ Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Art. 1561 c. 3 C.p.c.

³³⁸ Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

- soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
- soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
- soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe. Art. 1562 C.p.c.

³³⁹ La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative. Art. 1563 c. 1 C.p.c.

³⁴⁰ Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560. Art. 1563 c. 2 C.p.c.

³⁴¹ L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Art. 1563 c. 3 C.p.c.

³⁴² Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat. Art. 1563 c. 4 C.p.c.

Negli altri casi, l'avvocato del ricorrente è informato dalla cancelleria, del deposito della richiesta, della data della prima udienza utile in cui sarà chiamato il caso. Questa data è portata a conoscenza della controparte con la notifica di cui al terzo comma dell'articolo 1563³⁴⁴.

mediaresenzaconfini.org

³⁴³ Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Art. 1564 c. 1 C.p.c.

³⁴⁴ Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563 c. 2 C.p.c.

3. Un raffronto tra la legislazione francese e quella italiana.

Vediamo dunque qui sia le difformità sia i punti di contatto, dato che a più riprese è stato dichiarato dal Ministro della Giustizia che ci si è ispirati alla disciplina transalpina.

La prima differenza con la disciplina italiana riguarda lo strumento legislativo adottato.

In Francia la *procédure participative* si è introdotta con una legge per gli aspetti civilistici³⁴⁵ ed un decreto del primo ministro per quelli di rito³⁴⁶.

Sono ancora da emanarsi da parte dell'esecutivo transalpino le normative di dettaglio.

In Italia è stato utilizzato un decreto-legge ad oggi convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162³⁴⁷.

Il decreto-legge come ogni atto ministeriale deve essere sottoposto nel nostro paese all'analisi di impatto della regolamentazione³⁴⁸ all'esito del quale si deve presentare una relazione denominata AIR.

Con l'AIR si deve precisare il risultato delle consultazioni pubbliche e private su un dato tema che deve essere trasparente o perlomeno spiegare perché non ci sono state consultazioni.

In sostanza prima di fare una legge bisogna fare una adeguata istruttoria.

Si devono poi evidenziare nell'AIR, tra le altre cose, "*i relativi vantaggi collettivi netti, l'analisi dei presupposti di natura giuridica, organizzativa, economico-sociale e l'indicazione degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di imprese e cittadini*";³⁴⁹" di un dato provvedimento.

E bisogna indicare con chiarezza le fonti che hanno portato gli analisti ad un certo convincimento.

Solo a seguito dell'apprestamento dell'AIR il provvedimento può essere presentato al Consiglio dei Ministri per essere varato. E ciò perché l'art. 7. del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 in tema di Presentazione della relazione AIR stabilisce che "*1. Le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9*".

³⁴⁵ LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires in <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023273986>

³⁴⁶ Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?sessionId=A34A0DEDE8CDB686BB5C8F0F0B71E908.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000025179010&dateTexte=20141105

³⁴⁷ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175)http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-10&atto.codiceRedazionale=14G00175&elenco30giorni=false

³⁴⁸ Art. 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008, n. 170 (Ambito di applicazione dell'AIR).

1. La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa.

³⁴⁹ Art. 6. (Contenuti della relazione AIR) c. 2 lett. f) del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008, n. 170 (Ambito di applicazione dell'AIR).

Il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha però sottolineato che ciò non è avvenuto per il decreto legge 132-14; nel suo parere scrive che “*il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;*³⁵⁰”, ma inspiegabilmente non ha chiesto al Governo di presentarla³⁵¹.

Va detto che il Consiglio dei Ministri può apprestare l'AIR in qualsiasi momento, ma allo stato allo scrivente resta il dubbio legittimo sulla genesi del provvedimento.

Ad ogni modo il tessuto normativo italiano è di soli 10 articoli³⁵², mentre quello francese ne conta, in attesa della regolamentazione di dettaglio, ben 28.

Per la disciplina italiana non è stato previsto un inserimento nei codici (si richiama soltanto la disciplina dell'art. 480 C.p.c.³⁵³), a differenza di quella transalpina che integra direttamente il codice civile ed il codice di procedura civile³⁵⁴.

Altra discrepanza riguarda la configurazione della condizione di procedibilità: non è prevista dalla disciplina francese; nel paese transalpino vige il principio di volontarietà per tutti gli strumenti alternativi (salve limitate deroghe), nonostante il CNB ancora da ultimo invochi per la *procédure participative* almeno una seduta informativa obbligatoria³⁵⁵; né troviamo qualsivoglia traccia di obbligatorietà nei disegni di legge italiani anteriori al decreto-legge 132-14³⁵⁶.

Nella disciplina francese e nei disegni di legge³⁵⁷ non si individua poi una materia in particolare come oggetto dell'istituto, ma si richiedono alcuni requisiti e si pongono divieti: si veda l'art. 2064 C.c. che

³⁵⁰

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0026040&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2681-e-sede=-e-tipo=

³⁵¹ L'art. 9 c 4 del DPR 170/08 prevede che “Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi di cui all'articolo 8, ove sia richiesto dalle Commissioni Parlamentari,...”.

³⁵² L'art. 7 è stato eliminato in sede di Commissione al Senato e dunque degli 11 articoli del decreto-legge 132-14 ne rimangono oggi solo 10. I disegni di legge antecedenti al decreto legge 132-14 contenevano 25 articoli e dunque erano più corposi.

³⁵³ Nel senso che si richiede che l'accordo che derivi da una negoziazione assistita o da una mediazione “deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”.

³⁵⁴ Art. 1542-1654 C.p.c.

³⁵⁵ Cfr. “L'avocat, acteur des modes amiables de résolution des différends” in http://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/199905791718/%5BCNB%5D_Justice_21eme_siecle_-_Modes_amiables_de_resolution_des_differends_%5Boct._2014%5D.pdf

³⁵⁶ In questi si prevede però la possibilità di pattuire contrattualmente una negoziazione assistita. V. ad esempio il disegno di legge C. 1474-13: “4. Il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché sia conforme a quanto disposto dall'articolo 21 nonché ai criteri per la nomina dell'avvocato negoziatore”.

³⁵⁷ Si veda ad esempio il C. 1474.

Art. 23.

richiede la disponibilità dei diritti e vieta la procedura per i contratti di lavoro o l'art. 2067 C.c. che statuisce una particolare disciplina per la negoziazione in materia di separazione e divorzio³⁵⁸.

Oggi in Italia abbiamo invece due tipi di controversia per cui la negoziazione assistita costituisce appunto condizione di procedibilità: faccio riferimento alla materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e alla domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro (ad eccezione della domanda connessa appunto ai sinistri stradali che già vi rientra)³⁵⁹.

Si deve però aggiungere che restano fermi gli speciali procedimenti di conciliazione o di mediazione obbligatoria e dunque se la controversia riguardante il pagamento ricade nelle materie previste da tali ultimi procedimenti, non si può che utilizzare i medesimi.

Tra gli speciali procedimenti possiamo indicare, senza la presunzione di esaurirli:

- Conciliazione CO.RE.COM.³⁶⁰;
- Conciliazione in materia di subfornitura³⁶¹;
- Conciliazione diritto d'autore³⁶²;
- Conciliazione CONSOB³⁶³: si noti che in questo caso, a differenza della mediazione, la negoziazione assistita non può essere alternativa;
- Mediazione nel turismo³⁶⁴: se la clausola di mediazione obbligatoria è sottoscritta dal turista;
- Conciliazione agraria³⁶⁵.

Viene poi in campo l'art. 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che prevede ipotesi per le quali è la mediazione a doversi considerare condizione di procedibilità: condominio, diritti reali, divisione,

(Oggetto della convenzione: limiti).

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato non può essere stipulata al fine di risolvere controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 (controversie in materia familiare), o controversie relative alla risoluzione del rapporto del lavoro dipendente, alla certificazione dei contratti di lavoro e alla materia previdenziale.

³⁵⁸ Cfr. ad esempio S. 148

Art. 6.

(Oggetto della convenzione. Limiti)

1. La convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorti in relazione a diritti indisponibili, a status della persona, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, a questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto del lavoro dipendente ovvero ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.

³⁵⁹ Art. 3. Improcedibilità

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (*Omissis*)

³⁶⁰ Art. 1 c. 11 legge 31 luglio 1997, n. 249.

³⁶¹ Art. 10 L. 18 giugno 1998 n. 192.

³⁶² Art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.

³⁶³ Art. 27 c. 1 lett. a) L. 28 dicembre 2005, n. 262.

³⁶⁴ Art. 67 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

³⁶⁵ Art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Non si può poi trascurare le ipotesi in cui una negoziazione assistita non è applicabile:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d) nei procedimenti in camera di consiglio;
- e) nell'azione civile esercitata nel processo penale³⁶⁶.

Ancora è esente da n.a. l'ipotesi in cui ci si possa difendere in giudizio senza l'assistenza dell'avvocato³⁶⁷.

Infine sono escluse dalla condizione di procedibilità le controversie da contratti tra consumatori e professionisti.

Vi sono poi da muovere alcune osservazioni sugli elementi definitori dell'istituto.

La convenzione di procedura partecipativa è in Francia un accordo mediante il quale le parti di una controversia che non ha ancora visto l'intervento di giudice o di un arbitro si impegnano ad operare congiuntamente ed in buona fede per risolvere amichevolmente la loro controversia³⁶⁸.

La disciplina italiana non utilizza la locuzione "procedura partecipativa", ma piuttosto quella di negoziazione assistita da uno o più avvocati; la locuzione italiana è giustificata perché il rapporto Guinchard che ha battezzato l'istituto fa riferimento ad una «*procédure participative*» de négociation assistée par avocat.

Recita l'art. 2 c. 1 del decreto convertito:

*"La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96"*³⁶⁹.

Nella disciplina italiana non sussiste il requisito che la controversia non debba aver ancora visto l'intervento di un giudice o di un arbitro.

³⁶⁶ Art. 3 c. 3 del decreto convertito.

³⁶⁷ Art. 7 del decreto convertito.

³⁶⁸ La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Art. 2062 c. 1 C.c.

³⁶⁹ L'art. 2 c. 1 del decreto legge aveva il seguente testo "1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96".

Tale vincolo era previsto espressamente dai disegni di legge³⁷⁰, ma non è stato recuperato né dal decreto legge, né dalla disciplina di conversione³⁷¹.

Nella disciplina francese poi viene richiesta la buona fede delle parti che operano congiuntamente³⁷², ma non il requisito della lealtà a cui noi facciamo riferimento a partire dal primo disegno di legge, senza però darne una definizione.

Nel nostro diritto privato non esisteva sino ad ora un negozio di tal fatta.

La giurisprudenza parla da decenni di obbligo di cooperazione sia nella fase delle trattative sia nella fase di esecuzione del contratto

Per la lealtà verrebbe secondo alcuno in gioco l'art. 1337 c.c. (comportamento secondo buona fede nelle trattative precontrattuali): e dunque il dovere di informare la controparte sulle circostanze rilevanti (invalidità o inefficacia di un futuro contratto), sui vizi della cosa oggetto del contratto, sulla inutilità della prestazione; si parlerebbe di cooperazione perché il contratto sia efficace o comunque utile; non si dovrebbe interrompere le trattative senza una ragionevole giustificazione³⁷³.

La buona fede, come abbiamo già rilevato, stava già alla base dell'antenato dell'istituto nel 1563.

Non era invece presente nel decreto-legge originario la previsione riguardante la negoziazione assistita nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

mediarensenzaconfini.org

³⁷⁰ V. ad esempio l'ultimo disegno di legge, il C. 1474-13:

Art. 18.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato).

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti in conflitto, *che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro*, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto o la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati.

³⁷¹ Sempre i disegni di legge disponevano però una interessante disciplina di una negoziazione assistita disposta dal giudice anche per i procedimenti di famiglia, ma non è stata recepita dal decreto-legge, né dalla legge di conversione

Prendiamo ad esempio S. 148/13

Art. 17.

(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato)

1. Il giudice, con l'ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile e in qualsiasi momento successivo fino alla precisazione delle conclusioni o nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione a lui sottoposta, nonché fornendo alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando il termine per la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato in contraddittorio con le parti.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'istanza di omologazione prevista dall'articolo 9 è presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza.

3. Nei giudizi di separazione e di divorzio, il presidente del tribunale in sede di comparizione personale delle parti davanti a sé e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e fornendo loro ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.

4. I termini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

³⁷² Non si parla esattamente di cooperazione come nella disciplina italiana: in proposito ci si potrebbe chiedere come si faccia a cooperare senza buona fede o slealmente.

³⁷³ D. PISELLI, *La negoziazione assistita da avvocato*, Impresa e Società, in <http://www.ilcaso.it/>

“1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165³⁷⁴, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente”.

Non è stata questa la scelta operata dal legislatore francese che ha introdotto nel 2011³⁷⁵ la conciliazione delegata nell'ambito del processo amministrativo³⁷⁶.

Nei tribunali amministrativi e nelle corti amministrative d'appello, i presidenti possono, se le parti sono d'accordo, organizzare una missione di conciliazione e nominare a questo effetto la o le persone che la condurranno³⁷⁷.

Sempre nel 2011 si è deciso di introdurre nel settore amministrativo anche la mediazione. Va qui menzionata in particolare l'Ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011³⁷⁸ che ha inserito nel Codice di giustizia amministrativa un capitolo inerente alla mediazione³⁷⁹.

Vengono in campo però le sole controversie transfrontaliere nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo quando non si tratti di questioni per cui una delle parti è assoggettata al potere pubblico.

La convenzione di *procédure participative* è in Francia a tempo determinato³⁸⁰ ed è prorogabile³⁸¹.

Anche in Italia si prevede che quella di negoziazione assistita sia a tempo determinato e si stabilisce come in Francia, che il termine per l'espletamento della procedura debba precisarsi, ma si aggiunge che la pattuizione non stabilisca un termine “*inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti*”³⁸².

Ciò presuppone che nel suddetto tempo si svolga attività negoziale e si spera sin d'ora la pronuncia di improcedibilità da parte dei giudici nel caso in cui ciò non avvenga, così come accade peraltro nel caso di rapporti soggetti a mediazione come condizione di procedibilità.

³⁷⁴ “2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

³⁷⁵ Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011.

³⁷⁶ *Livre II. Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Titre premier. Attributions Chapitre premier. Attributions contentieuses. Chapitre I.*

³⁷⁷ Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. Art. L 211-4 Codice di giustizia amministrativa.

³⁷⁸ Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. La norma è in vigore dal 18 novembre 2011.

³⁷⁹ *Livre VII. Le Jugement. Titre VII. Dispositions spéciales. Chapitre premier ter. La médiation.*

³⁸⁰ Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Art. 2062 c. 2 C.c.

³⁸¹ Cfr. Art. 1546 Codice di procedura civile. Article 1546

La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

³⁸² Il decreto legge prevedeva che non dovesse essere inferiore ad un mese. I disegni di legge da uno a quattro mesi. La possibilità di proroga, ma per quattro mesi spunta nel disegno di legge C. 1474.

Non si comprende però perché per la negoziazione assistita sia stata consentita la proroga e ciò non sia invece stato stabilito per la mediazione che è procedura decisamente più rilevante data la mole delle procedure che muove (nei primi due semestri del 2014 ben 142.599³⁸³ a fronte delle “teoriche” 17.000 della negoziazione assistita), per quanto la prassi, dobbiamo dirlo, porti sovente ad uno sfioramento di cui ad oggi nessun mediatore conosceva le conseguenze³⁸⁴.

Premesso ciò abbiamo annotato che nella disciplina francese il termine non viene fissato dalla legge, perché è l’ultima cosa a cui pensano i negoziatori; non si può, infatti, prevedere un termine sino a che non sono state sviscerate tutte le questioni oggetto della controversia e non si sono indicate le strade per una risoluzione della controversia.

Abbiamo anche visto che il termine convenzionale è in Francia molto importante perché da esso dipendono importanti effetti, tra cui la prescrizione che resta sospesa dal momento della firma della convenzione – assume la dottrina (FRICERO) - sino al constatato e datato fallimento.

La disciplina francese è profondamente differente dalla nostra³⁸⁵, perché da noi la prescrizione si interrompe, mentre da loro sospende il termine. Inoltre quella francese consisterebbe in una disposizione a carattere premiale perché comunque resta sospesa per almeno sei mesi dal termine previsto dalla convenzione.

In Francia è il diritto comune che prevede non la interruzione, ma la sospensione della prescrizione e questa disposizione dunque non poteva che essere coerente al sistema.

Ancora il termine di sospensione in Francia decorre dalla convenzione, mentre in Italia il termine di interruzione è stabilito dall’invito; c’è una parificazione degli effetti con la domanda giudiziale che deriva dall’aver voluto riprendere da parte del legislatore italiano la disciplina della mediazione³⁸⁶, ma mentre in quest’ultima il termine da cui ridecorre può essere ricostruito dalla data del verbale di mancata conciliazione redatto da un terzo imparziale (o comunque di deposito se si voglia parificare in questo senso la disciplina della prescrizione con quella decadenza) per la negoziazione assistita non vengono dati

³⁸³ Cfr.

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/statistiche_mediazione_civile_del_2_trimestre_2014.pdf

³⁸⁴ Da ultimo il Ministero, su richiesta di un organismo, si è espresso sul quesito del termine tacciandolo come ordinatorio e specificando soltanto quello che già si sapeva ossia che le parti una volta trascorso possono recarsi davanti ad un giudice.

³⁸⁵ Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza

1. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

³⁸⁶ Art. 5 c. 6 decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.

elementi certi: forse si potrebbe pensare alla dichiarazione di mancato accordo che è certificata dagli avvocati designati³⁸⁷(così come assume la dottrina francese per la *procédure participative*).

Vi è poi solo in Italia il richiamo alla decadenza per cui si prende a prestito una parte della disciplina della mediazione: la decorrenza del termine può essere impedita per una sola volta per tutti e due gli istituti, ma mentre per la mediazione il termine per l'azione giudiziale decorre dal deposito del verbale di mancato accordo, per la negoziazione assistita parte dal rifiuto dell'invito o dalla mancata accettazione nel termine di 30 giorni. Si prevede però anche il caso in cui l'invito sia accettato e la convenzione non porti ad accordo; in tal caso il termine per adire il giudice decorre dalla certificazione degli avvocati di mancato accordo. La norma potrebbe essere premiale se stabilisse la decorrenza di un eguale termine di decadenza rispetto a quello che la legge prevede per l'esercizio del diritto, ma l'interpretazione in questo senso non è sicura (anche se il richiamo alla disciplina della mediazione così deporrebbe).

Abbiamo detto che dalla locuzione antica "*ans être astreins aux subtilités des Lois & Ordonnances*" si ricava che la ratio dell'istituto era proprio quella di creare una zona franca, fuori cioè dagli obblighi coercitivi, ove le parti potessero negoziare.

Ma la capacità di negoziazione non è soltanto una attitudine che il negoziatore si porta dentro, va alimentata con la formazione.

Mentre i disegni di legge prevedevano un obbligo in capo ai Consigli dell'Ordine per la formazione³⁸⁸, nulla di tutto ciò rinveniamo nel decreto legge o nella legge di conversione.

Pensare che la negoziazione assistita si possa ridurre soltanto ad una transazione assistita per quanto complessa non è esatto se affermiamo di ispirarci alla procedura francese; che abbisogni di formazione trasversale lo indicano appunto i disegni di legge tra il 2011 ed il 2013 anche se poi prevedono rimedi impugnatori per la transazione³⁸⁹; certo un accordo può tradursi anche in una transazione, ma non è detto poiché si può agire sugli interessi o anche sugli interessi e per quanto riguarda poi la Francia le

³⁸⁷ Cfr. art. 5 c. 3 del decreto convertito.

³⁸⁸ Disegno di legge C. 1474 (Art. 39) (Ordini).

1. Gli Ordini organizzano per gli iscritti corsi di formazione volti a promuovere la conoscenza delle procedure relative alle convenzioni di negoziazione assistite da un avvocato e di mediazione e delle tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, nonché a diffondere il loro utilizzo tra i medesimi iscritti. Gli enti locali territoriali e le associazioni di categoria assumono d'intesa o su richiesta del consiglio dell'Ordine ogni iniziativa per favorire la conoscenza delle citate procedure per incentivarne l'utilizzo.

³⁸⁹ Cfr. ad es. art. 26 c. 2 e 28 C. 1474: "2. L'accordo di cui al comma 1 deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti oggetto di transazione, conciliazione o rinuncia. Le dichiarazioni generiche non hanno valore."

Art. 28. (Annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo).

1. L'accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L'accordo può essere dichiarato nullo o annullato ai sensi degli articoli 1966, 1971, 1973, 1974 e 1975 del codice civile.

transazioni sono omologabili già dal 1999³⁹⁰ e dunque non avevano bisogno di ribadire una disciplina già presente nell'ordinamento.

Se non siamo in presenza di una mera transazione³⁹¹ ci sono inevitabili ripercussioni sulla consulenza legale che dovrà condursi in materia non tradizionale, a meno che l'invito in negoziazione assistita non venga inteso come una semplice ed inutile formalità burocratica; in sostanza andrà preparata così come dovevasi preparare una mediazione, anzi forse con una maggiore attenzione agli aspetti comunicativi e alle tecniche di negoziazione, se non si voglia prevedere la presenza del mediatore.

Il codice di procedura civile francese stabilisce poi che la procedura partecipativa *“Si traduce in una procedura convenzionale per raggiungere un accordo e, se del caso, per proseguire in sede giudiziaria”*³⁹².

Abbiamo già detto che in omaggio a detto principio la negoziazione francese prevede due fasi: 1) negoziazione tra le parti in base alla convenzione stipulata liberamente e accordo o mancato accordo o accordo parziale 2) omologazione per accordo e giudizio per mancato accordo o per accordo parziale partendo non dagli atti introduttivi delle parti, ma dalla stipulata convenzione a cui sono allegati i documenti che le parti ritengono pertinenti.

Questo impianto non trova casa nella disciplina italiana ove il fallimento della negoziazione non conduce ad alcun vantaggio tangibile per un'abbreviazione del giudizio: di qui non si comprende come con questa misura il Ministero possa pensare di ridurre il contenzioso in primo grado ad un anno.

Nella procedura convenzionale al fine di raggiungere un accordo può poi trovare spazio anche l'intervento di un tecnico (articoli 1544-1555 del Codice di rito).

Anche questa opzione non è stata contemplata dal decreto-legge 132-14, né dalla legge di conversione.

E pensare che invece i disegni di legge anteriori avevano sul punto un'ampia veduta: *“5. Gli avvocati designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall'articolo 31, all'ausilio di mediatore familiare abilitato”*³⁹³.

Si è persa davvero l'occasione di impraticarsi con la mediazione familiare e con la neutra valutazione che è molto utilizzata nel mondo anglo-sassone: ci sono dei recenti provvedimenti europei che sembrano indirettamente contemplarla laddove si parla di un terzo che *“propone una soluzione”* e che non si possono ignorare. E pure il raccordo espresso alla mediazione civile poteva essere molto utile.

³⁹⁰ Article 1441-4 C.p.c. Créé par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 30 JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999. Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.

³⁹¹ Come pensa già qualche giudice italiano, mi riferisco ad esempio alla tesi da ultimo espressa in pubblico convegno dal presidente del tribunale di Genova.

³⁹² Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Art. 1543 C.p.c.

³⁹³ C. 1474-13.

Chi vuole fare negoziazione assistita/ mediazione deve sapere non c'è molta differenza tra il prepararsi per una mediazione ed una negoziazione assistita. L'unica differenza riguarda il fatto che nel secondo caso la figura del mediatore può mancare, il che determina semmai una maggiore attenzione e cura dei negoziatori.

Le parti devono sempre e comunque ottenere quanto più possibile dalla procedura e dunque ci sono aspetti giuridici e non da prendere in considerazione se si vuole condurre una trattativa.

Negli Stati Uniti non esiste una norma che abiliti gli avvocati ad negoziare perché ciò discende dal loro mandato a partire dalla consulenza che viene condotta secondo determinati parametri e spesso il diritto rimane sullo sfondo³⁹⁴.

Negli Stati Uniti esiste come noto la mediazione e l'*American Bar Association* ogni anno fornisce delle guide specifiche e generali agli avvocati, ma anche agli enti pubblici, perché il cittadino deve sapere che cosa aspettarsi sia dalla mediazione sia dal suo difensore se decide di munirsene. Ricordo che negli Stati Uniti non è necessaria la difesa legale. Qui di seguito traduco un estratto della guida generale alla mediazione per il 2014; di seguito passerò ad una illustrazione delle domande che si possono ricavare con riferimento alla negoziazione assistita anche dalle versioni degli anni precedenti delle guide diffuse dall'ABA.

*“Prima di iniziare una mediazione potresti desiderare di discuterne gli aspetti con qualcuno di cui hai fiducia e che può essere in grado di consigliarti. Ad esempio potresti considerare di chiedere una consulenza ad un avvocato se la questione involve aspetti giuridici, se in gioco c'è una proprietà o molto denaro, o se tu desideri un legale esperto che ti consigli prima e/o durante la mediazione”*³⁹⁵.

Se hai un avvocato, devi lavorare a stretto contatto con lui per preparare la mediazione.

Oltre ad aiutarti a raccogliere importanti informazioni, a sviluppare una strategia negoziale, e consideri gli aspetti che seguono, lavorare insieme ti aiuterà a capire che cosa ci si può aspettare l'uno dall'altro in una mediazione. Ad esempio tu potrai discutere se il ruolo dell'avvocato sarà soltanto quello di aiutarti a preparare la mediazione e a consigliarti dopo ogni sessione o se il tuo avvocato ti accompagnerà alle sessioni. Se l'avvocato viene in mediazione con te, devi assicurarti di discutere su quale ruolo ognuno di voi giocherà durante la mediazione. Potresti anche decidere il modo in cui tu ed il tuo avvocato

³⁹⁴ “In representing a client, a lawyer shall exercise independent professional judgment and render candid advice. In rendering advice, a lawyer may refer not only to law but to other considerations such as moral, economic, social and political factors, that may be relevant to the client's situation”. Rule 2.1 Model Rules of Professional Conduct (2014) Cfr. http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/rule_2_1_advisor.html

³⁹⁵ Before you start mediating, you might want to discuss the issues listed below with someone you trust and who may be able to advise you. For example, you should consider getting advice from a lawyer if the case involves legal issues, if there is a lot of money or property at stake, or you want a legal expert to advise you before and/or during the mediation.

esprimerete il vostro punto di vista e il modo in cui comunicherete con gli altri, ad esempio che cosa dovrai fare se desideri parlare privatamente con qualcuno durante la mediazione³⁹⁶.

Se non hai un avvocato ed hai domande circa il processo di mediazione puoi desiderare di parlare con il mediatore, con un dipendente del mediatore, o con lo staff. Ricorda che in alcuni programmi di mediazione il mediatore non può parlare con una delle parti privatamente prima della sessione di mediazione. Tieni conto che i mediatori o le terze parti neutrali non possono elargire consulenze legali in una mediazione. Anche se non parli con nessuno prima della mediazione dovresti pensare ad alcuni aspetti che seguono. Non puoi darti delle risposte precise ad alcune delle seguenti domande e le tue risposte possono cambiare durante la mediazione ma ti può comunque aiutare a prendere in considerazione alcune questioni prima del tempo³⁹⁷.

Ci sono degli elementi oggettivi su cui le parti possono concordare che potrebbero risolvere la controversia?

Ci sono problemi causati da sfiducia o difettosa comunicazione?

³⁹⁶ If you have a lawyer, you should work closely with that lawyer to prepare for the mediation. In addition to helping you collect important information, develop a negotiation strategy, and consider the issues listed below, working together will help you know what to expect of each other in the mediation process. For example, you will want to discuss whether your lawyer's role will be only to help you prepare for mediation and advise you after each session or whether your lawyer will also join you at the mediation session(s). If your lawyer is going to be at the mediation with you, be sure to discuss what roles each of you will play during the mediation session. You might also decide how you and the lawyer will express your point of view during the mediation and how you will communicate with each other, for example, what you should do if you want to talk with each other privately during the mediation.

Questa è peraltro al preoccupazione del Codice deontologico forense del Canada che è stato emendato da poco ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2014.

SECTION 5.7 LAWYERS AS MEDIATORS

Role of Mediator

5.7-1 A lawyer who acts as a mediator shall, at the outset of the mediation, ensure that the parties to it understand fully that

(a) the lawyer is not acting as a lawyer for either party but, as mediator, is acting to

assist the parties to resolve the matters in issue; and

(b) although communications pertaining to and arising out of the mediation process

may be covered by some other common law privilege, they will not be covered by the solicitor-client privilege.

Commentary

[1] In acting as a mediator, generally a lawyer should not give legal advice as opposed to legal information to the parties during the mediation process. This does not preclude the mediator from giving information on the consequences if the mediation fails.

[2] Generally, neither the lawyer-mediator nor a partner or associate of the lawyer-mediator should render legal representation or give legal advice to either party to the mediation, bearing in mind the provisions of the rules in Section 3.4 (Conflicts) and its commentaries and the common law authorities.

[3] Generally a lawyer-mediator should suggest and encourage the parties to seek the advice of separate counsel before and during the mediation process if they have not already done so.

[4] Where in the mediation process the lawyer-mediator prepares a draft contract for the consideration of the parties, the lawyer-mediator should expressly advise and encourage them to seek separate independent legal representation concerning the draft contract.

<http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147486159>

³⁹⁷ If you don't have a lawyer and you have questions about the mediation process, you may want to talk with the mediator, an employee of the mediator, or staff working in a mediation office. Note that in some mediation programs, the mediator may be prohibited from having private conversations with the parties before the mediation session. Be aware that mediators are neutral third parties and are not allowed to provide legal advice to the parties in a mediation.

Even if you don't talk with anyone else before mediation, you should think about the issues listed below. You may not be able to give a definite answer to some of the following questions and your answers may change during the mediation process, but it is still helpful to seriously consider these questions ahead of time.

Che cosa ti piacerebbe realizzare in mediazione?

Che cosa il mediatore ha bisogno di capire per far sì che tu raggiunga i suoi obiettivi?

Che cosa l'altra parte ha bisogno di capire?

Se non raggiungi un accordo che cosa è più probabile che accada?

Quale è la tua migliore e realistica alternativa se non raggiunge un accordo? E quale la tua peggiore alternativa? In molti casi giuridici questo significa sviluppare una chiara consapevolezza dei punti di forza e di debolezza prima della mediazione

Quale risultato potrebbe soddistarti?

Che cosa pensi potrebbe soddisfare l'altro? Ciò può riguardare un valore di scambio monetario o non monetario.

Come si fa a sapere se un eventuale accordo sia migliore di una probabile alternativa? Si considerano i costi, il tempo e gli sforzi necessari, gli effetti sui rapporti con gli altri, la sola risoluzione della controversia?

Su quali aspetti ti puoi mettere d'accordo e su quali altri non è possibile?

Quanto favorevolmente vedi il rischio di non raggiungere un accordo, di andare a processo o in arbitrato?

In caso di raggiungimento di un accordo accettabile vuoi mantenere la relazione con l'altra parte dopo la risoluzione della controversia?

Quali informazioni, documenti casi o regole possono far cambiare idea all'altro circa gli aspetti della disputa? Che cosa può farti cambiare idea?"³⁹⁸

³⁹⁸ What is the conflict really about?

Are there objective standards the parties would agree upon that might help resolve the dispute?

Are some of the problems caused by mistrust or miscommunication?

What would you like to accomplish at the mediation?

What does the mediator need to understand to help you accomplish your goals?

What does the other party need to understand?

If you do not reach agreement, what is most likely to happen?

What is your best possible (realistic) alternative if you do not reach agreement? What is your worst possible (realistic) alternative? In most legal cases, this means developing a clear understanding of the strengths and the weaknesses of your case before.

What would you need to feel satisfied the mediation with the outcome?

What do you think that the other person needs to feel satisfied? This may involve the exchange of monetary or nonmonetary value.

How would you know if a possible agreement is better than the most likely alternatives to it? As you compare possible agreements with your alternatives, consider the costs, time and effort required, effect on your relationships with the other party and other people, and the value of just getting the matter resolved, among other things.

If you can reach an acceptable agreement in mediation, would you want to have any relationship with the other party after the dispute is resolved?

What issues do you and the other party agree about?

What issues do you disagree about?

How comfortable are you with the risks of not reaching an agreement, such as going to court or binding arbitration?

What information, documents, cases, or rules might cause the other party to change his or her mind about the issues in dispute? What might cause you to change your mind?). Preparing for mediation ABA 2014. http://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/resources/mediation_week_toolkit.html

Detto ciò vediamo che cosa un negoziatore assistito potrebbe chiedere al suo cliente sia in seguito all'acquisizione dell'incarico, sia di seguito all'ottenimento dei documenti di controparte e alla loro compiuta valutazione.

L'avvocato negoziatore in primo luogo deve spiegare alla parte - se non abbia mai partecipato ad una negoziazione - che può ricavare maggiore profitto da una preparazione preventiva.

Deve spiegare alla parte che abbia già partecipato ad una negoziazione che una preparazione preventiva è utile perché le questioni e la controparte e il suo avvocato sono comunque differenti.

Deve essere consapevole del fatto ed è tenuto a spiegare al cliente che non esiste un modo migliore di un altro per preparare la negoziazione e che comunque la preparazione è assai impegnativa.

Durante la preparazione della negoziazione l'avvocato negoziatore è tenuto a:

- raccogliere le informazioni rilevanti;
- sviluppare una strategia negoziale;
- aiutare il cliente ad avere una visione comune di quello che ognuno può aspettarsi dall'altro e dunque dei ruoli di ognuno;
- considerare alcune questioni anche se non possono avere una risposta anticipata e la cui risposta può variare nel corso della procedura.

Detto ciò e premesso che l'avvocato negoziatore è uno che fa domande più che recare consulto, questo potrebbe l'oggetto di tali richieste:

1. Quale è il reale conflitto tra voi? Quello che appare o c'è dell'altro?
2. Ci sono problemi tra le parti causati dalla sfiducia o da una cattiva comunicazione?
3. Che cosa vorrebbe realizzare nella negoziazione?
4. Che cosa deve conoscere l'altra parte per raggiungere il suo obiettivo?
5. Di che cosa ha bisogno lei per essere soddisfatto?
6. Di che cosa ha bisogno l'altra parte per sentirsi soddisfatta?
7. Ci sono degli elementi oggettivi su cui potete concordare che potrebbero risolvere la controversia?
8. Che cosa l'avvocato dell'altra parte ha bisogno di capire per far sì che lei raggiunga i suoi obiettivi?
9. Che cosa l'altra parte ha bisogno di capire?
10. Se non raggiungete un accordo in negoziazione che cosa si aspetta di fare?
11. Quale è la sua migliore e realistica alternativa se non raggiunge un accordo? E quale la sua peggiore alternativa?
12. Quanto favorevolmente vede il rischio di non raggiungere un accordo e di andare a processo o in arbitrato?

13. Come possiamo fare a sapere se un eventuale accordo sia migliore di una probabile alternativa (processo, arbitrato ecc.)? Consideriamo i costi, il tempo e gli sforzi necessari, gli effetti sui rapporti con le altre persone, la sola risoluzione della controversia?

14. Nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo vuole mantenere una relazione con la controparte dopo la risoluzione della controversia?

15. Su quali questioni vi potete accordare?

16. Su 17. Che cosa potrebbe causare un cambiamento in lei?

18. Quali informazioni, documenti, casi, o regole potrebbero far cambiare idea all'altra parte sulle questioni coinvolte nella disputa?

19. In caso di raggiungimento di un accordo accettabile vuole mantenere la relazione con l'altra parte dopo la risoluzione della controversia? quali questioni lei non può accordarsi?

Anche se il cliente è convinto che le altre persone abbiano torto, l'avvocato negoziatore sa che per una buona riuscita della negoziazione deve esplorare i punti di vista altrui.

L'avvocato negoziatore deve dunque avvertire il cliente che in negoziazione:

- può ascoltare opinioni che non condivide;
- è più produttivo sforzarsi di comprendere le opinioni altrui anche se non si condividono;
- la controparte ed il suo avvocato vogliono ascoltare ciò che è realisticamente possibile;
- è meglio ascoltare con attenzione la controparte e cercare di individuare gli argomenti su cui concorda: ciò, infatti, può indurre la controparte a capire le opinioni del cliente e a chiudere un accordo;
- è meglio trattare la controparte con rispetto quando si è in disaccordo: il rispetto attira rispetto;
- è meglio mantenere una mente aperta e desiderosa di considerare varie opzioni di un accordo.

Con riferimento alle sedute congiunte di negoziazione potrebbero poi essere utili i seguenti quesiti.

- Che cosa potrei fare io come legale per aiutarla?
- Secondo lei quali informazioni dovremo riservare alla seduta di negoziazione?

Il legale negoziatore poi dovrà essere pronto ad anticipare le seguenti domande del cliente.

- Chi sarà presente alla seduta di negoziazione?
- Parteciperanno alla seduta oltre agli avvocati delle parti anche altri professionisti?
- Se le parti raggiungeranno un accordo chi lo preparerà?
- Quanto costa la negoziazione? Come si dividono i costi? (ove non si fissi in sede di convenzione)

Anche da tutto questa attività preparatoria consegue che la negoziazione per essere accurata vuole i suoi tempi e non si possono generalizzare: da ultimo se ne sono accorte ad esempio per la mediazione

giudiziaria le Corti della Lituania³⁹⁹, non si comprende perché noi non ci siamo ancora arrivati e ci facciamo incalzare dal fantasma di un accesso alla giustizia peraltro male inteso in buona o in mala fede non so.

Non va decisamente in questo senso la previsione che nel testo convertito in legge (art. 3 c. 5) stabilisce poi che *“Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi”*.

E dunque se non si vuole leggere come una norma di semplice coordinamento della negoziazione assistita coi termini di procedibilità delle assicurazioni private⁴⁰⁰, si potrebbe arguire che se due assistenti negoziatori decidono di partecipare ad una mediazione il tempo non si somma, ma decorre in parallelo; è dunque abbiamo ancora una norma disincentivante del ricorso ad un mezzo alternativo.

In Francia gli estremi della convenzione di procedura partecipativa sono contenuti, a pena di nullità, in un atto scritto che deve precisare il termine, l'oggetto della controversia e l'indicazione dei documenti e delle informazioni necessarie per risolvere la disputa e le condizioni del loro scambio⁴⁰¹.

Il Codice di rito aggiunge alcuni elementi in relazione alla procedura convenzionale: *“Oltre a quanto menzionato dall'art. 2063 C.c., la convenzione di procedura partecipativa menziona i nomi, i cognomi, e gli indirizzi delle parti e dei loro avvocati.”*⁴⁰²

³⁹⁹ Il Consiglio giudiziario della Lituania, a seguito del buon esito di un progetto pilota (le norme sulla mediazione giudiziaria sono del 2011 e si trovano in <http://www.teismai.lt/lt/mediacija/visuomenei/>), nel settembre scorso ha approntato un panel di mediatori giudiziari (sono 66 e si trovano in <http://www.teismai.lt/lt/mediatoriams/>). A giugno aveva già stabilito che la mediazione giudiziaria fosse estesa a tutti i tribunali del paese (<http://www.teismai.lt/lt/mediacija/visuomenei/>).

Qualche giorno fa lo stesso Consiglio ha richiesto ai giudici di invitare le parti ad aumentare l'uso delle procedure pacifiche di risoluzione delle controversie, che sono più veloci e costano meno di un normale processo giudiziario.

Sono state approntate nuove regole per la mediazione giudiziaria (entreranno in vigore il 1° gennaio 2015): in particolare non ci sarà più un termine fisso di 4 ore per la procedura perché ogni procedura deve avere il tempo necessario fino a quando le parti non trovino il risultato desiderato (con il limite però dell'udienza fissata da l giudice); inoltre si potrà mediare anche in luoghi diversi dalle aule di tribunale.

Sono state varate nuove regole anche per la formazione dei mediatori che sarà di 32 ore da cui saranno dispensati i giudici (in Lituania possono mediare anche loro, ma in tal caso non possono partecipare alla fase giudiziaria) che hanno una formazione a sé.

La mediazione giudiziaria è gratuita e l'accordo comporta una diminuzione dell'imposta di bollo del 75%.

⁴⁰⁰ Art. 145 (Proponibilità dell'azione di risarcimento)

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

⁴⁰¹ La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise:

1° Son terme ;

2° L'objet du différend ;

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. Art. 2063 C.c.

La dottrina (FRICERO) rileva che sarebbe opportuno allegare anche la fotocopia della carta di identità delle parti e l'estratto K bis⁴⁰³ per le persone giuridiche.

E precisa che la comunicazione delle memorie e dei documenti tra le parti avviene tramite i loro avvocati secondo le modalità previste dalla convenzione, che li porta a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo. Una ricevuta viene apprestata quando un documento sarà comunicato⁴⁰⁴.

Anche la convenzione di negoziazione italiana deve essere redatta invece per iscritto a pena di nullità (art. 4 decreto-legge e legge di conversione)⁴⁰⁵.

Non c'è però una norma che precisi come sia possibile modificarla: ciò sarebbe stato opportuno; in Francia si prevede che *“la convenzione di procedura partecipativa può essere modificata con le stesse forme che sono stabilite per la sua costituzione”*⁴⁰⁶.

La convenzione di negoziazione assistita deve specificare l'oggetto della controversia che, abbiamo detto, deve riguardare come in Francia diritti disponibili e non deve vertere oggi in materia di lavoro⁴⁰⁷.

Non si richiede invece da noi di citare i nomi e cognomi e gli indirizzi delle parti e dei loro avvocati, mentre si sottolinea che gli avvocati certificano le sottoscrizioni dei loro clienti⁴⁰⁸.

Nulla viene poi riferito sulle forme di comunicazione di memorie e documenti ed è questa sicuramente una lacuna.

La comunicazione dei documenti sta alla base dell'istituto che come sappiamo deriva dal diritto collaborativo canadese; se non c'è una *discovery* non c'è diritto collaborativo, come non c'è procedura partecipativa.

Il nostro legislatore invece non ha ripreso questa disciplina: non ha previsto lo scambio di documenti né che fossero presenti “le informazioni necessarie per risolvere la disputa”, rendendo la negoziazione assistita un simulacro di istituto, eliminandone almeno allo stato la *ratio*: non si sa, infatti, se nella ipotizzata sede di modifica del Codice di procedura civile ci sarà o meno un riallineamento alla disciplina transalpina.

⁴⁰² Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. Art. 1545 c. 1 C.p.c.

⁴⁰³ Rappresenta la carta di identità delle società (sarebbe il nostro certificato camerale). Cfr. <https://www.infogreffe.fr/societes/documents-officiels/demande-kbis.html>

⁴⁰⁴ La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée. Art. 1545 c. 2 C.p.c.

⁴⁰⁵ Anche i disegni di legge precedente erano nello stesso senso (cfr. art. 3 C. 4376-11, S. 2774-11, S. 148-13 e art. 20 C. 1474/13).

⁴⁰⁶ Art. 1546.- La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

⁴⁰⁷ Art. 2 c. 2 del testo convertito: “b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro”. Nel decreto-legge si richiedeva solo che i diritti non fossero indisponibili. Ma in precedenza anche i disegni di leggi vedevano come preclusa la materia del lavoro e quanto relativo alla certificazione dei contratti di lavoro.

⁴⁰⁸ Art. 2 c. 6 decreto-legge 132-14 e legge di conversione.

Che il nostro foro sia allergico ad una prospettiva di scambio dei documenti e di rinvenimento delle informazioni per risolvere la disputa, è un dato perché diversamente non avremmo un contenzioso così paralizzante, ma incentivare questa secolare abitudine alla “non negoziazione” non va certamente nel senso di una deflazione come il legislatore si propone.

Al contrario i disegni di legge italiani, in linea con quanto previsto dalla commissione Guinchard, disponevano che la convenzione dovesse precisare “c) *le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia e i modi del loro scambio e prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e di consulenti;*”⁴⁰⁹.

Il che apriva anche ed ulteriormente al mondo della negoziazione e alla individuazione in consulenza di quella che si definisce in negoziazione la *zone of possible agreement* (zopa) perché diversamente non si sarebbe potuto fornire le “*informazioni necessarie per risolvere il conflitto*”.

La determinazione dell'oggetto della convenzione comporta per la Francia qualche altra considerazione che però potrebbe riguardare anche noi, anche se ad esempio sulla riservatezza la legge detta prescrizioni specifiche e certamente meno elastiche⁴¹⁰.

L'oggetto merita grande attenzione intanto perché deve riguardare, si diceva, la totalità degli aspetti (ad esempio in materia di autorità parentale deve concernere sia gli aspetti patrimoniali, sia quelli extrapatrimoniali), ma soprattutto perché può riguardare soltanto diritti disponibili (art. 2064⁴¹¹) e non è sempre facile distinguerli dagli indisponibili.

La determinazione dell'oggetto poi da noi dovrà essere assai dettagliata se si vuole far decorrere i termini per la prescrizione e la decadenza.

La *procédure participative* è una procedura con assistenza legale obbligatoria.

⁴⁰⁹Art. 21 lett. c) C. 1474.

⁴¹⁰ Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

1.I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2.È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3.I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4.A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.

⁴¹¹ Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

Ciò è ribadito anche dall'art. 1544 del Codice di rito francese nella Sezione I, e dunque in relazione alla procedura partecipativa convenzionale: «*Le parti, assistite dai loro avvocati, ricercano congiuntamente, alle condizioni fissate dalla convenzione, un accordo che metta fine alle differenze che li oppongono*»⁴¹².

In Italia si prevede che la convenzione di negoziazione assistita sia conclusa tramite l'assistenza di uno o più avvocati iscritti all'albo (art. 2 c. 1).

La puntualizzazione sull'iscrizione all'albo non è stata necessaria in Francia: l'Italia è l'unico paese tra i più importanti d'Europa ad avere una sostanziale differenza tra avvocati iscritti e non iscritti all'albo; il CNB⁴¹³ francese in uno studio ha ipotizzato che questi ultimi siano circa 53.000⁴¹⁴.

Un appunto che si potrebbe fare a questa scelta che è dovuta probabilmente solo al tentativo di far emergere i non iscritti, è che in questo modo non si dà alcuna possibilità ai patrocinatori legali di crescere come negoziatori, per quanto effettivamente la cosa sia davvero complessa.

Per di più le materie che sono oggetto di negoziazione assistita fanno sì che ci siano molte controversie di competenza dei patrocinatori da cui dipende la loro sopravvivenza nella professione: secondo la legge Carotti⁴¹⁵ sono patrocinabili controversie, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni di vecchie lire (25.822,84 €); appare una solenne stortura che i praticanti abilitati avvocato possano occuparsene soltanto nel caso di eventuale giudizio dopo magari aver istruito la pratica per il *dominus* ed aver concretamente lavorato alla trattativa col cliente.

Un'altra categoria che sicuramente vedrà drasticamente ridotti i suoi spazi è quella dei patrocinatori stragiudiziali⁴¹⁶ per cui è stata emanata recentemente la norma UNI 11477/2013⁴¹⁷; non si comprende a che cosa sia servito fornire delle garanzie al sistema e ai cittadini se poi si è deciso che possano negoziare solo gli avvocati iscritti all'albo.

La norma aggiunge che anche gli avvocati comunitari che esercitino permanentemente in Italia possono utilizzare questo strumento⁴¹⁸.

È inoltre dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita⁴¹⁹.

⁴¹² Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

⁴¹³ Conseil National des Barreaux

⁴¹⁴ Tra gli avvocati italiani e gli avvocati iscritti alla cassa di previdenza italiana c'era una differenza abissale: al 1/12/12 si contavano 216.728 avvocati e solo 162.820 erano iscritti alla Cassa (si sostiene nel rapporto che la situazione sia cambiata a seguito della legge n° 247 del 31/12/2012). Profession avocat: les chiffres clés de six pays de l'Union européenne – Mars 2013 http://cnb.avocat.fr/Profession-Avocat-Les-chiffres-cles-2013-de-six-pays-de-l-Union-europeenne-quand-les-statistiques-tordent-le-cou-aux_a1593.html

⁴¹⁵ Legge 16 dicembre 1999, n. 479

⁴¹⁶ Si tratta di un'associazione costituita ai sensi della legge sulle professioni non regolamentate (Legge 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013).

⁴¹⁷ Cfr. <http://www.unps.it/norma-uni>

⁴¹⁸ "...tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96".

⁴¹⁹ Decreto-legge art. 2 c. 2 punti 7.

La disciplina sostanziale francese non prevede un obbligo dell'avvocato di illustrare al suo cliente la possibilità di una *procédure participative*.

Forse la preoccupazione del legislatore italiano era quella di realizzare una parificazione sul punto informativa, tra la mediazione (per cui si prevede un dovere di informazione espresso sia con il decreto legislativo 28/10⁴²⁰ sia con il codice deontologico nuovo⁴²¹) e la negoziazione assistita, dal momento che sussiste una condizione di procedibilità⁴²².

Ma non era operazione necessaria dato che il nuovo codice deontologico già prevede l'onere informativo generico di informare il cliente “*dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge*”.

Anche se in Francia conciliazione, mediazione e negoziazione assistita sono sullo stesso piano sotto tutti i punti di vista (art. 1528 C.p.c.⁴²³) l'avvocato non ha un onere specifico di informazione: queste procedure sono tra l'altro volontarie.

Né il codice deontologico forense francese⁴²⁴ prevede alcuna norma che menzioni la *procédure participative* o richieda all'avvocato di spiegare alcunché in merito al suo cliente; contiamo solo due richiami alla mediazione; si afferma che l'avvocato può accettare di essere arbitro, mediatore, esperto, conciliatore, sequestratario, liquidatore amichevole ed esecutore testamentario (art. 6.2)⁴²⁵ e c'è poi una norma analoga che riguarda l'avvocato onorario⁴²⁶.

Ricordo anche un articolo (art. 8.2) intitolato “Regolamento amichevole” che disciplina il caso in cui appunto l'avvocato ritenga che vi siano gli estremi per un accordo amichevole⁴²⁷ che però non riguarda

⁴²⁰ Art. 4 c. 3.

⁴²¹ Art. 27 c. 3 – Doveri di informazione

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

⁴²² Art. 3 c. 1° decreto-legge seconda parte: “L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

⁴²³ Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

⁴²⁴ Aggiornato da ultimo all'11 ottobre 2014.

⁴²⁵ Il peut également être investi d'une mission d'arbitre, d'expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire.

⁴²⁶ Art. 13.3 L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours. Règlement.

Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) in [http://cnb.avocat.fr/docs/RIN/RIN_Consolide+Commentaire\[Version-a-date\].pdf](http://cnb.avocat.fr/docs/RIN/RIN_Consolide+Commentaire[Version-a-date].pdf)

⁴²⁷ Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.

L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.

La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s'assurant préalablement de l'adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l'invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.

la problematica in questione dell'informazione al cliente, ma disciplina i rapporti con l'avversario ed il suo legale⁴²⁸.

In Italia peraltro vi sono diverse ipotesi di illecito disciplinare con riferimento alla norma della negoziazione assistita.

I legali commettono infatti illecito disciplinare se: diventano arbitri arbitri nella stessa controversia od in altra connessa; non sono leali; non sono riservati; se non informano il cliente all'atto dell'incarico della possibilità della negoziazione assistita; se impugnano l'accordo che ne deriva⁴²⁹

I legali sono ancora chiamati a certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale⁴³⁰.

Questa norma che non si ritrova nella legislazione transalpina avrebbe da noi maggior significato se fosse stata accompagnata dalla prescrizione transalpina “...tuttavia l'inesecuzione della convenzione di una parte autorizza l'altra ad adire il giudice perché statuisca sul litigio”⁴³¹.

È di tutta evidenza che se mi rivolgo al giudice perché la convenzione non è stata eseguita devo dimostrare che la convenzione è stata firmata effettivamente dal mio avversario e la certificazione del suo avvocato mi può aiutare in tal senso.

Ma da noi l'inesecuzione della convenzione non mi legittima ad andare dal giudice: e la cosa costituisce un limite perché prima di agire bisogna attendere lo spirare del termine convenuto in convenzione per la procedura che come sappiamo va da un mese a tre mesi salvo proroga⁴³².

La legge prevede, come già accennato, soltanto delle ipotesi, in parallelo con la disciplina della mediazione, in cui non si è obbligati a partecipare ad una negoziazione assistita.

“3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

Ces règles s'appliquent également à l'occasion de toute relation téléphonique, dont l'avocat ne peut prendre l'initiative.

⁴²⁸ Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure. L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier. La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s'assurant préalablement de l'adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l'invitant à lui faire connaître le nom de son conseil. Ces règles s'appliquent également à l'occasion de toute relation téléphonique, dont l'avocat ne peut prendre l'initiative.

⁴²⁹ Quest'ultima disciplina non è coordinata con quella del codice deontologico (art. 44) che prevede invece per la transazione la possibilità di impugnazione per fatti sopravvenuti o di cui non si era venuti a conoscenza.

⁴³⁰ Decreto-legge art. 2 c. 2 punti 5-6.

⁴³¹ ...Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige (art. 2065).

⁴³² Art. 2 c 2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Gli unici casi in cui posso avvalermi del giudice durante la procedura è quello in cui ho bisogno di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari

In Francia la norma sulla legittimante inesecuzione è stata prevista unitamente alla facoltà di richiedere al giudice misure provvisorie e conservatorie; non ci sono invece gli altri casi che legittimano le parti ad andare in giudizio durante la vigenza della procedura⁴³³.

Prevedere insomma anche da noi l'inesecuzione della convenzione come motivo per adire la giurisdizione, avrebbe certamente potuto evitare comportamenti defatigatori.

Anche la disciplina dell'invito appare poco efficace:

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Sarebbe stato meglio forse stabilire l'avveramento della condizione di procedibilità se entro 30 giorni non si stipulava la convenzione; così come è scritto premia il silenzio di chi concorda di negoziare per guadagnare tempo.

Anche se la disciplina prevede delle sanzioni.

“L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile”⁴³⁴.

Qui ci sono dunque delle sanzioni per il rifiuto poiché il giudice può valutare il rifiuto ai fini delle spese, potrebbe configurare una responsabilità aggravata e autorizzare l'esecuzione provvisoria nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo.

⁴³³ Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties (art. 2065 C.c.).

⁴³⁴ Art. 4 c. 1 decreto-legge e testo convertito.

Sarà invero difficile che possa intervenire quest'ultima autorizzazione dato che la presenza di un monitoraggio, compresa la sua fase di opposizione, implica che non si vada in negoziazione assistita.

La procedura francese non può essere utilizzata nella materia del lavoro⁴³⁵.

Al contrario il nostro legislatore aveva previsto una sostanziale modifica dell'art. 2113 C.c. introducendo la negoziazione assistita tra avvocati tra le sedi protette in cui è possibile transigere⁴³⁶.

Il che allo scrivente ex lavorista appariva operazione a dir poco spregiudicata; a prescindere dal possibile nocumento per gli enti previdenziali non si comprendeva come potesse essere negata al mediatore terzo che è neutrale la possibilità di mediare nella materia del lavoro e si fosse messo invece un meccanismo così delicato nelle mani di soggetti che fanno per natura l'interesse dei propri clienti; non è chi non veda la seria ed incombente minaccia dello squilibrio di poteri.

Al Senato la norma è stata cancellata ed oggi la legge di conversione ribadisce addirittura che la negoziazione assistita non può vertere in materia di lavoro⁴³⁷.

In Francia le parti, a conclusione della procedura partecipativa, possono raggiungere un accordo su tutte o su alcune delle controversie che può essere sottoposto all'omologazione del giudice⁴³⁸.

Quando, non riuscendo a raggiungere un accordo con la procedura partecipativa, le parti presentano la loro controversia in tribunale, sono esentati dal preventivo tentativo di conciliazione o di mediazione, se previsto⁴³⁹.

Tale norma, lo abbiamo detto, appare criticabile dal momento che la mediazione non agisce solo sul piano dei diritti, ma soprattutto su quello degli interessi e quindi la procedura di mediazione non può considerarsi equiparabile ad un contratto stipulato con l'assistenza dei legali e tantomeno ad un non accordo. Inoltre potrebbe aggiungersi che la mediazione o la conciliazione sono di ausilio proprio quando la negoziazione diretta od indiretta si sia rivelata inefficace.

Pertanto con questa norma si evita che le parti restino vincolati da una clausola di mediazione che abbiano previsto pattizamente; tale prescrizione ha determinato l'aspra critica degli organismi francesi di mediazione.

Il nostro legislatore sul punto, non ha previsto la possibilità di evitare la mediazione, ma ha stabilito semplicemente una rigida separazione per materie: e dunque per alcune è necessaria la mediazione, per

⁴³⁵ Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Art. 2064 cpv C.c.

⁴³⁶ L'art 7 del decreto-legge prevede che "1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato»."

⁴³⁷ Art. 2 c. 2 lett. b) "l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro".

⁴³⁸ Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. (Art. 2066 c. 1 C.c.) Non si fa qui che riprendere la prassi vigente in materia di transazioni tra avvocati.

⁴³⁹ Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Art. 2066 c. 2 C.c.

altre la negoziazione assistita; ultimato il percorso di entrambe secondo le regole dell'uno o dell'altro istituto si può adire il giudice.

Qualsiasi persona, assistita dal suo avvocato, può in Francia concludere una convenzione di procedura partecipativa a condizione, come è detto, che i diritti siano disponibili, fatte salve le disposizioni dell'art. 2067⁴⁴⁰, ossia quelle che attengono alla separazione ed al divorzio, materie nelle quali comunque è possibile utilizzare la procedura, ma non vi sono le conseguenze in caso di mancato raggiungimento di un accordo, ossia si celebrerà il tentativo di conciliazione in quanto previsto.

Una convenzione di procedura partecipativa può essere dunque raggiunta dai coniugi che siano in cerca di una soluzione consensuale per il divorzio o la separazione⁴⁴¹.

La domanda di divorzio o separazione legale presentata a seguito di una convenzione di procedura partecipativa è formata e giudicata secondo le norme inerenti al divorzio contenute nel titolo VI del libro I del Codice civile⁴⁴².

Il divorzio in Francia non costituisce appunto diritto disponibile. Per questo motivo la legge precisa che per la procedura partecipativa si devono seguire le norme del titolo VI del libro I del Codice civile.

Se sfogliamo detta ultima normativa abbiamo visto che ci sono plurime occasioni in cui le parti assistite dai loro avvocati possono sottoporre al giudice gli accordi derivanti da una procedura partecipativa.

Ma il punto che qui interessa e che distingueva la disciplina transalpina da quella italiana previgente e di cui al decreto 132/14⁴⁴³ è proprio il fatto che in Francia non ci sono casi di sottrazione dei rapporti di famiglia al loro giudice naturale ed il giudice preside a tutti gli accordi che le parti possano rinvenire.

⁴⁴⁰ Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067. Art. 2064 c. 1 C.c.

⁴⁴¹ Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. Art. 2067 c. 1 C.c.

⁴⁴² La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce. Art. 2067 C.c. c. 2 ultima parte.

⁴⁴³ Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

(omissis)

Con la legge di conversione 162/14 si è pensato di modificare la normativa stabilendo che comunque ci sia un passaggio giudiziario anche in Italia⁴⁴⁴ e quindi ci si è avvicinati alla concezione transalpina, seppure in Francia vigano regole diverse sia per la procedura, sia per la sostanza.

Con la legge 162/14 dunque se non ci sono figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta sostanzialmente per trasmettere l'accordo all'ufficiale dello stato civile.

Se invece c'è presenza delle categorie sopra nominate è prevista sempre la trasmissione al p.m. entro 10 giorni, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene al contrario che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3, e dunque la trasmissione all'ufficiale di stato civile da parte dell'avvocato⁴⁴⁵.

Dicevamo che la disciplina francese è diversa da quella italiana: ognuna delle ipotesi che ho sommariamente elencato vede la presenza del giudice e dunque di un processo.

Dalla disciplina già esaminata si può comprendere che la disciplina francese non protegge solo i minori, gli incapaci e i figli maggiorenni non autonomi, ma a differenza della nostra, protegge anche il coniuge, specie quello più debole.

⁴⁴⁴ Prima si prevedeva soltanto "in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti".

⁴⁴⁵ 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori». L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. Il testo convertito in legge sulla negoziazione assistita

Per avere contezza della la disciplina italiana rispetto a quella francese, mi pare opportuno riportare qui di seguito il testo coordinato, a seguito della conversione del decreto-legge 132/14 (in grassetto e di colore verde sono riportate le modifiche intervenute ed approvate durante il percorso parlamentare per la conversione)⁴⁴⁶.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

CAPOII – PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI.

⁴⁴⁶ Anche se non ce ne occupiamo riportiamo qui anche il testo del nuovo arbitrato endoprocessuale

Art. 1

Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.

Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da **uno o più avvocati**

1. La convenzione di negoziazione assistita da **uno o più avvocati** è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

- a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese **e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.**
- b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili **o vertere in materia di lavoro.**

3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di **uno o più avvocati.**

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3. Improcedibilità

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di

quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d) nei procedimenti in camera di consiglio;
- e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. **Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.**

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4. Non accettazione dell'invito e mancato accordo

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può

essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Art. 5. Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti **soggetti a trascrizione**, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da **uno o più avvocati** per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione assistita **da almeno un avvocato per parte** può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge **1° dicembre** 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al

procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, **terzo periodo**, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000 ad euro 10.000**. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio”;

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”.

Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.

Art. 10. Antiriciclaggio

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,».

Art. 11. Raccolta dei dati

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

mediarensenzaconfini.org

5. La disciplina francese

Il Codice civile

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 2062

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

Article 2063

La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

1° Son terme ;

2° L'objet du différend ;

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

Article 2064

Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Article 2065

Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

Article 2066

Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Article 2067

Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

Article 2068

La procédure participative est régie par le code de procédure civile.

mediarensenzaconfini.org

Codice di procedura civile

Livre V : La résolution amiable des différends

Article 1528

Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Titre II : La procédure participative

Article 1542

La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.

Article 1543

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Chapitre Ier : La procédure conventionnelle

Section 1 : Dispositions générales

Article 1544

Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

Article 1545

Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

Article 1546

La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Section 2 : Le recours à un technicien

Article 1547

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Article 1548

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.

Article 1549

Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1550

A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Article 1551

Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Article 1552

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.

Article 1553

Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

Article 1554

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

Ce rapport peut être produit en justice.

Section 3 : L'issue de la procédure

Article 1555

La procédure conventionnelle s'éteint par :

1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Article 1556

A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend

Article 1557

La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article 1558

Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

Article 1559

Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article 1561.

Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel

Article 1560

Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :

les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Article 1561

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.

Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation

ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend

Article 1562

Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Article 1563

La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

Article 1564

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.

Titre III : Dispositions communes

Article 1565

L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Article 1566

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Article 1567

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

©Tutti i diritti sono riservati.

1

1. Introduzione; 2

2

2. La procédure participative; 7
2.1 I provvedimenti normativi e la genesi; 7
2.2 Uno sguardo comparato; 16
2.3 La procédure participative, la negoziazione e le tecniche di comunicazione; 20
2.4 La disciplina in generale; 22
2.5 La procédure participative in materia di famiglia; 28
2.6. La comparsa del tecnico nella procedura partecipativa; 56

2.7. Conclusione della procedura convenzionale e di quella a fine del giudizio; 61

3

3. Un raffronto tra la legislazione francese e quella italiana.; 66

4

4. Il testo convertito in legge sulla negoziazione assistita; 90

5

5. La disciplina francese; 97

mediaresenzaconfini.org